

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

CRISTIÁN BOETSCH GILLET

Los siguientes apuntes, cuyo exclusivo objeto es facilitar el estudio de la Responsabilidad Contractual por parte de los alumnos, han sido elaborados en base a extractos de diversos libros y manuales de estudio, a los cuales se han adicionado comentarios.

De los libros y manuales empleados se deben destacar los siguientes:

1. **ABELIUK MANASEVICH, René**, *Las Obligaciones*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1993.
2. **ALCALDE RODRÍGUEZ, Enrique**, *La Responsabilidad Contractual. Causa y efectos de los contratos y sus obligaciones*, Ediciones UC, 2018.
3. **ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo**, *Teoría de las Obligaciones*, Santiago, Editorial Ediar-Conosur 1988.
4. **BARAONA GONZÁLEZ, Jorge**, “Responsabilidad contractual y factores de imputación de daños: apuntes para una relectura en clave objetiva”, en *Revista Chilena de Derecho*, vol. 24 N° 1, 1997.
5. **CÁRDENAS VILLARREAL, Hugo y REVECO URZÚA, Ricardo**, *Remedios contractuales. Cláusulas, acciones y otros mecanismos de tutela del crédito*, Thomson Reuters, 2018.
6. **FUEYO LANERI, Fernando**, *Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1990.
7. **GATICA PACHECO, Sergio**, *Aspectos de la indemnización de perjuicios por incumplimiento del contrato*, Editorial Jurídica de Chile, 1959.
8. **PEÑAILILLO ARÉVALO, Daniel**, “Responsabilidad contractual objetiva”, *Estudios de Derecho Civil IV*, LegalPublishing, Santiago, 2009, pp. 331 y ss.
9. **RODRÍGUEZ GREZ, Pablo**, *Responsabilidad Contractual*, Editorial Jurídica de Chile, 2003
10. **VIAL DEL RÍO, Víctor**, *Manual de las Obligaciones en el Código Civil Chileno*, Editorial Biblioteca Americana, Santiago, Segunda Edición, 2007.

TEMARIO

I.

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y “EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES”

II.

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

III.

ASPECTOS GENERALES DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

1. ASPECTOS GENERALES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN GENERAL, Y DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL EN PARTICULAR.
 - 1.1. Concepto general de responsabilidad civil.
 - 1.2. Estatutos de responsabilidad civil que el Código Civil reglamenta. Regla general.
 - 1.3. Sentido restringido y amplio de la responsabilidad contractual.
 - 1.4. Análisis general del régimen de acciones o “remedios” ante el incumplimiento de un contrato.
 - 1.5. Sistema de atribución de responsabilidad. Objetivación de la responsabilidad contractual.
2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN COMO FACTOR DE ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.
 - 2.1. Causales de incumplimiento que la ley distingue.
 - 2.2. Casos en que el incumplimiento no da lugar a responsabilidad contractual.
 - 2.3. Incumplimiento del contrato y distinción entre obligaciones de medio y de resultado.
 - 2.4. Prueba del incumplimiento y presunción de imputabilidad

IV.

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

1. NOCIONES GENERALES.
2. CONCEPTO DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO.
3. EN CUANTO A SI LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO ES EL “DERECHO PRINCIPAL” DEL ACREEDOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO.
4. OBJETO DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO. CUMPLIMIENTO EN “NATURALEZA” Y “POR EQUIVALENCIA”.
5. PRESUPUESTOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO.
6. CUMPLIMIENTO Y “EJECUCIÓN FORZADA” DE OBLIGACIONES DE DAR, HACER Y NO HACER.

- 6.1. Cumplimiento forzado de obligaciones de dar.
- 6.2. Cumplimiento forzado de obligaciones de hacer.
- 6.3. Cumplimiento forzado de obligaciones de no hacer.
- 7. LÍMITES A LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO.

V.

RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

V.A.

LA CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA

- 1. CONSIDERACIONES GENERALES.
- 2. CONCEPTO.
- 3. FUNDAMENTO DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA.
- 4. CARACTERÍSTICAS DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA (EN CUANTO CONDICIÓN).
- 5. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA.
 - 5.1. En cuanto a si se aplica exclusivamente a los contratos bilaterales, o también tiene aplicación respecto de los contratos unilaterales.
 - 5.2. La resolución en los contratos de tracto sucesivo.
 - 5.3. La resolución no tiene lugar en la partición.
- 6. EL INCUMPLIMIENTO RESOLUTORIO, PRESUPUESTO FUNDAMENTAL PARA EJERCER LA ACCIÓN RESOLUTORIA.
- 6. NECESIDAD DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN RESOLUTORIA Y DE UNA SENTENCIA JUDICIAL QUE DECLARE LA RESOLUCIÓN.
 - 6.1. La acción resolutoria.
 - 6.2. En cuanto a la posibilidad de enervar la acción resolutoria mediante la excepción de pago.
- 7. EN CUANTO A SI ES O NO NECESARIO QUE QUIEN DEMANDE LA RESOLUCIÓN DEBA HABER CUMPLIDO SU PROPIA OBLIGACIÓN O ALLANARSE A CUMPLIRLA. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ART. 1552.
- 8. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.
- 9. RESOLUCIÓN, NULIDAD Y RESCILIACIÓN.

V.B.

EL PACTO COMISORIO

- 1. CONCEPTO.
- 2. EL PACTO COMISORIO PROCEDE EN CUALQUIER CONTRATO Y POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA OBLIGACIÓN.
- 3. PACTO COMISORIO SIMPLE Y PACTO COMISORIO CALIFICADO
- 4. EFECTOS DEL PACTO COMISORIO
 - 4.1. Efectos del pacto comisorio típico.
 - 4.2. Efectos del pacto comisorio atípico.
- 5. PRESCRIPCIÓN DEL PACTO COMISORIO

V.C.

CLÁUSULA DE TÉRMINO UNILATERAL DEL CONTRATO

VI.
ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE LOS PERJUICIOS

VI.1.
NOCIONES GENERALES

1. CONCEPTO
2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR PERJUICIOS
3. CLASES DE INDEMNIZACIÓN
4. NO SE PUEDE ACUMULAR EL CUMPLIMIENTO Y LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS COMPENSATORIA, PERO SÍ EL CUMPLIMIENTO Y LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA O BIEN AMBAS INDEMNIZACIONES.
5. ¿ES LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS UN REMEDIO AUTÓNOMO, O BIEN ES DEPENDIENTE DEL CUMPLIMIENTO FORZADO O DE LA RESOLUCIÓN?
 - 5.1. Doctrina tradicional
 - 5.2. Doctrina moderna
 - 5.3. La jurisprudencia.
 - 5.4. Nuestra opinión.

VI.2.
REQUISITOS DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

1. PRIMER REQUISITO: INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE
 - 1.1. Clases de incumplimiento.
 - 1.2. Prueba del incumplimiento y presunción de imputabilidad
 - 1.3. Imputabilidad del deudor (dolo o culpa del deudor)
 - 1.3.1. Dolo contractual
 - 1.3.2. La culpa contractual
2. SEGUNDO REQUISITO: PERJUICIO DEL ACREEDOR
 - 2.1. Concepto
 - 2.2. Requisitos
 - 2.3. Clasificación de los perjuicios.
 - (i) Perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales.
 - (ii) Daño emergente y lucro cesante.
 - (iii) Perjuicios directos e indirectos.
 - (iv) Perjuicios directos previstos y directos imprevistos.
 - 2.4. Prueba de los perjuicios
3. TERCER REQUISITO: RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL INCUMPLIMIENTO Y LOS PERJUICIOS
 - 3.1. Concepto
 - 3.2. Teorías acerca de la causalidad
 - 3.3. La causalidad en la responsabilidad contractual
 - 3.4. Interrupción del nexo causal
4. CUARTO REQUISITO: MORA DEL DEUDOR
 - 4.1. Generalidades

- 4.2. Concepto
- 4.3. Requisitos
- 4.4. Efectos de la mora
- 4.5. Mora del acreedor

VI.3. AVALUACIÓN DE PERJUICIOS

- 1. AVALUACIÓN JUDICIAL
 - 1.1. Introducción
 - 1.2. Perjuicios que deben indemnizarse
- 2. AVALUACIÓN LEGAL
 - 2.1. Concepto y Naturaleza Jurídica
 - 2.2. Características de la liquidación legal
 - 2.3. Reglas del art. 1559
- 3. AVALUACIÓN CONVENCIONAL: LA CLÁUSULA PENAL
 - 3.1. Concepto
 - 3.2. Funciones que cumple la cláusula penal
 - 3.3. La cláusula penal puede ser compensatoria o moratoria
 - 3.4. Diferencias de la cláusula penal con la indemnización de perjuicios ordinaria
 - 3.5. Paralelo de la cláusula penal con otras instituciones
 - 3.6. Características
 - 3.7. Extinción de la cláusula penal
 - 3.8. Efectos de la cláusula penal
 - 3.9. Cobro de la pena, de la obligación principal y la indemnización ordinaria de perjuicios
 - 3.10. Pluralidad de acreedores o de deudores
 - 3.11. Cláusula penal enorme

VII. CAUSALES DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

- 1. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
 - 1.1. Concepto
 - 1.2. Elementos o requisitos del caso fortuito
 - 1.3. Efectos del caso fortuito
 - 1.4. Excepciones en el que el caso fortuito no libera de responsabilidad al deudor
 - 1.5. Prueba del caso fortuito
- 2. AUSENCIA DE CULPA
- 3. OTRAS SUPUESTAS CAUSALES DE EXENCIÓN
 - 3.1. EL ESTADO DE NECESIDAD
 - 3.2. HECHO O CULPA DEL ACREEDOR
 - 3.3. EL HECHO AJENO
 - 3.4. TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN
 - 3.5. LA FRUSTRACIÓN DEL FIN DEL CONTRATO

VII.
MEDIOS DE CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR:
LOS “DERECHOS AUXILIARES DEL ACREEDOR”

VII.A.
CONSIDERACIONES GENERALES

1. EL DERECHO DE PRENDA GENERAL
2. FUNDAMENTO DE LOS MEDIOS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, COMÚNMENTE DENOMINADOS “DERECHOS AUXILIARES DEL ACREEDOR”

VII.B.
MEDIDAS CONSERVATIVAS

VII.C.
LA ACCIÓN OBLICUA O SUBROGATORIA

1. CONCEPTO
2. CASOS EN QUE SE LA LEY CONSAGRARÍA EXPRESAMENTE LA ACCIÓN OBLICUA.
3. ACCIÓN SUBROGATORIA GENERAL.
 - 3.1. Debate sobre la procedencia de la acción oblicua en Chile
 - 3.2. Requisitos para que opere una acción oblicua general
 - 3.3. Efectos de la subrogación

VII.D.
LA ACCIÓN PAULIANA O REVOCATORIA

1. CONCEPTO
2. REQUISITOS
3. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PAULIANA
4. EFECTOS DE LA ACCIÓN PAULIANA
5. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN PAULIANA

VII.E.
EL BENEFICIO DE SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS

VIII.
CLÁUSULAS ESPECIALES SOBRE
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

1. CONSIDERACIONES GENERALES.
2. CONSIDERACIONES GENERALES RELATIVAS A LAS CLÁUSULAS QUE ALTERAN LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y SU INTERPRETACIÓN

- 2.1. Las cláusulas que alteran la responsabilidad contractual requieren de una estipulación expresa, especial y explícita.
 - 2.2. Literalidad, intención y buena fe en la interpretación contractual.
 - 2.3. Por su naturaleza, las cláusulas que exoneran, reducen o restringen la responsabilidad civil deben ser interpretadas restrictivamente.
 - 2.4. La interpretación de una cláusula limitativa de responsabilidad no admite presumir la voluntad o intención de condonar el dolo (o culpa grave) pasado.
 - 2.5. A su turno, la condonación del dolo (o culpa grave) constituye un límite a las cláusulas restrictivas de responsabilidad civil.
3. ANÁLISIS PARTICULAR DE DETERMINADAS CLÁUSULAS DE ESTILO
- 3.1. Del sentido y alcance que debe darse a la cláusula conforme a la cual “no se admitirá interpretación” de una cláusula en particular o del contrato en general.
 - 3.2. Del sentido y alcance que debe darse a las exoneraciones y limitaciones de responsabilidad que se pactan respecto de “todo” o “cualquier” incumplimiento.
 - 3.3. Del sentido y alcance que debe darse a las estipulaciones que establecen limitaciones a la responsabilidad aplicable a “todo” o “cualquier” daño.
 - 3.4. Del sentido y alcance que debe darse a la cláusula que habilita a indemnizar todo daño, inclusive “los indirectos”.

I.

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y “EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES”

Tradicionalmente, la doctrina nacional estudia la responsabilidad contractual bajo el rótulo “efecto de las obligaciones”, atendido que las principales normas -aunque no todas- se encuentran en el Título XII del Libro IV (arts. 1545 a 1559, ambos inclusive), precisamente denominado “*Del efecto de las obligaciones*”.

Con todo, como bien observa CLARO SOLAR, lo cierto es que más allá de su nombre, el referido Título XII trata promiscuamente los efectos *de los contratos* y los efectos *de las obligaciones*, que son cosas diferentes. Tal defecto provendría de haber seguido en el punto al Código francés, cuestión llamativa pues los autores en que se inspiró el *Code* -POTHIER, DOMAT- no incurrían en esta confusión, y distinguían con claridad ambas cosas.

CLARO SOLAR se explica los motivos de la confusión expresando que se debe a que “siendo las **obligaciones el efecto del contrato**, y habiéndose propuesto **tratar de las obligaciones convencionales (contractuales)** y **no**, en general, de las **obligaciones**, estimaron que en el efecto de las obligaciones se comprendía también el efecto de los contratos”.

Lo cierto es que los **efectos del contrato** son los **derechos y las obligaciones que genera**. El contrato es una de las fuentes de las obligaciones, como lo señala expresamente el art. 1437.

En cambio, el **efecto de la obligación**, mirado desde el punto de vista del **deudor**, viene a ser la **necesidad jurídica en que se encuentra de tener que dar, hacer o no hacer algo** en favor de **acreedor**. Y mirado, desde el punto de vista de este último, son los **medios que la ley le otorga para obtener del deudor el pago íntegro y oportuno de la prestación debida**. En razón de ello es que, como antes se indicaba, tradicionalmente es a propósito del estudio de los efectos de las obligaciones que se analiza la responsabilidad contractual.

Cabe observar que, en todo caso, las normas que regulan los efectos de las obligaciones se encuentran dispersas en diversos títulos del Libro IV, por lo que el estudio de la materia abarca mucho más que el Título XII, teniendo especial relevancia el art. 1489 del Código.

No obstante la trascendencia de la materia, no es pacífico a nivel doctrinal lo que debe entenderse por “efectos de las obligaciones”.

Sobre la materia, la **doctrina tradicional** se enfoca a analizar los *efectos derivados del incumplimiento de la obligación*. En tal sentido, ALESSANDRI señala que los efectos de las

obligaciones “son los derechos que la ley confiere al acreedor, para exigir del deudor el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación, cuando éste no la cumpla en todo o en parte o está en mora de cumplirla”. En similares términos CLARO SOLAR expresa que “el efecto de las obligaciones es colocar al deudor en la necesidad jurídica de dar, hacer o no hacer alguna cosa dando al acreedor los medios de obtener la ejecución de esta prestación”.

Así las cosas, la doctrina tradicional no considera como un efecto de las obligaciones todo lo referente al cumplimiento propiamente tal de las obligaciones, esto es, principalmente el pago, que por definición legal es “la prestación de lo que se debe”.

Como observa ABELIUK, la doctrina tradicional en buena medida sigue en parte la concepción del Código, puesto que bajo el título de efectos de la obligación trata fundamentalmente el incumplimiento, y el cumplimiento lo reglamenta entre los modos de extinguir las obligaciones.

En tal sentido, resulta habitual observar en los tratados y manuales clásicos sobre la materia, el señalar que los efectos de las obligaciones, esto es, los derechos que el acreedor posee frente al incumplimiento del deudor, son los siguientes:

- (i) En primer lugar, el acreedor tendría un “derecho principal”, consistente en la facultad para exigir el cumplimiento, aun forzado, de la obligación, si ello es posible.
- (ii) Luego, el acreedor tendría un “derecho secundario”, que podría ejercer ante la imposibilidad de obtener el cumplimiento y como un sustituto del mismo: la indemnización de perjuicios, a la que también se denominaba “cumplimiento por equivalencia”.
- (iii) Adicionalmente, el acreedor se encuentra dotado de los denominados “derechos auxiliares”, principalmente destinados a mantener la integridad del patrimonio.

Frente a tal concepción tradicional de los efectos de las obligaciones, limitada al estudio del incumplimiento de la obligación, durante la segunda mitad del siglo XX una serie de autores –entre ellos FUEYO y ABELIUK- comenzaron a expandir el enfoque de la materia, a efectos de observar que el adecuado estudio de los efectos de las obligaciones necesariamente debe comprender el estudio de su cumplimiento.

En este punto, FUEYO observa que la doctrina tradicional, enfocada exclusivamente en los efectos derivados del incumplimiento de la obligación, “omite, sin embargo, el efecto primero y principal de la obligación, el que justamente se denomina normal, a la vez la razón fundamental tenida en cuenta particularmente por el acreedor al vincularse jurídicamente.

Se trata del efecto de cumplimiento, realizado espontáneamente y de conformidad al contenido efectivo de la obligación. Es la razón fundamental por la cual ha contratado el acreedor y aun el propio deudor”.

Bajo tal entendido, ABELIUK analiza la materia bajo la siguiente pauta:

- (i) Efectos en el cumplimiento, que se traduce en estudiar el deber del deudor de cumplir y su responsabilidad patrimonial, el pago y otras modalidades del cumplimiento, que no siendo pago propiamente tal, lo implican o equivalen: dación en pago, compensación, novación y confusión.
- (ii) Efectos de la obligación en cuanto da lugar a los derechos auxiliares de protección del patrimonio del deudor.
- (iii) Efectos en el incumplimiento, a saber, derecho del acreedor a obtener el cumplimiento forzado si ello es posible, y a falta de él, la indemnización de perjuicios.

Como se puede observar, la discrepancia dice más bien con un tema de enfoque y sistematización, en torno a si incluir o no el estudio del cumplimiento y pago en el estudio de los efectos de las obligaciones. De ahí que el propio ABELIUK indique que “se trata de un mero problema de método y claridad en el enfoque de la institución”.

En tal sentido, en nuestro concepto resulta acertada una visión amplia de los efectos de las obligaciones, comprensiva tanto del cumplimiento como del incumplimiento de las obligaciones. Sin perjuicio de ello, no puede obviarse el hecho que la doctrina tradicional sigue en buena medida la sistematización del Código, en orden a que el cumplimiento o pago se regula a propósito de los modos de extinguir las obligaciones.

Atendido lo anterior, y a fin de tener una visión global de la materia, más adelante se enunciarán los principales efectos de las obligaciones en lo referente al cumplimiento de las obligaciones, dejándose el estudio detallado del mismo para el capítulo del pago como modo de extinguir.

Luego se analizarán los efectos en lo referente al incumplimiento de la obligación, y propiamente la responsabilidad contractual. Sobre la materia, en general no se seguirá la distinción tripartita de los “derechos del acreedor” al que alude la doctrina tradicional, consistente en un “derecho principal” a pedir el cumplimiento forzado, un “derecho secundario” o subsidiario a pedir la indemnización, además de la existencia de “derechos auxiliares”.

Si bien tal distinción presenta ciertas virtudes de orden pedagógico, lo cierto es que da cuenta de una visión algo parcial del tema, y más importante, que no se adecúa plenamente a lo que la ley prescribe. En tal sentido, y no obstante su ubicación, lo cierto es que la norma fundamental en materia de efectos derivados del incumplimiento de un contrato es el art. 1489, en cuanto es la disposición que consagra los derechos o remedios con que cuenta el acreedor en tales casos, consagrando al efecto el derecho a pedir el cumplimiento, alternativamente el derecho a pedir la resolución del contrato, y adicionalmente solicitar la correspondiente indemnización de perjuicios.

Lo relevante es que el art. 1489, lejos de distinguir entre derechos “principales” y “secundarios”, expresamente indica que ante el incumplimiento el acreedor tiene la opción de pedir el cumplimiento o la resolución, y en uno y otro caso con indemnización de perjuicios. Tal opción la ejerce el acreedor “a su arbitrio”, y por tanto no tiene que justificar su decisión ni procede cotejar las consecuencias de la alternativa elegida con las de la abandonada para enjuiciarla y deducir alguna limitación.

II.

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La obligación es un vínculo jurídico entre dos personas determinadas -deudor y acreedor- en virtud del cual el primero se encuentra en la necesidad jurídica de dar, hacer o no hacer algo en favor del segundo.

De lo anterior se deriva que la obligación constituye un vínculo que tiene **fuerza obligatoria**, y por tanto el deudor debe cumplir.

En tal contexto, el “cumplimiento” de las obligaciones alude a los requisitos que debe satisfacer el cumplimiento **voluntario** o espontáneo del deudor (en oposición al cumplimiento *forzado*, exigido por el acreedor a causa de un incumplimiento previo) y **en naturaleza**, esto es, tal como la obligación fue establecida (en oposición a lo que tradicionalmente se denominad cumplimiento *por equivalencia*, consistente en la indemnización de perjuicios como sustitutivo de la prestación).

Así las cosas, la forma más perfecta de cumplimiento es el **pago efectivo o solución**, el cual, por definición legal contenida en el art. 1568, es precisamente “la prestación de lo que se debe”, agregando el art. 1569 que “se hará bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación”. De ahí que el inciso segundo de dicha norma disponga que “el acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba ni aun a pretexto de ser igual o mayor valor la ofrecida.

Es decir, **cumplimiento y pago son conceptos sinónimos**. Por tanto, el concepto de pago es mucho más amplio que el coloquial e iletrado (que en general lo reduce al cumplimiento de una obligación de dinero), ya que jurídicamente el pago es el cumplimiento de toda obligación, sea esta de dar, hacer o no hacer.

El pago tiene algunas **características o principios especiales**: (i) la identidad del pago se traduce en que debe hacerse “bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación...”, sin que pueda ser obligado el acreedor a recibir “otra cosa que lo que se le deba ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida” (art. 1569); (ii) la integridad del pago significa que el pago debe ser total, de la obligación y sus accesorios, y por tanto “el pago de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban” (art. 1591 inc. 2º). Por la misma razón y salvo excepciones, los gastos del pago son de cargo del deudor (artículo 1571), porque si ellos corrieran por cuenta del acreedor ya no recibiría éste integra la prestación; y (iii) la indivisibilidad del pago significa que “el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención

contraria; y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales” (art. 1591 inc. 1º). Por excepción, se puede dividir el pago, en determinados casos (v.gr. si así lo acuerdan las partes, en las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas, etc.).

De especial relevancia es observar que **el pago o cumplimiento del contrato debe hacerse de buena fe**, conforme lo dispone el art. 1546 del Código, que señala: *“Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”*.

La buena fe constituye un principio a la luz del cual todo contrato (desde luego un mandato) debe ser informado, integrado e interpretado. Como señala BETTI, la buena fe contractual consiste esencialmente en un *“deber de cooperación debido en interés ajeno”*, y por lo mismo se traduce en una conducta leal caracterizada por el consciente respeto hacia el interés de la contraparte, esto es, en una actitud activa de cooperación en interés ajeno, en una actitud de fidelidad al vínculo. Desde un punto de vista del acreedor, el titular de un derecho emanado de un contrato tiene la obligación de conducirse según la buena fe, y por lo tanto deberá ejercer sus derechos según la confianza depositada por la otra parte, lo cual lo imposibilita de abusar de su crédito en desmedro del deudor, aprovechando circunstancias nocivas que puedan afectar a la parte pasiva de la obligación. En este sentido, LARENZ indica que esta obligación rige para todos los participantes en la relación jurídica en cuestión, *“con el mandato de conducirse como corresponda en general al sentido y finalidad de esta especial vinculación y a una conciencia honrada”*. Así también lo ha entendido nuestra jurisprudencia, al resolver que *“el principio de la buena fe, debe ser aplicado y respetado por las partes en todos los contratos que celebren y en todas sus etapas”*.

Como se ha indicado, el Código Civil califica al pago como un **modo de extinguir las obligaciones** (arts. 1567 N° 1), y en tal calidad reglamenta sus más diversos aspectos (por quién puede hacerse, a quién debe pagarse, dónde debe hacerse el pago, cómo debe hacerse el pago, etc.) y modalidades (pago por consignación, con subrogación, por cesión de bienes, con beneficio de competencia; reconociéndose también la dación en pago).

Siguiendo al Código, el análisis detallado del pago –esto es, del cumplimiento (voluntario y en naturaleza)- se realizará más adelante, en el capítulo referente a los modos de extinguir las obligaciones.

Sin perjuicio de ello, en lo que respecta a la calificación del pago como modo de extinguir obligaciones, cabe por ahora observar que, como señala ABELIUK, **el pago extingue naturalmente la obligación, pero por vía consecencial**, porque ella se cumple desempeñando el rol y la finalidad jurídicos que le dieron nacimiento; la extinción se produce precisamente porque la obligación ha desarrollado y agotado sus efectos normales. Por ello es que se sostiene que el cumplimiento o pago corresponde a la fase de “vida de la

obligación”, ya que las obligaciones se pagan o cumplen cuando se encuentran vigentes; y solo una vez que se ha llegado al pago total y efectivo, es que se produce la extinción de la obligación.

En suma, el principal efecto de la obligación es su cumplimiento o pago efectivo; y a falta de éste, aparecen los efectos del incumplimiento, que se pasan a analizar a continuación.

III.

ASPECTOS GENERALES

DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

Y DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

1. ASPECTOS GENERALES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN GENERAL, Y DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL EN PARTICULAR.

1.1. Concepto general de responsabilidad civil.

En términos muy generales, la *responsabilidad* consiste en la necesidad efectiva, o eventual, en que se encuentra una persona de hacerse cargo de las consecuencias gravosas de un acto que se le atribuye como propio.

En particular, la *responsabilidad civil* consiste en la necesidad en que se encuentra un individuo de tener que reparar un daño causado por su obrar doloso o culposo; tal necesidad se satisface por medio de la indemnización de perjuicios.

Como se puede observar, la responsabilidad civil se encuentra esencialmente vinculada al *daño* que sufre una o más personas, y al deber de repararlo o compensarlo con medios equivalentes. En este sentido, la Corte Suprema ha resuelto que “Por responsabilidad debe entenderse, en general, la obligación en que se coloca una persona para reparar adecuadamente todo daño o perjuicios causado”. La esencialidad del daño exigida por la responsabilidad civil constituye una notable diferencia con la responsabilidad penal, pues esta última contempla la existencia de figuras delictivas de mero peligro y sanciona conductas tentativas y frustradas, sin daño.

1.2. Estatutos de responsabilidad civil que el Código Civil reglamenta. Regla general.

De conformidad al art. 1437 las obligaciones pueden encontrar cinco fuentes: el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. Frente al incumplimiento de una obligación, el Libro IV del Código Civil regula dos estatutos jurídicos de responsabilidad: en el Título XII se regula la responsabilidad contractual, referidas al incumplimiento de obligaciones que surgen de un contrato; por su lado, el Título XXXV regula la responsabilidad extracontractual, que consiste en la obligación en que se encuentra el autor de indemnizar los perjuicios que su hecho ilícito, delito o cuasidelito, ha ocasionado a la víctima.

Las principales diferencias entre uno y otro estatuto de responsabilidad se estudian al analizar la responsabilidad extracontractual. Por ahora, cabe preguntarse: ¿Qué reglas de responsabilidad se aplican a las obligaciones nacidas de la ley o de los cuasicontratos? En otras palabras, ¿cuál es la regla general en materia de responsabilidad: contractual o extracontractual?

Buena parte de la doctrina tradicional, fundada en los amplios términos del Título XII, “Del efecto de las obligaciones”, sin hacer distinción, estima que las normas de los arts. 1545 y siguientes constituyen el derecho común y general en materia de indemnización de perjuicios, aplicándose cualquiera sea el origen de la obligación incumplida, contractual, cuasicontractual, legal, etc. No se aplicarían, en cambio a los siguientes casos: a) cuando la ley ha dado reglas distintas, como ocurre con la responsabilidad extracontractual, proveniente de los delitos o cuasidelitos civiles, que trata especialmente esa materia en el Título 35 del Libro IV, artículos 2314 y siguientes; y b) cuando las partes se han dado reglas especiales, haciendo uso del principio de la autonomía de la voluntad. Ello con algunas limitaciones como la que les impide renunciar anticipadamente al dolo o a la culpa grave (arts. 1465 y 44 inc. 1º, parte final) (STITCHKIN, ALESSANDRI).

Sin embargo, tal conclusión es a lo menos cuestionable, si se considera que el Título “Del efecto de las obligaciones” discurre sobre la idea de una estipulación previa entre las partes (un contrato), sin considerar las obligaciones que surgen sin convención (legales, cuasicontractuales, delictuales y cuasidelictuales). Lo anterior se ve reforzado por el art. 2284, que precisamente distingue entre las obligaciones que se contraen con convención de las que se generan sin una, dando a entender que estas últimas tienen una naturaleza diversa de las obligaciones contractuales. En razón de lo anterior, resulta más adecuado que los arts. 1545 y siguientes, sobre responsabilidad contractual, únicamente se aplican a las obligaciones contractuales; en cambio las obligaciones que encuentran su origen en la ley, un cuasicontrato, un delito o un cuasidelito se encontrarán regidas por las normas dadas para la responsabilidad extracontractual, contenidas en el Título XXXV del Libro IV.

1.3. Sentido restringido y amplio de la responsabilidad contractual.

Tradicionalmente, gran parte de la doctrina entiende a la responsabilidad contractual en un *sentido restringido o estricto*, consistente en el deber u **obligación de indemnizar los perjuicios** causados por el incumplimiento del deudor; esto es, se asimila a la responsabilidad contractual a lo que usualmente se denomina “cumplimiento por equivalencia”. En este sentido, existe una íntima vinculación de la responsabilidad con un hecho ilícito, como es el incumplimiento de la obligación contractual imputable a dolo o culpa del deudor.

Ligado a lo anterior -entender la responsabilidad contractual como una sanción a un hecho ilícito-, la doctrina tradicional señala como fundamento de la obligación que la ley impone

de indemnizar el daño causado, la culpabilidad del deudor, esto es, la infracción dolosa o culposa del contrato, que le impone la necesidad de responder de su conducta. Para esta doctrina, que sustenta la **responsabilidad subjetiva o por culpa**, resulta esencial para que exista responsabilidad contractual el que el incumplimiento sea imputable a dolo o culpa del deudor.

Con todo, la doctrina nacional más moderna ha comenzado a abogar por un *sentido amplio*, que no agota a la responsabilidad contractual a la indemnización de perjuicios, sino que al **conjunto de derechos y acciones** (que también denominan “remedios”) en cuya virtud el acreedor puede reclamar la satisfacción de su interés contractual. De ahí que, de acuerdo a esta concepción amplia, la responsabilidad contractual no solo se refiere a acciones resarcitorias, sino que también comprende el derecho a obtener el cumplimiento en naturaleza (la prestación de lo debido) así como las acciones destinadas a conservar el patrimonio del deudor (tradicionalmente denominadas derechos auxiliares del acreedor).

Esta responsabilidad en sentido amplio en buena medida se vincula con una visión más objetiva de la responsabilidad, conforme a la cual su fundamento no es propiamente el obrar imputable a dolo o culpa

Recientemente, CÁRDENAS & REVECO han observado que “la idea de un sistema de acciones ante el incumplimiento no es ajena a nuestro sistema, puesto que [...] tradicionalmente la materia se ha estudiado de manera sistemática, clasificando los efectos según los diferentes tipos de incumplimientos y de contratos que admite nuestro derecho. Lo que es nuevo, estriba, por una parte, en la pretensión de que se prescinda de la imputabilidad del incumplimiento, de los efectos especiales de los diferentes tipos contractuales; y, por otra parte, en la pretensión de que la relación obligatoria sea comprendida como una garantía de resultado, aunque los extremos de esta afirmación no se alcanzan a comprender del todo bien”.

1.4. Análisis general del régimen de acciones o “remedios” ante el incumplimiento de un contrato.

Concebida la responsabilidad contractual en un sentido amplio, resulta pertinente analizar el régimen de acciones que la ley confiere al acreedor frente a un incumplimiento del contrato, cuyo estudio detallado se realizará en los siguientes capítulos.

Al respecto, y como es claro, en virtud del principio de autonomía de la voluntad **primeramente se deben aplicar la regulación particular contenida en el contrato**, en caso de haberla. Sobre este punto, se observará a lo largo de este capítulo que la ley le otorga amplia libertad a los contratantes para reglamentar las más variadas materias, como es el grado de diligencia con el deudor debe obrar, quién debe soportar los efectos de un caso fortuito, evaluar anticipadamente los perjuicios mediante una cláusula penal, establecer

multas por atrasos o incumplimientos, acordar pactos comisorios, convenir causales específicas de incumplimientos resolutorios, etc. Desde luego, dicha autonomía reconoce los límites generales a que se refieren los arts. 1461 y 1467 (a saber, el orden público, las buenas costumbres y la ley), así como límites particulares (v.gr. prohibición de condonar el dolo futuro).

Ahora bien, si las partes nada regularon sobre la materia, o bien si dicha regulación fue incompleta, será indispensable recurrir a las normas legales. Sobre la materia, es pertinente considerar que, no obstante su ubicación en el título sobre las condiciones, la **norma base y esencial** relativa a los efectos que produce el incumplimiento del deudor es el **art. 1489**, en cuanto consagra las acciones (o, más genéricamente, los “remedios”) con que cuenta el acreedor para obtener la satisfacción de su crédito.

En concreto, el **artículo 1489** se refiere a los efectos de las obligaciones, por cuanto establece los remedios con que cuenta el contratante diligente frente a un incumplimiento, confiriéndole al efecto los siguientes derechos:

- (a) **Derecho del acreedor a exigir el cumplimiento forzado de la obligación incumplida.** El art. 1489 señala que para el caso de *“no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado [...] podrá el otro contratante pedir a su arbitrio [...] el cumplimiento del contrato”*.

Así, el acreedor puede solicitar la ejecución forzada de la obligación, esto es, esto es, que el acreedor, con el auxilio de la fuerza, obtenga el cumplimiento en naturaleza o pago de la obligación incumplida, para lo cual, como veremos, la ley –civil y procesal- distingue entre las obligaciones de dar, hacer y no hacer.

En relación a este primer remedio contractual, cabe preguntarse si las partes podrían o no renunciar a la acción destinada a obtener el cumplimiento forzado de la obligación. No obstante una posición minoritaria –fundada genéricamente en la autonomía de la voluntad- afirma que tal renuncia es jurídicamente factible, la mayoría de los autores opina que no es posible renunciar a la acción de cumplimiento, por la sencilla razón de que, de hacerlo, de desnaturalizaría por completo la obligación, que por definición es un vínculo jurídico que impone un deber cuyo cumplimiento es susceptible de ser exigido por la fuerza. Visto desde otra perspectiva, la renuncia anticipada al derecho a pedir el cumplimiento daría cuanta de una manifestación de voluntad que no es realmente seria (y por tanto ineficaz), o bien tal pacto equivaldría a una condición meramente potestativa del deudor (pues pactar tal renuncia es lo mismo que convenir “cumpliré la obligación si quiero”), las que como vimos son nulas de conformidad al art. 1478.

Lo que se encuentra fuera de toda duda es que no se puede renunciar a demandar tanto la ejecución forzada como la resolución en el evento de infracción de obligación. Desde el momento que no se puede compeler al deudor a cumplir ni a sancionarlo por la infracción de la obligación, se produce una situación similar a la de la obligación contraída bajo la condición que consiste en la mera voluntad de la persona que se obliga. Es como decir “me obligo si quiero”, por lo que no se puede exigir el cumplimiento de la obligación ni demandar la resolución del contrato. Por ello la renuncia antedicha es ineficaz.

- (b) **Derecho del acreedor a solicitar la resolución –total o parcial- del contrato del cual emanaba la obligación incumplida.** El art. 1489 agrega que para el caso de “*no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado [...] podrá el otro contratante pedir a su arbitrio [...] la resolución [...] del contrato*”.

Esta norma consagra la comúnmente denominada *condición resolutoria tácita*, en cuya virtud se otorga al acreedor el derecho a exigir la resolución por incumplimiento.

A diferencia de lo que acontece con el derecho a cumplir el cumplimiento forzado de la obligación, la ley reconoce a las partes el derecho a renunciar anticipadamente a la acción resolutoria. Como es del todo obvio, tal renuncia no se traduce en que el incumplimiento quedará impune, sino que el acreedor tendrá siempre su derecho a pedir el cumplimiento forzado (que es irrenunciable) y/o la correspondiente indemnización de perjuicios. Así, la renuncia anticipada de la acción resolutoria en definitiva da cuenta del ánimo de las partes de que el contrato no se termine por el incumplimiento de una de ellas. Como sea, y por amplios que sean los términos en que hubiese sido pactada, jamás tal renuncia comprenderá el incumplimiento doloso, ya que ello equivaldría a condonar el dolo futuro, pacto que no vale por adolecer de objeto ilícito conforme al art. 1465.

Por su lado, cabe considerar que también se reconoce a las partes otorgarse una reglamentación contractual particular sobre la materia, por vía de convenir pactos comisorios y causales específicas de incumplimientos resolutorios.

- (c) **Derecho del acreedor a solicitar la indemnización de los perjuicios causados por el incumplimiento de la obligación.** Por último, se debe considerar que el art. 1489 dispone que para el caso de “*no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado [...] podrá el otro contratante pedir*” el cumplimiento o la resolución “*con indemnización de perjuicios*”.

La doctrina tradicional en general trata a la indemnización de perjuicios como un “cumplimiento por equivalencia”, atendido que el acreedor no obtendrá el pago de la obligación (esto es, la “prestación de lo que se debe”), sino que deberá ver

satisfecha su acreencia por una cantidad de dinero que equivaldría al cumplimiento en naturaleza. Como se verá, la doctrina moderna ha objetado el que la indemnización de perjuicios sea propiamente un “cumplimiento por equivalencia”.

Como se anticipó, y como se desarrollará más adelante, la ley le reconoce a las partes una amplia libertad para reglamentar los diversos aspectos de la indemnización de perjuicios entre otros el incumplimiento que la genera y los daños que deben resarcirse.

Es relevante considerar que **las acciones de cumplimiento y de resolución son incompatibles, pero pueden interponerse sucesivamente**. Por ello no pueden demandarse conjuntamente, a menos que lo sea en forma subsidiaria, pero nada obsta a que ejercida una se pueda ejercer posteriormente la otra si no se obtuvo (art. 17 del Código de Procedimiento Civil). Si el contratante diligente demanda el cumplimiento y no lo obtiene, mantiene su opción para demandar la resolución. Así lo entiende la doctrina.

Por otro lado, no está de más recordar que habitualmente la doctrina tradicional afirma que el cumplimiento forzado sería el *derecho principal* del acreedor, en circunstancias que la resolución y consecuente indemnización de perjuicios (compensatoria) sería un *derecho secundario*. Con todo, se objeta tal nomenclatura, pues no considera que de conformidad al art. 1489 **el acreedor puede optar “a su arbitrio”** por solicitar el cumplimiento (con indemnización moratoria) o la resolución (con indemnización compensatoria), sin que el Código establezca un orden de prelación entre ambos, sino que muy por el contrario, dejando en claro que se trata de un derecho optativo del acreedor.

Por otro lado, la ley, en su afán de proteger al acreedor, le otorga ciertos derechos destinados a la conservación del patrimonio del deudor, en razón de que será en ese patrimonio donde se hará exigible el cumplimiento, en virtud del derecho de prenda general establecido en el artículo 2465. Son los comúnmente denominados **derechos auxiliares**, destinados a mantener la integridad patrimonial del deudor (beneficio de separación, acción subrogatoria, acción pauliana, medidas conservativas).

Finalmente, conviene tener presente que **el incumplimiento de las obligaciones naturales, no producen los efectos** que vamos a estudiar, por cuanto su característica es justamente que no otorgan acción para exigir su cumplimiento (artículo 1470).

1.5. Sistema de atribución de responsabilidad. Objetivación de la responsabilidad contractual.

La doctrina tradicional entiende que el factor de atribución de responsabilidad contractual es de carácter **subjetivo**, en cuanto solo habrá lugar a la responsabilidad en la medida que se verifique un *incumplimiento imputable a dolo o culpa*.

Sin embargo, doctrina más reciente -destacando en nuestro medio BARAONA y PEÑAILILLO- señala que el análisis de la materia no se puede reducir al incumplimiento imputable, atendido que nuestro Código contiene normas que demostrarían que el principal factor de atribución de la responsabilidad es el **incumplimiento**, aun cuando no sea imputable, pues verificado el mismo -y no mediando un evento de fuerza mayor- igualmente el deudor se encuentra obligado a cumplir el contrato. Por tanto, verificado el incumplimiento, no obstante el mismo no pueda atribuirse a dolo o culpa del deudor, igualmente faculta al acreedor a solicitar el cumplimiento del contrato -o incluso su resolución-; pero sin tener derecho a una indemnización de perjuicios, pues ello sí presupone imputabilidad.

Al respecto, BARAONA observa que una comprensión objetiva de la responsabilidad contractual obligaba a admitir que en tanto no sobreviniera la imposibilidad no habría necesidad de indagar otra fuente de responsabilidad que no fuera la misma obligación, y concurriendo tal imposibilidad por causa no imputable al deudor, se extinguía la obligación quedando el deudor liberado.

En similares términos, PEÑAILILLO señala que el fundamento de la responsabilidad es la obligatoriedad del contrato, que ahora ha sido infringido. Se pide la ejecución de la prestación simplemente porque a eso se obligó el deudor. En tal eventualidad, es evidente que la culpa no tiene intervención; producido el incumplimiento, no se divisa razón para exigir *un nuevo requisito* más allá del contrato, a fin de que el acreedor pueda demandar la prestación convenida (por lo demás -y afortunadamente- no hay norma que lo exija). Entonces, demandada la prestación en especie, al acreedor le bastará simplemente *demostrar la existencia de la obligación*, correspondiendo al deudor la prueba del pago o de la extinción de la misma por cualquier otro de los medios mencionados en el art. 1567 del Cód. Civil (como lo consignan los arts. 438 del CPC y 1672 y 1698 del CC). Agrega este autor que mientras la obligación no se extinga la ejecución forzada es plenamente procedente, y el deudor no puede excepcionarse ofreciendo simplemente la prueba de la diligencia (o la ausencia de culpa); ella no está contemplada entre las causales de extinción de la obligación.

2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN COMO FACTOR DE ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.

El primer y elemental presupuesto para que el acreedor pueda ejercer cualquiera de los derechos que el contrato o la ley le otorga, es que exista un incumplimiento de la obligación por parte del deudor.

2.1. Causales de incumplimiento que la ley distingue.

Empleando los términos del art. 1556, hay incumplimiento en tres casos:

- (i) cuando la obligación no se cumple;
- (ii) cuando la obligación se cumple imperfectamente; o
- (iii) cuando se retarda el cumplimiento de la obligación.

Dicho de otra manera, cuando se falta íntegramente al pago, o se infringe alguno de los requisitos de éste. En otras palabras, cada vez que no se verifique un pago íntegro y oportuno -la “prestación de lo que se debe”-, entonces se estará en presencia de un incumplimiento, que en rigor es un concepto de carácter objetivo. El hecho que tal incumplimiento obedezca a un obrar doloso o negligente del deudor, otorgará el derecho al acreedor a pedir -además del cumplimiento o la resolución- la indemnización de perjuicios, si la infracción efectivamente causó un daño (o bien se estipuló una cláusula penal al efecto).

De lo que se viene diciendo, aparece que **el incumplimiento puede ser total o parcial**. El incumplimiento es total si no se ejecuta la obligación en todas sus partes. Y es parcial en los dos casos del art. 1556: (i) si la obligación se cumple imperfectamente, o sea, no se paga en forma íntegra (v.gr., como si de una deuda de \$10.000 el acreedor acepta un abono de \$5.000; si se paga la deuda, pero no los intereses; si el edificio tenía defectos de construcción, etc.); el acreedor debe haber aceptado este cumplimiento imperfecto, porque no está obligado a recibir un pago que no sea íntegro. Si rechaza el cumplimiento incompleto habrá lisa y llanamente incumplimiento total, y; (ii) cuando existe retardo en el cumplimiento, o sea, la obligación no se ha cumplido en su oportunidad.

2.2. Casos en que el incumplimiento no da lugar a responsabilidad contractual.

No necesariamente cada vez que se verifique un incumplimiento habrá lugar a la responsabilidad contractual. En efecto, puede suceder que:

- a) El deudor puede dejar de cumplir por un acuerdo con el acreedor, esto es, aceptando éste el incumplimiento, por lo cual no hay responsabilidad ulterior para el deudor; así ocurrirá si opera una remisión, una transacción o una novación, aunque ésta, equivale al cumplimiento.
- b) El deudor no cumple, pero se justifica para así hacerlo en que a su turno el acreedor tampoco ha cumplido alguna obligación suya; así ocurre, por ejemplo, en la denominada excepción del contrato no cumplido que se analizará más adelante.
- c) El deudor deja de cumplir, porque ha operado algún modo de extinguir liberatorio para él, ya sea que destruyó el vínculo jurídico o puso término a la obligación nacida de él: prescripción, nulidad.

- d) En fin, puede acontecer que tenga lugar alguna causal de exclusión de responsabilidad, que se analizarán en un capítulo posterior. La principal causal de exclusión es el caso fortuito o fuerza mayor, caso en el cual la obligación se extinguirá sin ulterior responsabilidad para el deudor, o la cumplirá eliminando el obstáculo, pero sin que responda por el retardo.

2.3. Incumplimiento del contrato y distinción entre obligaciones de medio y de resultado.

A efectos de analizar el incumplimiento de un contrato, y particularmente las eventuales causales de exención de responsabilidad, adquiere relevancia la distinción doctrinal entre obligaciones de medios y de resultado.

Como se analizó a propósito de la clasificación de las obligaciones, se dice que son obligaciones de medio *de medio* aquellas en que el deudor se compromete únicamente a realizar todo lo posible y necesario, poniendo para ello la suficiente diligencia, para alcanzar un resultado determinado; en cambio, son obligaciones *de resultado* aquellas otras en que el deudor para cumplir debe alcanzar el resultado propuesto.

Se ha observado que en las obligaciones de medio la diligencia cumpliría una función *integradora* de la prestación -como acontece, por ejemplo, en las labores que desarrolla un abogado en el juicio-, de modo que, en el evento de que no obstante se hubiese obrado con la debida diligencia no se hubiese alcanzado el resultado deseado -en el ejemplo, ganar el juicio-, no se configura una responsabilidad. De ahí que se afirme que, respecto de estas obligaciones de medio, la ausencia de culpa configura una causal de exención de responsabilidad.

En cambio, todo lo contrario acontecería en las obligaciones de resultado, en las que, para determinar el incumplimiento, y la consecuente responsabilidad, la culpa no sería un elemento a considerar. En estos casos, el deudor únicamente se podría exonerar acreditando la existencia de un evento de fuerza mayor que le imposibilitó ejecutar la obligación debida, no siendo procedente invocar la ausencia de culpa como causal de exención de responsabilidad.

Sobre la materia, cabe recordar que no existe consenso doctrinal en torno a esta clasificación. Primeramente, mientras algunos autores estiman que una obligación tendrá uno u otro carácter dependiendo de la descripción de la obligación contenida en la ley o en el contrato, otros estiman que en rigor todas las obligaciones son de medio (por lo que siempre se podría alegar la ausencia de culpa como causal de exoneración de responsabilidad); y en el otro extremo, hay quienes afirman que en rigor toda obligación es de resultado. En segundo lugar, entre quienes admiten esta clasificación, hay quienes sostienen que únicamente se

puede predicar respecto de las obligaciones de hacer, mientras otros señalan que también cabe esta distinción en las obligaciones de dar, e incluso en las de no hacer.

2.4. Prueba del incumplimiento y presunción de imputabilidad

De acuerdo al art. 1698, corresponde probar la obligación o su extinción al que alega aquélla o ésta.

En consecuencia, si al acreedor le corresponde acreditar la existencia de la obligación, no le toca, en cambio, probar el incumplimiento. Es el deudor quien debe establecer que ha cumplido, porque alega el pago, o sea, la extinción de la obligación y sobre él coloca la ley la carga de la prueba en tal caso.

Pero aún más, si el deudor no ha cumplido, deberá probar, si quiere quedar exento de responsabilidad, que el incumplimiento no le es imputable. Porque el deudor se defenderá de la demanda del acreedor que le exige el cumplimiento o la indemnización de perjuicios, alegando que ha operado algún modo extintivo de la obligación liberatorio para él. Según la regla general del art. 1698, deberá probarlo.

Si lo que alega es la imposibilidad en el cumplimiento por caso fortuito, él debe acreditar que ha concurrido dicho modo de extinguir, estableciendo la concurrencia de la fuerza mayor. No sólo porque así resulta de la regla del art. 1698 citada, sino porque lo dispone expresamente el inc. 3º del art. 1547: “la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega”.

Si debe probar la diligencia quien debió emplearla, ello equivale a presumir la culpa, y la conclusión es que el deudor debe destruir la presunción legal de imputabilidad.

IV.

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

1. NOCIONES GENERALES.

El derecho del acreedor de exigir el pago de la obligación y el cumplimiento del contrato es sin duda una cuestión evidente, y connatural a la noción misma de obligación jurídica: las obligaciones se asumen para ser cumplidas, por lo que su infracción lógicamente otorga al acreedor el derecho a exigir su cumplimiento o pago. Precisamente en razón de ello es que de conformidad al art. 1489, ante el evento de un incumplimiento, el acreedor tiene el derecho de instar por el cumplimiento. Para tales efectos, y considerando que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, el acreedor debe recurrir al juez para reclamar el cumplimiento de la obligación, de modo que el deudor sea compelido por la autoridad de la justicia a pagar lo que debe.

No obstante la evidente trascendencia de la acción de cumplimiento, lo cierto es que llamativamente -y salvo excepciones- la doctrina nacional no ha desarrollado mayormente el estudio de la acción de cumplimiento, limitándose en general a analizar el cumplimiento *forzado*, focalizando el análisis en la distinción del cumplimiento de obligaciones de dar, hacer (art. 1553) y no hacer (art. 1555) y en los requisitos para iniciar un *juicio ejecutivo*, materia mayormente regulada en el Código de Procedimiento Civil.

Con todo, la materia es más amplia y requiere un análisis relativo a diversos aspectos, que van desde el objeto mismo de la acción de cumplimiento a los requisitos de su procedencia, en orden a si es o no necesario que el incumplimiento sea imputable, entre otros temas. De los trabajos recientes de la doctrina nacional que analiza con mayor amplitud la acción de cumplimiento es el de CÁRDENAS y REVECO, a quienes seguiremos en varios pasajes de este capítulo.

2. CONCEPTO DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO.

La acción de cumplimiento es aquella de que dispone el acreedor insatisfecho, una vez acontecido el incumplimiento, para que se declare la existencia y exigibilidad de una obligación y se condene al deudor a su pago. En términos simples, la acción de cumplimiento es aquella destinada a **obtener directamente que el deudor sea condenado al cumplimiento de la obligación.**

En general, se le denomina **acción de cumplimiento específico**, en cuanto su función es obtener **forzadamente** el pago, esto es, la **prestación de lo que se debe.**

3. EN CUANTO A SI LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO ES EL “DERECHO PRINCIPAL” DEL ACREEDOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO.

Como se indicó con anterioridad, la doctrina tradicional afirma habitualmente que el cumplimiento específico como el derecho principal del acreedor frente al incumplimiento contractual, concediéndosele un lugar preponderante entre las diversas acciones de que dispone el acreedor, haciendo primar el cumplimiento en naturaleza sobre las otras acciones. Así CLARO SOLAR sostuvo que la ley permite al acreedor “[...] adoptar la determinación que más le convenga en el momento en que se realiza la condición resolutoria; pero lógicamente, y en la generalidad de los casos naturalmente también, no se ha de recurrir a la resolución, cuando la ejecución del contrato es aún posible; pues los contratos se hacen para cumplirlos, no para resolverlos; y es del contrato del que nace la obligación de exigir su cumplimiento, así como la acción resolutoria nace de la realización de la condición, de la falta de cumplimiento de la obligación en el lugar y tiempo señalados. Sin embargo, como se verá, existen voces disidentes sobre dicha primacía.

En algunas jurisdicciones del derecho comparado también se ha fundamentado la primacía de la acción de cumplimiento sobre la base de otros argumentos. Así, desde un punto de vista ético, se ha sostenido que el reconocimiento de la acción de cumplimiento es disuasivo del incumplimiento, incentivando el comportamiento virtuoso o de buena fe de los contratantes. Por otro lado, desde un punto de vista económico y social, la acción de cumplimiento es el remedio que mayor seguridad jurídica confiere al tráfico jurídico, reforzando la certeza del contrato y, en consecuencia, protegiendo la confianza depositada.

Con todo, la primacía de la acción de cumplimiento ha sido cuestionada por un sector de la doctrina contemporánea. Las críticas provienen de autores que consideran que el acreedor insatisfecho cuenta con una batería de acciones que le permiten remediar su situación dependiendo de su interés específico.

Tal postura encuentra asidero a nivel normativo, atendido que el art. 1489, lejos de distinguir entre derechos “principales” y “secundarios”, expresamente indica que ante el incumplimiento el acreedor tiene la opción de pedir el cumplimiento o la resolución, y en uno y otro caso con indemnización de perjuicios. Tal opción la ejercita el acreedor “a su arbitrio”, y por tanto no tiene que justificar su decisión ni procede cotejar las consecuencias de la alternativa elegida con las de la abandonada para enjuiciarla y deducir alguna limitación.

4. OBJETO DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO. CUMPLIMIENTO EN “NATURALEZA” Y “POR EQUIVALENCIA”.

De conformidad a las normas que regulan la acción de cumplimiento, resulta evidente que el primer -y podríamos primordial- objeto de la misma es el **cumplimiento en naturaleza, en especie o in natura**. En tal caso lo que se pide es propiamente el **pago**, la “prestación de lo que se debe”, sea este un dar, hacer o no hacer.

Sobre lo anterior no existe duda alguna. En lo que sí existe algún mayor grado de controversia es en el hecho de si también es objeto de esta acción el **valor o precio de lo adeudado** (*aestimatio rei*), esto es, el **“cumplimiento por equivalencia”**.

Tradicionalmente, la doctrina nacional ha identificado el “cumplimiento por equivalencia” con la indemnización de perjuicios, tratándolo como términos sinónimos. Sin embargo, doctrina nacional más reciente han objetado tal identificación, por los motivos que se pasan a reseñar.

Sobre la materia, PEÑAILILLO afirma que debe distinguirse entre el cumplimiento por equivalencia y la indemnización de perjuicios. El primero tiene lugar cuando, estando vigente la obligación, ya no es posible (o útil) el cumplimiento específico; en esta alternativa la obligación subsiste pero varía de objeto, y el deudor es obligado a pagar el “precio” (o valor) de la prestación incumplida. La indemnización de perjuicios (o daños ulteriores) ya no persigue el valor de la prestación incumplida, sino que resarcir los perjuicios que, más allá de la cosa o prestación no ejecutada, se causaron al acreedor por el incumplimiento.

A lo anterior BARAONA agrega si se revisa el contenido de los daños y perjuicios a que puede ser condenado el deudor, puede concluirse que no necesariamente coinciden con lo que podría denominarse el valor de la prestación, pues el artículo 1556 se refiere al daño emergente y al lucro cesante, y por mucho que se quiera hacer coincidir la expresión daño emergente con el valor de la prestación, el lucro cesante no puede ser reconducido a esa idea. Por otra parte, tal contenido de los daños no sólo es aplicable a los perjuicios que se originan con la infracción por ausencia total de cumplimiento, sino también para el defectuoso y la ejecución retrasada, lo que permite concluir que las expresiones son universales a cualquier pretensión de daños de origen contractual.

Lo cierto es que existen una serie de normas del Código Civil que claramente distinguen entre el valor o precio de la cosa, de la indemnización de perjuicios. Entre ellas caben mencionar:

- (i) el art. 1672, sobre la pérdida de la cosa que se debe, señala que si el cuerpo cierto adeudado perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación subsiste, pero varía de objeto (efecto que se denomina *perpetuatio obligationis*), agregando

que en tal caso “el deudor es obligado al *precio* de la cosa y a indemnizar al acreedor”;

- (ii) el art. 1486.1 dispone que si antes del cumplimiento de la condición la cosa prometida perece por culpa del deudor, este es obligado “al *precio*, y a la indemnización de perjuicios”;
- (iii) más elocuente es la distinción que realiza el art. 1521, relativa a las obligaciones solidarias, conforme al cual si la cosa perece por culpa o durante la mora de uno de los codeudores solidarios, “todos ellos quedan obligados solidariamente al *precio* [...] Pero la acción de *perjuicios* a que diere lugar la culpa o mora, no podrá intentarla el acreedor sino contra el deudor culpable o moroso”.

Cabe observar que el Código de Procedimiento Civil también asimila ambas clases de cumplimiento –“en naturaleza” y “por equivalencia”-, pues su art. 438 señala que la “ejecución puede recaer 1° Sobre la *especie* o cuerpo cierto que se deba y que exista en poder del deudor; 2° Sobre el *valor* de la especie debida y que no exista en poder del deudor [...]”.

Desde luego, el que se entienda que la acción de “cumplimiento por equivalencia” es propiamente de cumplimiento -y no de indemnización de perjuicios, es de gran relevancia, pues -siguiendo la misma doctrina moderna- para su procedencia **no es necesaria la concurrencia de dolo o culpa del deudor, sino que basta que objetivamente la obligación contractual se haya incumplido total o parcialmente.**

Al decir de PEÑAILILLO, si se demanda el llamado cumplimiento por equivalencia, entonces se está tratando el *valor* de la prestación; por lo mismo, no se requiere culpa del deudor. El fundamento está en el **incumplimiento contractual**. En otros términos, el régimen por el que se rige el cumplimiento por equivalencia es el mismo del cumplimiento en especie; es natural que así sea pues, como lo manifiesta la expresión, se trata ahora de que el deudor pague lo que la prestación “vale”.

En términos similares, BARAONA observa que la pretensión por la *aestimatio rei* como acción de cumplimiento no indemnizatoria, y la distinción entre el valor de la prestación y los perjuicios causados en el cumplimiento, permiten separar dos conceptos básicos en materia de responsabilidad: lo que se debe porque se ha obligado (el valor económico de la obligación), y lo que se debe *ex novo*, porque se ha causado daño con ocasión del cumplimiento/incumplimiento de la obligación (los daños y perjuicios propiamente obligacionales).

5. PRESUPUESTOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En términos generales, los presupuestos de procedencia de la acción de cumplimiento son fundamentalmente dos: que exista una obligación exigible y que la misma se haya incumplido.

Al respecto, se observa que, para que la acción prospere, no hay que acreditar daño, ni necesariamente culpa o dolo, pudiendo realizarse la imputación en forma objetiva.

Aún más, atendido el tenor del artículo 1698 CC Ch, bastaría con que el acreedor acredite la existencia de la obligación, teniendo el deudor la carga de probar su extinción, ya sea por pago -esto es, cumplimiento- o por otro modo. Respecto a la exigibilidad, en tanto la regla general es que una obligación sea pura y simple, bastará con la prueba de su existencia, presumiéndose, salvo pacto expreso o prueba en contrario, que es actualmente exigible.

6. CUMPLIMIENTO Y “EJECUCIÓN FORZADA” DE OBLIGACIONES DE DAR, HACER Y NO HACER.

Como se señaló, la doctrina predominante, al analizar el cumplimiento, ha atendido fundamentalmente a la etapa ejecutiva de la acción de cumplimiento, pues el “cumplimiento forzado” o “ejecución forzada” se obtiene mediante un procedimiento de apremio en que no se discute acerca de la existencia de la obligación, sino que esta se da por indubitada y se compele al deudor, incluso por la fuerza al pago.

No obstante, lo anterior, no se duda de que, en nuestro ordenamiento jurídico, el acreedor dispone de la acción de cumplimiento, aun cuando no disponga de un título ejecutivo. Si no dispone de un título ejecutivo, deberá iniciar un juicio de lato conocimiento, solicitando se declare la existencia y exigibilidad de la obligación incumplida. La eventual sentencia definitiva favorable, en la medida en que esté firme o cause ejecutoria, constituirá el título ejecutivo en base al cual el acreedor podrá hacer efectivo su crédito en el patrimonio del deudor.

La acción de cumplimiento específico persigue, en términos simples, el pago íntegro de la obligación. Ello implica la necesidad de una sentencia que declare la existencia de la obligación y condene al deudor a cumplir con ella. Posteriormente, en tanto la sentencia sea favorable y se encuentre firme o cause ejecutoria, se da lugar a la fase de ejecución, la que se inicia mediante el ejercicio de la denominada acción de cumplimiento forzado, que ciertamente está comprendida en el concepto más amplio de acción de cumplimiento. Par la fase de ejecución, el acreedor puede optar entre interponer la acción mediante un procedimiento incidental de ejecución o mediante un juicio ejecutivo.

Como se observa, la satisfacción plena de la acción de cumplimiento implica dos fases, a saber, una declarativa, en que se discute acerca de la existencia y exigibilidad de la obligación y otra de ejecución, que presupone una obligación indubitada, a cuyo cumplimiento se compele incluso por la fuerza. Con todo, el mismo legislador contempla ciertos instrumentos (además de la sentencia definitiva o interlocutoria firme o aquella que causa ejecutoria), a los que atribuye mérito ejecutivo, pudiendo el acreedor, en la medida en que disponga de uno de ellos, iniciar inmediatamente la fase de ejecución. Estos son típicamente los títulos ejecutivos.

El Código de Procedimiento Civil regula los llamados “juicios ejecutivos”, que, a diferencia del juicio ordinario, constituye un procedimiento más expedito para que el acreedor pueda demandar la ejecución forzada. Para ello requiere de un “título ejecutivo”, esto es, un documento que deje constancia de la obligación en forma indubitable. Si el acreedor carece de un título ejecutivo, y no logra obtenerlo mediante las denominadas gestiones preparatorias de la vía ejecutiva (por ejemplo, el reconocimiento de firma o la confesión de deuda), sólo le queda iniciar un juicio ordinario de lato conocimiento, cuya sentencia podrá servir de título ejecutivo.

Expuesto lo anterior, debe considerarse que lo que se va a exigir forzosamente no es de una misma naturaleza, pues va a depender del tipo de obligación, debiendo distinguirse entre: a) obligación de dar; b) obligación de hacer; y d) obligación de no hacer.

6.1. Cumplimiento forzado de obligaciones de dar.

Si la obligación es de pagar una suma de dinero, que será lo más corriente, el acreedor se dirigirá directamente sobre el dinero para hacerse pago con él, o bien sobre los bienes del deudor, para realizarlos y pagarse con el producto de la venta; si la obligación es de dar una especie o cuerpo cierto y ésta se encuentra en poder del deudor, la ejecución forzada se dirigirá a obtener la entrega de esa especie, o al pago de la indemnización si ello no es posible.

El procedimiento ejecutivo está establecido en el título I del Libro III del Código de Procedimiento Civil (arts. 434 a 530).

Para que proceda la ejecución forzada se requiere, en síntesis:

a) **Que la obligación conste en un título ejecutivo.** Por título ejecutivo se entiende un documento que da constancia fehaciente de la existencia de una obligación entre las partes y al cual la ley le atribuye mérito ejecutivo, es decir, idoneidad para exigir el cumplimiento forzado de la obligación que en él se consigna. Los principales títulos ejecutivos se encuentran enumerados en el art. 434 del CPC, que menciona, entre otros, las sentencias y

las escrituras públicas. El carácter ejecutivo lo da la ley, y por ello las partes no pueden darle carácter de ejecutivo a un título que como tal la ley no reconoce (art. 434 N° 7 del CPC).

b) **Que la obligación sea actualmente exigible.** Ello significa que al momento de interponerse la acción ejecutiva, la obligación no debe estar sujeta a plazo ni a condición pendiente que suspenda su exigibilidad.

c) **Que la obligación sea líquida o que pueda liquidarse** mediante simples operaciones aritméticas, con sólo los datos que el mismo título ejecutivo suministre, y

d) **Que la acción ejecutiva no se encuentre prescrita.** La acción ejecutiva prescribe en tres años; cumplidos ellos, la acción ejecutiva se convierte en ordinaria y dura otros dos (art. 2515).

Si no se reúnen estos requisitos, se deberá demandar en juicio declarativo y obtener una sentencia que una vez firme servirá de título ejecutivo (art. 434 N° 1 del Código de Procedimiento Civil).

6.2. Cumplimiento forzado de obligaciones de hacer.

El cumplimiento forzado de una obligación de hacer presenta más dificultades, pues es difícil obligar a un deudor a que realice satisfactoriamente el hecho debido. Sólo será posible tratándose de hechos que puedan ser ejecutados por otra persona. Por ello, es que el artículo 1553 autoriza al acreedor para demandar directamente el pago de la indemnización de perjuicios.

En conformidad al artículo 1553 del Código Civil, si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, el acreedor podrá pedir, junto con la indemnización de perjuicios por la mora, cualquiera de estas tres cosas a elección suya:

- i. que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido;
- ii. que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor; y
- iii. que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato.

El procedimiento ejecutivo está establecido en el título II del Libro III del Código de Procedimiento Civil (arts. 530 a 544). Para que proceda es necesario que exista un título ejecutivo; que la obligación esté determinada; que sea actualmente exigible y que la acción ejecutiva no se encuentre prescrita

Si el acreedor demanda indemnización de perjuicios tendrá que hacerlo en juicio declarativo, pues el valor de lo demandado no puede constar en el título. Se requiere de una sentencia firme que resuelva previamente la existencia y monto de los perjuicios. Ejecutoriada la sentencia que se dicte, quedará constituido el correspondiente título ejecutivo.

6.3. Cumplimiento forzado de obligaciones de no hacer.

La materia se encuentra regulada en el art. 1555. El procedimiento ejecutivo está establecido en el Título II de Libro III del Código de Procedimiento Civil.

La obligación de no hacer se infringe en los casos en los que se hace lo que no debió hacerse. La ejecución forzada (esto es, cumplimiento de la obligación de no hacer) sólo procede cuando puede destruirse lo hecho y siempre que la destrucción sea necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de contratar. En tal evento, será el deudor obligado a la destrucción (que es una obligación de hacer), o autorizado el acreedor para que la lleve a efecto a expensas del deudor (art. 1555 inc. 2º).

En caso contrario (imposibilidad de destrucción o no siendo esta necesaria para lograr el objeto del contrato) la contravención hace responsable al deudor de la indemnización de perjuicios (art. 1555, inc. 1º).

Ahora bien, si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane a prestarlo.

El inciso final del art. 1555 agrega que “El acreedor quedará de todos modos indemne”. Ello significa que cualquiera que fuera la solución que se dé a la infracción de la obligación de no hacer, el acreedor ha de quedar de todos modos libre de daño o perjuicio.

7. LÍMITES A LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En general, se entiende que la *imposibilidad de la prestación*, física o jurídica, constituye un límite a la acción de cumplimiento.

La imposibilidad *física* atiende a la naturaleza del objeto, como una especie o cuerpo cierto que es destruida o perdida; mientras que la imposibilidad *jurídica* se refiere a alguna norma que prohíbe cumplir con la obligación, o a una orden de una autoridad competente, como una resolución judicial o decreto administrativo.

Por otra parte, según el momento a partir del cual pueda predicarse la imposibilidad, esta puede ser originaria o sobrevenida. Asimismo, según si la prestación es imposible, total o

parcialmente, la imposibilidad es, respectivamente, absoluta o relativa. Y finalmente, según el ámbito temporal de la imposibilidad, esta puede ser definitiva o transitoria.

En Chile, para que la imposibilidad extinga las obligaciones, debe ser física o jurídica, sobrevenida, absoluta y definitiva.

Si, en cambio, la imposibilidad es *originaria*, se configurará una hipótesis de falta de objeto en base al artículo 1461. Asimismo, si es *relativa*, la obligación debe cumplirse en los términos en que sea posible, salvo que se trate de una obligación de especie o cuerpo cierto y la imposibilidad relativa consista en la destrucción de la aptitud de la cosa para la finalidad a que según su naturaleza o la convención se destina, pues, en tal caso, la cosa se entiende absolutamente destruida (art. 1486, inciso final). Finalmente, si la imposibilidad es *transitoria*, simplemente permitirá que el deudor suspenda la ejecución de la prestación mientras subsista el impedimento, salvo que la prestación haya debido ejecutarse dentro de determinado plazo y el impedimento haya subsistido hasta su expiración, pues, en tal supuesto, la imposibilidad se entenderá definitiva.

Como sea, si la imposibilidad está sustentada en un caso fortuito o fuerza mayor, se configurará el modo de extinguir “pérdida de la cosa debida”, contemplado en los artículos 1670 y siguientes, que, si bien es aplicable únicamente a obligaciones de especie o cuerpo cierto, trasunta el principio general de que nadie está obligado a lo imposible. Por ende, tratándose de obligaciones de hacer o no hacer, aún cuando no exista norma expresa, es evidente la existencia de imposibilidad como modo de extinguir las obligaciones.

V.

RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Una segunda acción o “remedio” que se confiere al acreedor consiste en el derecho de solicitar la resolución del contrato incumplido. Tal derecho es otorgado directamente por la ley en virtud de la denominada *condición resolutoria tácita*, que es aquella que va envuelta en todo contrato bilateral para el evento de no cumplirse lo convenido; o bien puede ser ejercido en base a una estipulación contractual denominada *pacto comisorio*, que, en términos simples, es la condición resolutoria tácita expresada.

Tradicionalmente, y fundamentalmente a raíz de la ubicación del art. 1489 en el título de las obligaciones condicionales, la doctrina analiza los efectos de la condición resolutoria tácita y del pacto comisorio a propósito del estudio de la condición resolutoria general. Con todo, más allá de su ubicación, lo cierto es que el art. 1489 es la principal norma que establece los derechos del acreedor ante el incumplimiento, por lo que, a nuestro entender, resulta más adecuado analizarlo a propósito de la responsabilidad contractual, particularmente si se tiene una noción amplia de la misma, no limitada a la indemnización de perjuicios, sino que comprensiva de la reacción del ordenamiento jurídico ante el incumplimiento del contrato.

V.A.

LA CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA

1. CONSIDERACIONES GENERALES.

El artículo 1489 establece que *“En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios.”*.

Esta norma, inspirada en el art. 1184 del *Code*, regula lo que la doctrina tradicional denomina la “condición resolutoria tácita”, la que en términos generales consiste en el hecho futuro e incierto consistente en el incumplimiento de alguna de las obligaciones generadas por un contrato bilateral.

Con todo, la doctrina moderna y la gran mayoría de los Códigos Civiles del siglo XX han abandonado tal nomenclatura y concepción, por cuanto se sostiene que, más que una condición propiamente tal, se trata de un remedio frente a una infracción del contrato: la **resolución por incumplimiento**. Y se agrega que en cuanto tal el art. 1489 no debiera encontrarse en el título sobre las condiciones, sino que en el título XII del Libro IV,

correspondiente a los **efectos de las obligaciones**. En otras palabras, no sería correcto hablar de “condición resolutoria tácita”, sino que de “resolución por incumplimiento, por cuanto no es acertado considerar la facultad de resolver como una condición, sino que es un remedio frente al incumplimiento.

En relación a lo anterior, PEÑAILILLO bien apunta que el art. 1489 abarca: (i) un *tema substantivo*, como es la resolución del contrato por incumplimiento; y (ii) la *forma* que adopta tal regulación es la de una condición tácita. La “forma” adoptada por el Código no sería correcta, entre otras cosas, porque a diferencia de las condiciones propiamente tales la resolución por incumplimiento no opera de pleno derecho; a ello cabe agregar que cumplida la condición (esto es, generado el incumplimiento) se otorga al acreedor la alternativa de solicitar el cumplimiento del contrato, nota que también la distingue de las condiciones propiamente tales.

2. CONCEPTO.

ABELIUK define la condición resolutoria tácita como “aquella que va envuelta en todo contrato bilateral, y en que el hecho futuro e incierto que puede provocar la extinción del derecho de una de las partes es el incumplimiento de sus obligaciones”. Agrega, que la condición resolutoria tácita se funda en la falta de cumplimiento del deudor.

El incumplimiento de una obligación en un contrato bilateral, da a la otra parte un derecho alternativo para solicitar o el cumplimiento o la resolución, y en ambos casos, con indemnización de perjuicios.

3. FUNDAMENTO DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA.

Se dan diversas explicaciones: equidad; voluntad presunta de las partes; falta de causa; interdependencia de las prestaciones en un contrato bilateral, forma de indemnizar los perjuicios derivados del incumplimiento, etc.

Es evidente la razón de equidad y justicia que hay en que si una de las partes no cumple su obligación en un contrato bilateral, la otra pueda a su vez desligarse del vínculo jurídico, dejando sin efecto el contrato.

Se dice también que el legislador interpreta la voluntad presunta de las partes, pues parece lógico concluir que el contratante diligente no desea seguir ligado con quien no ha cumplido su obligación, y esta intención ha estado presente al otorgarse el contrato.

Según algunos el fundamento de la condición resolutoria tácita estaría en el hecho de que si en un contrato bilateral una de las partes no cumple con sus obligaciones, la obligación del otro contratante carecería de causa. Así lo sostienen CAPITANT y sus seguidores. Sin

embargo, se argumenta en contra de esta opinión señalándose que de faltar la causa, el contrato sería nulo, por lo que el contratante diligente no podría pedir el cumplimiento. Si lo puede hacer -y el artículo 1489 le da esa opción- es porque la obligación tiene causa. La verdad es que nada tiene que ver el incumplimiento de una de las partes, con la existencia de la causa. El requisito de la causa debe verse al momento en que el contrato se celebró, y a ese momento la causa existía, pues ambas partes contrajeron obligaciones recíprocas. El incumplimiento posterior no hace desaparecer la causa (en este sentido los hermanos MAZEAUD).

También se ha dicho que la resolución sería una consecuencia de la interdependencia de las obligaciones nacidas del contrato sinalagmático. Sin embargo, como acotan los MAZEAUD, “esta explicación carece de precisión y no da cuenta de las diferencias que separan la resolución y la teoría de los riesgos”.

Los MAZEAUD concluyen que “en realidad, la resolución judicial es un modo de reparación del perjuicio que causa al acreedor el incumplimiento de la obligación del deudor”. Según estos autores “al dispensarle al acreedor de cumplir con su propia obligación, o al permitirle recuperar la prestación por él efectuada, la resolución se presenta como un modo de reparación de mayor eficacia...”.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA (EN CUANTO CONDICIÓN).

Entendiéndola como una condición, se afirma que la condición resolutoria tácita detenta las siguientes características:

- a. Es un tipo de condición *resolutoria*, ya que tiene por objeto extinguir una obligación;
- b. Es *tácita*, puesto que el legislador la subentiende en todo contrato bilateral. Por ello es un elemento de la naturaleza y, por lo mismo, renunciable;
- c. Es *negativa*: consiste en que no ocurra un hecho, que una de las partes no cumpla su obligación;
- d. Es *simplemente potestativa*, pues depende de un hecho voluntario del deudor.
- e. *No opera de pleno derecho*, sino que requiere de declaración judicial.

De lo anterior aparecen las **diferencias entre la condición resolutoria ordinaria y la condición resolutoria tácita**, a saber:

- a) En la condición resolutoria *tácita*, el hecho futuro e incierto, es el incumplimiento de una obligación en un contrato bilateral; en la condición resolutoria *ordinaria*, cualquier hecho futuro e incierto que no sea el incumplimiento de una obligación en un contrato bilateral;
- b) La condición resolutoria *ordinaria* opera de pleno derecho; la *tácita* requiere de declaración judicial;
- c) La condición resolutoria *ordinaria* requiere de una manifestación expresa de voluntad; la *tácita*, es subentendida por la ley en todo contrato bilateral;
- d) La condición resolutoria *tácita* sólo opera en los contratos bilaterales (opinión mayoritaria); la *ordinaria* se puede establecer en cualquier negocio jurídico;

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA.

5.1. En cuanto a si se aplica exclusivamente a los contratos bilaterales, o también tiene aplicación respecto de los contratos unilaterales.

El art. 1489 expresamente indica que en los *contratos bilaterales* va envuelta la condición resolutoria tácita, motivo por el cual buena parte de la doctrina estima que la resolución por incumplimiento únicamente opera respecto de tal clase de contratos, y no respecto de los contratos unilaterales; al punto de sostener que un requisito para que opere la condición resolutoria tácita es que el contrato sea bilateral (STITCHKIN, ALESSANDRI, ABELIUK).

Sin embargo, el tema no es pacífico en nuestra doctrina. CLARO SOLAR es de la opinión de que sí opera aun en los contratos unilaterales, fundado en las siguientes razones:

- a) El artículo 1489 sólo dice que la condición resolutoria tácita va envuelta en los contratos bilaterales, pero no excluye la posibilidad de que también pueda darse en los unilaterales;
- b) Varias disposiciones demuestran que el Código Civil no ha entendido restringida la condición resolutoria tácita exclusivamente a los contratos bilaterales. Así, por ejemplo, en el comodato, no obstante ser contrato unilateral, se otorga al comodante la facultad de solicitar la restitución de la cosa prestada aun antes del vencimiento del plazo, cuando el comodatario no la destina al uso convenido (artículo 2177). En el contrato de renta vitalicia - también contrato unilateral- la ley ha tenido que señalar en forma expresa que “el acreedor no podrá pedir la rescisión (entiéndase resolución) del contrato en caso de no pagársele la pensión...” (artículo 2271). En el contrato de prenda -artículo 2396- en que el deudor puede pedir restitución inmediata de la cosa empeñada si el acreedor abusa de ella.

La tesis de CLARO SOLAR no ha encontrado mayor acogida en nuestra doctrina. Las razones que se dan son, en síntesis, las siguientes:

- a) El propio tenor literal del artículo 1489, que habla de “contratos bilaterales”;
- b) Tratándose de los contratos unilaterales, el Código ha ido resolviendo en cada caso particular, lo que ocurre cuando el deudor no cumple. Esa es la explicación de los artículos 2177, 2271 y 2396. En cambio, nada ha dicho tratándose del mutuo, que es donde el problema ha sido discutido;
- c) El fundamento de la condición resolutoria tácita radicaría, según algunos, en la interdependencia de las prestaciones, lo que sólo puede ocurrir en los contratos bilaterales. La jurisprudencia se ha inclinado definitivamente por la tesis de que sólo procede la acción resolutoria en los contratos bilaterales.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta interesante revisar los fundamentos por los cuales el profesor VIAL estima que esta condición si opera en los contratos unilaterales. Este autor indica que la falta de una norma específica debe ser suplida por los principios generales del derecho, y es principio del derecho el que el contratante incumplidor (sea de un contrato unilateral o bilateral) contrae una responsabilidad que se hace efectiva mediante la indemnización de perjuicios. De este modo, todo contratante tiene derecho a que solicite la indemnización de perjuicios compensatoria, que reemplaza la obligación incumplida; pero para que pueda solicitarse tal indemnización es indispensable que se extinga la obligación infringida, y precisamente el modo de extinción de tal obligación es la resolución del contrato.

5.2. La resolución en los contratos de tracto sucesivo.

La resolución también opera en los contratos de tracto sucesivo, pero pasa a llamarse terminación, porque sus efectos no operan retroactivamente sino sólo para el futuro en razón de que las prestaciones de una de las partes no se pueden devolver.

Y así, en un arrendamiento a dos años plazo, si el arrendatario paga la renta de los primeros seis meses, pero deja entonces de cumplirlas, el contrato puede darse por terminado, pero el arrendador no deberá restituir las rentas percibidas, porque mal podría a su vez el arrendador devolver el uso y goce de la cosa arrendada.

5.3. La resolución no tiene lugar en la partición.

Es corriente que en una partición se produzcan alcances en contra de alguno de los comuneros, esto es, si a un interesado se le dan bienes que exceden su cuota en la comunidad y queda debiendo el saldo. Pues bien, ¿qué pasa si no se pagan estos alcances? ¿Se puede

pedir resolución de la partición? La respuesta es clara: no hay resolución. Así lo afirma en forma unánime la doctrina nacional (SOMARRIVA, CLARO SOLAR, ABELIUK). En el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia.

Las razones de ello son las siguientes:

- a) Porque si bien la partición participa de ciertos caracteres del contrato, no lo es, y menos uno bilateral;
- b) Porque se opone a ello el efecto declarativo de la partición (artículo 1344) que supone que lo adjudicado a cada comunero deriva directamente del causante, no del acto de partición;
- c) El artículo 1489 es doblemente excepcional: primero porque establece una modalidad, y más aún porque ella es tácita. Luego debe darse a la norma una interpretación restringida aplicable únicamente al caso regulado, que es el de los contratos bilaterales;
- d) El art. 1348 hace aplicables a la partición acciones propias de los contratos, como la nulidad y la rescisión, pero nada dice de la resolución, lo que demuestra claramente su intención de excluir esta acción;

6. EL INCUMPLIMIENTO RESOLUTORIO, PRESUPUESTO FUNDAMENTAL PARA EJERCER LA ACCIÓN RESOLUTORIA.

Tradicionalmente, la doctrina nacional afirma que los requisitos para que opere la condición resolutoria tácita son: (1) Que se trate de un contrato bilateral; (2) Incumplimiento de una de las partes, (3) Que quien la invoca haya a su vez cumplido o esté llano a cumplir su propia obligación; y (4) Que sea declarada judicialmente.

Con todo, se ha observado que es discutible que el ámbito de aplicación de la acción resolutoria sean exclusivamente los contratos bilaterales. A su turno, y como se verá más adelante, también existe controversia acerca de la necesidad de que quien requiera la resolución no se encuentre en mora.

Por lo anterior es que hemos estimado pertinente analizar, primeramente, el que es el presupuesto fundamental para que pueda ejercerse la acción resolutoria, a saber, la existencia de un incumplimiento resolutorio. Luego, en otro apartado, se analizará el ejercicio de la acción resolutoria y la necesidad de una sentencia judicial.

El art. 1489 señala que la condición resolutoria envuelta en los contratos bilaterales consiste en el hecho “*de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado*”. Así, el incumplimiento de una de las partes constituye justamente el hecho condicional, por ejemplo, el comprador no

paga el precio de la compraventa, el vendedor no entrega la cosa vendida, el socio no entrega el aporte prometido, el promitente vendedor se niega a otorgar la escritura definitiva de compraventa prometida, etc.

Sobre la materia es necesario analizar una serie de puntos.

a) **¿Es necesario que se trate de un incumplimiento imputable a dolo o culpa del deudor?**

La doctrina tradicional y mayoritaria (CLARO SOLAR, ALESSANDRI, SOMARRIVA) señala que el incumplimiento tiene que ser **imputable** al deudor —esto es, debido a su dolo o culpa— en base a los siguientes argumentos:

- a) Ello se desprendería del mismo art. 1489, que establece que producido el incumplimiento la otra parte puede pedir el cumplimiento o la resolución, en ambos casos, con “indemnización de perjuicios”, y precisamente uno de los requisitos para que opere la indemnización de perjuicios es el dolo o culpa del deudor. Reiteran esta misma idea, en la compraventa, los artículos 1826 y 1873.
- b) Además, si el incumplimiento es por caso fortuito o fuerza mayor no habrá lugar a la resolución, porque la obligación se habrá extinguido por otro modo de poner término a las obligaciones: la imposibilidad en el incumplimiento, que nuestro Código reglamenta bajo el nombre de pérdida de la cosa debida.
- c) Se da también como argumento el art. 1546, según el cual los contratos deben cumplirse de buena fe, de donde se sigue que si el deudor no puede cumplir por un hecho ajeno a su voluntad, sería contrario a la equidad sancionarlo con la resolución del contrato.

Frente a tal posición mayoritaria, recientemente ha surgido una postura que, en base al concepto de pago (o cumplimiento) consagrado en los arts. 1568 y 1569, construye una **noción objetiva de incumplimiento** —esto es, que prescinde del dolo o culpa del deudor—, manifestando al efecto que el incumplimiento es “toda desviación del programa de prestación idealmente convenido que conlleve una desarmonía con el interés que las partes se propusieron satisfacer al momento de la celebración del contrato” (MEJÍAS). Esta postura agrega que en el caso que el incumplimiento no sea imputable al deudor, el sólo podrá pedir la resolución, sin indemnización de perjuicios. Esta tesis, después de constatar que el art. 1489 no otorga un concepto de lo que es un incumplimiento resolutorio, afirma que el mismo se establecerá en base a los siguientes criterios:

a) En primer término, resulta necesario determinar la voluntad explícita o implícita de las partes, quienes en virtud de su libertad contractual pueden señalar de modo preciso en qué casos el incumplimiento dará lugar a la resolución.

b) A falta de estipulación, se debería establecer que un incumplimiento es resolutorio en cuanto este sea de tal incidencia o impacto que se altere el sentido práctico que se perseguía con la celebración del contrato. Ello acontecería en los siguientes supuestos: (i) imposibilidad material o jurídica de la prestación; (ii) privación sustancial al acreedor de beneficios que esperaba obtener con la ejecución del contrato; (iii) entrega de una cosa distinta a la convenida; (iv) prestación tardía que no reporta utilidad al acreedor.

c) El último criterio relevante para determinar la procedencia de la resolución es la pérdida de confianza del acreedor en el futuro incumplimiento de su deudor ante la conducta por él desplegada en la ejecución de la prestación, lo que tendría lugar (i) en caso de dolo o culpa grave del deudor; (ii) reticencia del deudor al incumplimiento; (iii) incumplimiento de obligaciones propias de los contratos *intuitu personae*.

b) ¿Procede la resolución si el incumplimiento es parcial?

En general, se admite la resolución aún cuando se trate de un incumplimiento parcial, esto es, por no cumplirse una de varias obligaciones, o bien por el incumplimiento imperfecto de una obligación; pudiendo en tal caso pedirse una resolución parcial del contrato. Por lo demás así lo permite expresamente en el artículo 1875 inc. 2º. En este punto hay prácticamente unanimidad de la doctrina y de la jurisprudencia (SOMARRIVA, ABELIUK).

Sin embargo, VIAL apunta que la resolución parcial no es posible en el caso que la obligación infringida constituya un efecto esencial del contrato o que, sin serlo, la consideración de su existencia fue el motivo determinante para contratar, de modo que, si falta, el contrato pierde razón de ser; o que cada una de las cláusulas vayan engarzadas entre sí de tal manera que se sirven la una de sustento de la otra.

c) ¿Procede la resolución por incumplimientos intrascendentes?

Cosa distinta a lo anterior es determinar si cualquier incumplimiento, por inocuo o insignificante que sea es suficiente para demandar la resolución, o si bien resulta necesario estar en presencia de un incumplimiento grave.

Parte de la doctrina tradicional (ALESSANDRI, SOMARRIVA, MEZA BARROS) afirma que al no distinguir la ley, cualquier incumplimiento sería suficiente.

El primero que plantea una opinión distinta es CLARO SOLAR, quien fundado en la equidad, piensa que el incumplimiento de una obligación secundaria no es suficiente para pedir la resolución. Posteriormente lo han seguido otros autores; entre ellos, ABELIUK da como razones, en primer lugar, porque puede dejarse sin efecto un contrato por minucias, y en seguida porque no corresponde a la esencia de la institución, derivada de la infracción de las obligaciones recíprocas que constituyen la bilateralidad del contrato: el precio y la cosa en la venta, la renta y el goce en el arrendamiento, etc.

Esta última postura parece más acertada, por cuanto dar lugar a la resolución del contrato por una insignificancia atentaría contra la equidad; faltaría el interés del acreedor en demandar la resolución; habría un abuso del derecho por parte de éste, y en definitiva se contravendría a la buena fe.

En efecto, enfrentados en concreto a un determinado contrato bilateral, el análisis de su contenido específico podría llevarnos a estimar que algunas de sus obligaciones tienen un carácter *principal* o *sustancial* y otras, en cambio, una naturaleza *secundaria* o *accidental*. Para los propósitos de identificar cuáles obligaciones emanadas de un contrato bilateral revisten un carácter *principal* y cuáles son *secundarias*, resultará imprescindible interpretar la convención de conformidad a las reglas de los arts. 1560 y siguientes del Código Civil.

A nivel jurisprudencial, un fallo clásico sobre la materia es el dictado por la Corte de Apelaciones de Talca en el año 1920, en el cual se resolvió que “la falta de cumplimiento de las demás obligaciones accesorias mencionadas [...], no es bastante para determinar la resolución del contrato, por más absolutos que parezcan los términos en que está concebida la disposición del artículo 1489 del Código Civil, dado que tratándose de una materia tradicional como es esta, que es regida por la equidad antes que por el derecho, o, mejor dicho, en la cual las disposiciones legales que la rigen aparecen inspiradas únicamente en principios de equidad natural, debe decidirse la resolución o negarse lugar a ella, según sean las circunstancias de la causa; circunstancias que, en este caso, inducen a negar lugar a la acción resolutoria en razón de que, habida consideración a la poca o ninguna influencia de esas obligaciones en los fines prácticos del contrato [...], es de presumir que aún sin ellas el comprador lo habría celebrado”.

6. NECESIDAD DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN RESOLUTORIA Y DE UNA SENTENCIA JUDICIAL QUE DECLARE LA RESOLUCIÓN.

La existencia de un incumplimiento resolutorio es un presupuesto necesario, pero no suficiente, para que opere la resolución, atendido que además resulta indispensable que se ejerza la acción resolutoria en juicio, y que se pronuncie una sentencia que declare la resolución.

Como se puede apreciar, esto constituye una diferencia notable con la condición resolutoria ordinaria, en cuanto ella opera de pleno derecho.

La necesidad del ejercicio de la acción resolutoria y del pronunciamiento judicial que la acoja fluye con absoluta claridad del propio tenor literal del artículo 1489, que en su inciso 2º, señala “Pero en tal caso...” dando a entender que en este caso no ocurre lo mismo que en el de la condición resolutoria ordinaria. Además, el inciso 2º emplea la expresión “pedir a su arbitrio”, lo que implica demandarlo a un tribunal que naturalmente deberá resolverlo.

Se suele también dar como argumento el que de operar la resolución de pleno derecho, no se ve cómo podría el acreedor usar la opción que le otorga el artículo 1489, para pedir el cumplimiento. No parece lógico que pueda pedir el cumplimiento de una obligación ya extinguida. ABELIUK afirma que este razonamiento no es convincente desde que el artículo 1487- norma aplicable tanto a la condición resolutoria ordinaria como a la tácita- permite al acreedor renunciar a la resolución. De tal suerte, explica que “aun cuando ella operara de pleno derecho, al acreedor le bastaría con manifestar su renuncia, para poder exigir el cumplimiento”.

6.1. La acción resolutoria.

Cabe recordar que conforme al art. 1489 ante el incumplimiento el acreedor tiene la opción de pedir el cumplimiento o la resolución, y en uno y otro caso con indemnización de perjuicios. Tal opción la ejercita el acreedor “a su arbitrio”, y por tanto no tiene que justificar su decisión ni procede cotejar las consecuencias de la alternativa elegida con las de la abandonada para enjuiciarla y deducir alguna limitación. Asimismo, cabe considerar que no es posible pedir simultáneamente el cumplimiento y la resolución, por cuanto son acciones incompatibles, pero si puede pedirse una en subsidio de la otra (art. 17 del Código de Procedimiento Civil).

Dicho lo anterior, a continuación se analizará en particular la acción resolutoria, que, como señala PEÑAILILLO, “es el instrumento procesal destinado a pedir la resolución del contrato”.

(i) Concepto.

ABELIUK define la acción resolutoria como “la que emana de la condición resolutoria en los casos que ella requiere sentencia judicial, y en cuya virtud el contratante diligente solicita que se deje sin efecto el contrato por no haber cumplido la contraparte alguna de las obligaciones emanadas de él”.

Dice la última definición que esta acción emana de la condición resolutoria en los casos en que ella requiere sentencia judicial. Ello se produce respecto de la condición resolutoria

tácita, y en los pactos comisorios típicos (simple y calificado) y en el pacto comisorio atípico y simple, que se analizarán más adelante.

En cambio, en la condición resolutoria ordinaria y en el pacto comisorio atípico y calificado no hay acción resolutoria, porque la resolución opera de pleno derecho; no es necesario demandar judicialmente la resolución, y por ello no se requiere de acción. Luego, como observa ABELIUK, es erróneo afirmar que la acción resolutoria proviene de la condición resolutoria, pues, como se viene mostrando, hay casos de condición resolutoria que no dan acción.

(ii) Características de la acción resolutoria.

La doctrina señala las siguientes:

a) Se trata de una acción resolutoria *personal*. Aun cuando en la doctrina extranjera su naturaleza de personal ha sido discutida, en Chile la unanimidad de la doctrina así lo entiende (ALESSANDRI, ABELIUK, SOMARRIVA). Es personal porque la acción deriva del contrato y éstos generan derechos personales. No olvidemos que el artículo 578 nos dice que “de estos derechos -de los personales o créditos- nacen las acciones personales”.

Por ser personal, sólo se puede entablar en contra de quien celebró el contrato, no en contra de terceros. Por ello, si el comprador, por ejemplo, enajena la cosa a un tercero, no podrá intentarse la acción en contra de este tercero, porque no fue parte del contrato. Ello, sin perjuicio, de que exista otra acción en contra de ese tercero (reivindicatoria o restitutoria), como luego veremos.

b) La acción resolutoria es *patrimonial*. Ello es así desde que su objetivo es dejar sin efecto un contrato patrimonial. No cabe la resolución en el Derecho de Familia.

Del hecho de ser patrimonial derivan importantes consecuencias:

- Es *renunciable*. Así fluye del artículo 1487 y es lógico que así sea pues sólo mira al interés personal del renunciante y no se encuentra prohibida su renuncia (artículo 12). Se puede renunciar en el mismo contrato, antes del incumplimiento o una vez producido éste. Puede la renuncia ser expresa o tácita. El solo hecho de demandar el cumplimiento, no supone la renuncia a la acción resolutoria;

- Es *transferible y transmisible*. En consecuencia, podrán deducirla los herederos y cesionarios del acreedor, y deberán soportarla los herederos del deudor, todo ello de acuerdo a las reglas generales, a las cuales no hay excepción alguna.

- *Es prescriptible*. Su plazo de prescripción será normalmente de 5 años, que se cuentan desde que la obligación se hace exigible (artículos 2514 y 2515). Sin embargo, en la condición resolutoria que emana del pacto comisorio establecido en un contrato de compraventa por no pago del precio, rige la regla especial del artículo 1880, esto es, que prescribe en el plazo que fijaron las partes si no excede de los 4 años, plazo que se cuenta desde la celebración del contrato.

Entre la prescripción de la condición resolutoria tácita y la del pacto comisorio del art. 1880, hay tres diferencias: i) la de los plazos, 5 y 4 años, respectivamente, ii) en el momento en que comienzan a correr, y iii) la primera es de largo tiempo común, y se suspende, en consecuencia, a favor de las personas enumeradas en el art. 2509, mientras que la emanada del art. 1880 es especial o de corto tiempo, y de acuerdo al art. 2524 no se suspende.

c) La acción resolutoria es *mueble o inmueble*, según la cosa sobre que recaiga. Ello en aplicación lisa y llana del artículo 580. Así, la del vendedor de un automóvil, es mueble, y la del vendedor de un bien raíz, inmueble.

d) La acción resolutoria es *indivisible*, siendo esta indivisibilidad es subjetiva y objetiva.

Se dice que la indivisibilidad es *subjetiva*, porque siendo varios los acreedores, todos ellos deben ponerse de acuerdo para pedir el cumplimiento o la resolución, y siendo más de uno el deudor no podría el acreedor exigir a uno el cumplimiento y al otro la resolución. Esta conclusión se funda en el artículo 1526 N° 6 del Código Civil y cuenta con el apoyo de la doctrina (FUEYO, SOMARRIVA).

Adicionalmente, la indivisibilidad es *objetiva*, porque no se puede demandar en parte el cumplimiento y en parte la resolución. Ello es así, porque el artículo 1489, da la alternativa para demandar el cumplimiento o la resolución, pero no en parte el cumplimiento y en parte la resolución.

6.2. En cuanto a la posibilidad de enervar la acción resolutoria mediante la excepción de pago.

Se suele señalar que, atendido que la resolución fundada en la condición resolutoria tácita requiere de sentencia judicial, resultaría factible que el deudor pudiese enervar la acción de resolución, pagando hasta antes de la citación para sentencia en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia.

Así se ha sostenido por buena parte por nuestros autores. En ese sentido, CLARO SOLAR: “Mientras la resolución del contrato no ha sido declarada por la sentencia que ha de poner término al juicio, el contrato subsiste; y por lo mismo, hallándose requerido judicialmente el demandado con la notificación de la demanda, puede evitar la resolución ejecutando la

obligación, efectuando la prestación de lo debido durante toda la secuela del juicio" (FUEYO, ABELIUK, STITCHKIN, SOMARRIVA). En el mismo sentido abundante jurisprudencia de nuestros tribunales.

Estas opiniones se fundan en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil-que consagra las denominadas excepciones anómalas-, permite oponer la excepción de pago en cualquier estado de la causa hasta el cítese para sentencia en primera instancia y la vista de la causa en segunda.

Sin embargo, parte de la doctrina moderna estima que tal solución es errada en razón de una serie de argumentos, de los cuales VIAL señala los siguientes: (1) El Código Civil no establece que el deudor incumplidor puede enervar la acción resolutoria con la excepción de pago; (2) El art. 310 del CPC no es de carácter sustantivo, sino que tan sólo procesal, y su alcance se limita a precisar la oportunidad procesal para oponer la excepción de pago en los casos en que ella sea procedente. Es claro que si el demandante busca el cumplimiento de la obligación, el demandado puede oponer la excepción de pago, pero si persigue lo contrario, esto es la resolución, dicha norma procesal tornaría en ilusoria la facultad de ejercer la acción resolutoria de no perseverar en el contrato que establece sin limitaciones el art. 1489; (3) Finalmente, es la parte diligente –y no la incumplidora- quien decide si perseverar o no en el contrato, pero de seguirse la interpretación mayoritaria, efectuando un pago tardío que no necesariamente será satisfactorio para el acreedor será en definitiva el deudor quien decida si se continúa o no con el contrato.

En esta línea, PEÑAILILLO expresa que "lo que el artículo 310 dispone es que la excepción de pago puede oponerse en cualquier estado del juicio (la excepción es tan trascendente que la ley persigue evitar que por no oponerse durante el breve plazo de la contestación de la demanda se produzca la injusticia de que el deudor se vea obligado a un doble pago, por lo que le permite oponer esa excepción en cualquier tiempo durante el pleito). Esto significa simplemente que si el deudor había pagado (antes de la demanda), puede oponer la excepción de pago durante todo el litigio, pero no significa que pueda pagar después de la demanda, porque entonces la opción, como se dijo, la tendría él, lo que es contrario al texto legal; él es el incumplidor, y habiéndose optado por la resolución por quien tiene la opción, ya no es tiempo de que pague".

Esta última postura ha sido recientemente reconocida por la Corte Suprema, la que en fallo de 25 de mayo de 2011 resolvió lo siguiente en relación al verdadero sentido y alcance del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil: "La norma adjetiva referida alude a las llamadas excepciones anómalas, que son aquéllas perentorias que por excepción pueden "oponerse en cualquier estado de la causa", siempre que se aleguen por escrito "antes de la citación para sentencia, o de la vista de la causa en segunda". Se las califica como anómalas porque, a diferencia de las demás de su naturaleza, pueden hacerse valer después de la contestación de la demanda. Entre ellas figura la de "pago efectivo de la deuda", que es exactamente la que, en el decir de la recurrente, le permitiría enervar la acción deducida en su contra, en cuanto ésta fue presentada en un momento procesal oportuno. Obsta sin embargo, al éxito de esta pretensión, la tesis defendida en doctrina por PEÑAILILLO, citado en el veredicto impugnado en apoyo

de su tesitura, en el sentido que, perteneciendo la opción de instar por la resolución o el cumplimiento del contrato al contratante diligente, la posibilidad reconocida al incumplidor para neutralizar la demanda, mediante el pago de la deuda en cualquier momento del juicio, invertiría el derecho de opción, traspasándolo a este último y contrariando así el sentido de la institución consagrada en el artículo 1.489 del código sustantivo. Haciéndose cargo de la objeción en orden a que esta solución contradice el artículo 310, apunta el autor citado que ello no es así. “Lo que el artículo 310 dispone es que la *excepción de pago* puede oponerse en cualquier estado del juicio, no que se pueda *pagar* en cualquier estado del juicio”. Para luego agregar: “Esto significa simplemente que si el deudor había pagado (antes de la demanda), puede oponer la excepción de pago durante todo el litigio, pero no significa que pueda pagar después de la demanda, porque entonces la opción, como se dijo, la tendría él, lo que es contrario al texto legal; él es el incumplidor, y habiéndose optado por la resolución por quien tenía la opción, ya no es tiempo de que pague” (PEÑAILILLO). En la misma línea de este autor se pronuncia ABELIUK). Esta inteligencia del precepto, que se asimila por otra parte a la propugnada en varios códigos modernos, como el italiano de 1.942 (art. 1.453, inc. 3°) y el boliviano de 1975 (artículo 568, inc. 2°), se concilia mejor con el verdadero sentido y alcance del artículo 1489 del texto sustantivo civil y acota a su correcta dimensión el 310 del ordenamiento procesal civil”.

Sin perjuicio de lo anterior, tratándose del pacto comisorio, el art. 1879 indica que la acción comisorio (especie de resolutoria) precisamente puede ser enervada mediante el pago. Al efecto, VIAL estima que la acción resolutoria con que una de las partes manifiesta su opción de desistirse del contrato y acogerse a los efectos de la condición resolutoria tácita no podría enervarse por el cumplimiento de la obligación infringida, salvo que esta sea la de pagar el precio en el contrato de compraventa, por aplicación del art. 1879.

7. **EN CUANTO A SI ES O NO NECESARIO QUE QUIEN DEMANDE LA RESOLUCIÓN DEBA HABER CUMPLIDO SU PROPIA OBLIGACIÓN O ALLANARSE A CUMPLIRLA. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ART. 1552.**

Buena parte de la **doctrina tradicional** (CLARO SOLAR, ABELIUK, ALESSANDRI, SOMARRIVA) sostiene que un requisito de procedencia de la acción resolutoria consistiría en que quien demanda la resolución debe haber cumplido con sus obligaciones, o bien estar llano a cumplirlas. Este requisito no aparece del artículo 1489, sino que derivaría del artículo 1552, en cuya virtud “*en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos*”.

Así, se afirma que el art. 1552 cumpliría un rol paralizador o inhibitorio, en el sentido de que ante la petición de cumplimiento o resolución, el demandado puede denunciar que el actor también es incumplidor y que, por tanto, con el art. 1552 él no está en mora, porque conforme a este texto, cuando ambos están morosos ninguno lo está. De ahí que se sostenga que, para los contratos bilaterales, el art. 1552 ordena un efecto purgador o limpiador de la mora (**la mora purga la mora**); introduciendo una ficción, el precepto dispone que cuando ambos están en mora, ninguno lo está.

Así, conforma a la doctrina tradicional, si quien demanda la resolución no ha cumplido con su propia obligación, se le opondrá por el demandado la denominada **excepción del contrato no cumplido** (*exceptio non adimpleti contractus*)

Con todo, este entendimiento ha sido debatido por la **doctrina moderna**, la que postula que el art. 1552 tiene un alcance diferente al de contemplar la denominada excepción de contrato no cumplido.

Lo anterior, fundado primeramente en que, a diferencia de nuestro Código Civil, los ordenamientos que han optado por establecer la *exceptio non adimpleti contractus*, coinciden, con mayores o menores matices, en un mismo factor o elemento; a saber: explicitan claramente que tratándose de un contrato bilateral una de las partes no puede exigir el cumplimiento a la otra sino en los casos en que califique como contratante *diligente*, esto es, que haya cumplido lo que a su vez debe en virtud del contrato o que esté llano a cumplirlo.

Pues bien, el solo tenor del artículo 1552, por lo demás claro, permite determinar su sentido y alcance sin necesidad de recurrir a otros preceptos ni a posición doctrinaria alguna. En efecto, el precepto únicamente expresa que en un contrato bilateral ninguno de los contratantes se entiende en *mora* por el hecho de infringir su obligación si el otro, a su vez, no ha cumplido la suya o no se allana a cumplirla en el tiempo y la forma debidos. En consecuencia, en el ámbito que aquí interesa, es evidente que el legislador nacional solo consideró la naturaleza bilateral del contrato y, por lo mismo, la eventual ruptura de la reciprocidad de las obligaciones que engendra, para un *único y preciso objeto*: determinar si una de las partes está o no constituida en *mora* en el supuesto que incumpla la obligación.

Así las cosas, corresponde ahora preguntarse ¿y para qué efectos se regula la constitución en mora –o ausencia de ella– a que alude esta disposición legal? La doctrina moderna señala que ello es con la **finalidad de establecer si es o no procedente la indemnización de perjuicios** que se deriva de un incumplimiento contractual. Nada más ni nada menos. Por tanto, no tiene por finalidad establecer un límite a la acción resolutoria.

Por lo demás, de seguirse la tesis tradicional, se arribaría a resultados francamente inconvenientes para la estabilidad y coherencia de las relaciones jurídicas. En efecto, conforme a tal doctrina tradicional, ante un incumplimiento recíproco no cabría la resolución, por cuanto ninguna de las partes ha cumplido ni se encuentra llana a cumplir.

Sin embargo, si las partes no acuerdan la resciliación del contrato, quedarán vinculadas por un contrato que ninguna de ellas tiene interés en cumplir, generando una situación de incertidumbre (por ejemplo, si fallece una de las partes no se sabe qué actitud podrían adoptar sus herederos). Una alternativa (aunque insatisfactoria por lo postergante) es esperar a que transcurra el correspondiente plazo de prescripción. Como observa VIAL, “no es lógico que las obligaciones que engendra, que debieron extinguirse por el

incumplimiento aunque este fuere imputable a ambas partes, deban mantenerse artificialmente con vida hasta que las extinga la prescripción. En otras palabras, no parece jurídicamente razonable que si ninguna de las partes del contrato bilateral quiere perseverar en él, deban continuar ligadas por el vínculo contractual a menos que una de estas cumpla su obligación. Ello más aún si cumple con el solo objeto de demandar la resolución, que va operar los efectos que le son propios que suponen que el contrato nunca existió y que, por lo mismo, no engendró obligaciones”.

8. EFFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.

Los efectos de la resolución por incumplimiento son los mismos ya estudiados al analizar los efectos de la condición resolutoria ordinaria, materia ya analizada a propósito de la clasificación de las obligaciones, a lo que nos remitimos.

Muy en síntesis, cabe observar que la resolución pone término al contrato, y en cuanto tal tiene un efecto extintivo. En este sentido, el art. 1567 N° 9 establece que un modo de extinguir las obligaciones tiene lugar “por el evento de la condición resolutoria”; en general se indica que, extinguidas las obligaciones, se extingue asimismo el vínculo contractual.

Consecuencialmente, y en lo que se refiere a los efectos de la resolución entre las partes, se observa que tiene lugar un *efecto restitutorio*, en cuanto las partes deben volver al estado anterior a la celebración del contrato, como si nunca hubieren contratado. Así lo ordena el artículo 1487, que es de alcance general para cualquier tipo de condición resolutoria: “Cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición, a menos que ésta haya sido puesta en favor del acreedor exclusivamente, en cuyo caso podrá éste, si quiere renunciarla, pero será obligado a declarar su determinación, si el deudor lo exigiere”.

Por su lado, los efectos de la resolución respecto de terceros se regulan en los artículos 1490 y 1491 del Código Civil.

9. RESOLUCIÓN, NULIDAD Y RESCILIACIÓN.

Para terminar, cabe observar que existen una serie de **diferencias entre la resolución y nulidad** de un contrato, a saber:

1. Porque la nulidad y rescisión suponen alguna omisión de los requisitos de eficacia del acto o contrato, que ha nacido viciado, y por ello se le deja sin efecto. En cambio, en la resolución el acto es perfectamente válido, en sí mismo es inatacable (por ello, se ha resuelto, que no puede demandarse la resolución de un contrato de promesa nulo) y es un hecho posterior, el incumplimiento de una obligación, el que permite al acreedor solicitar que se

deje sin efecto el contrato, pero también puede exigir el cumplimiento, precisamente, porque el acto es válido y eficaz;

2. La nulidad y rescisión producen efectos radicales; borran totalmente el acto o contrato; la resolución es de efectos más atenuados; así la nulidad de acuerdo al art. 1689 da acción contra terceros (de buena o mala fe) sin efectuar las distinciones que realizan los arts. 1490 y 1491, para la resolución;

3. La nulidad procede en toda clase de actos y contratos, mientras que la resolución únicamente en estos últimos, si son bilaterales (según la doctrina mayoritaria);

4. La acción de nulidad absoluta prescribe en 10 años; la rescisoria en 4, y por regla general la resolutoria en 5, que pueden ser 4 en el pacto comisorio;

5. Las reglas de las prestaciones mutuas son diferentes, y así en la nulidad y rescisión el deudor de mala fe debe restituir los frutos, mientras que en la resolución ellos no se devuelven, y no se pagan las mejoras necesarias, mientras debe hacerse en la nulidad y rescisión, etc.

A su turno, también se deben observar las **diferencias entre la resolución y la resciliación**. Corresponden a dos instituciones absolutamente diferentes. La resolución procede cuando en un contrato bilateral una de las partes no cumple sus obligaciones. La resciliación, en cambio, es un modo de extinguir las obligaciones que se produce cuando las partes, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, y en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, acuerdan dejar sin efecto el contrato de donde emana la obligación (art. 1567 inc. 1º). Por su propia naturaleza, la resciliación no puede afectar en modo alguno a los terceros, pues el acuerdo que ella supone les es inoponible, "*res inter alios acta*".

V.B.

EL PACTO COMISORIO

1. CONCEPTO.

El pacto comisorio está tratado en el párrafo 10 del Título XXIII del Libro IV del Código Civil, a propósito del contrato de compraventa por no cumplimiento de la obligación de pagar el precio. Su concepto lo da el artículo 1877 "por el pacto comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de compraventa" (inc. 1º). "Entiéndese siempre esta estipulación en el contrato de venta y cuando se expresa, toma el nombre de pacto comisorio, y produce los efectos que van a indicarse" (inc. 2º)

De lo expresado en este artículo, se desprende que el pacto comisorio viene a ser la estipulación de la condición resolutoria tácita, por el no pago del precio en el contrato de compraventa. En efecto, si nada hubieren dicho las partes, y el comprador no pagare el precio, el efecto sería en principio el mismo.

2. EL PACTO COMISORIO PROCEDE EN CUALQUIER CONTRATO Y POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA OBLIGACIÓN.

La ubicación de esta norma, dentro del contrato de compraventa y a propósito del no pago del precio, ha hecho surgir dudas sobre si puede también convenirse en otros contratos y en la misma compraventa por obligaciones distintas a las del pago del precio.

Hoy día la doctrina es conteste en que pese a estar el pacto comisorio tratado en el contrato de compraventa, por el incumplimiento de la obligación de pagar el precio, su alcance es general, pudiendo establecerse en cualquier contrato (incluso contratos unilaterales con el efecto propio de anticipar el cumplimiento) y por el incumplimiento de cualquier obligación. Esta opinión, se funda en los siguientes argumentos:

- a) El pacto comisorio no es otra cosa que la condición resolutoria tácita expresada, convenida;
- b) En virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden celebrar cualquiera estipulación con tal que no se atente contra la ley, el orden público o la moral y, por la misma razón, no se ve por qué no podrían acordar un pacto como éste;
- c) Únicamente por una razón histórica el pacto comisorio se ha ubicado dentro de los pactos accesorios al contrato de compraventa. Tiene su origen en la *Lex Commissoria* del Derecho Romano. Como allí no se aceptaba la condición resolutoria tácita, pareció necesario establecer la *Lex Commissoria*, en cuya virtud si el comprador no pagaba el precio, el vendedor quedaba autorizado para solicitar se dejase sin efecto esa venta.

Un problema distinto es saber qué normas se van a aplicar al pacto comisorio establecido en los demás contratos, si la de los artículos 1877 y siguientes, o las generales de la condición resolutoria tácita y de la ordinaria.

A modo de ejemplo señalemos que es muy corriente en los contratos de arrendamiento este tipo de pactos, con el objeto de que el arrendador se ponga a cubierto de la posible mora del arrendatario. Es usual encontrar cláusulas como la que sigue: “Si el arrendatario no pagare la renta convenida dentro del plazo fijado (dentro de los cinco primeros días de cada mes, por ejemplo), el contrato de arrendamiento se extinguirá de inmediato”. Por otra parte, y

tratándose del contrato de compraventa, es posible que se estipule un pacto comisorio relativo a la obligación del vendedor de hacer entrega de la cosa.

3. PACTO COMISORIO SIMPLE Y PACTO COMISORIO CALIFICADO

La doctrina ha establecido esta clasificación del pacto comisorio, que extrae del artículo 1879: “Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido, se resuelva ipso facto el contrato de compraventa, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir, pagando el precio, lo más tarde en las veinticuatro hora subsiguientes a la notificación judicial de la demanda”.

De esta norma se infiere que existen dos modalidades de pacto comisorio:

a) El pacto comisorio simple, que no viene a ser más que la condición resolutoria tácita expresada. Por ejemplo, en un contrato de compraventa se establece que si el comprador no paga el precio se resolverá el contrato; o si en el arrendamiento se conviene que si el arrendatario no paga la renta en la oportunidad fijada en el contrato, éste se extinguirá (recuérdese que el contrato de arrendamiento es un contrato de tracto sucesivo por lo que la resolución toma el nombre de terminación); y

b) El pacto comisorio calificado o con cláusula de ipso facto, que se define como el acuerdo de las partes en orden a dejar sin efecto el contrato, de inmediato, de ipso facto, si el deudor incumple sus obligaciones. No es necesario emplear palabras sacramentales (por ejemplo: sin necesidad de juicio, de pleno derecho, inmediatamente, etc.). Estaremos frente a un pacto comisorio calificado, cualquiera que sean los términos empleados, si aparece clara la intención de las contratantes de que se produzca la resolución de inmediato, por el sólo hecho del incumplimiento, sin necesidad de resolución judicial. Ejemplos: Si comprador no pagare el precio dentro del plazo establecido, se resolverá de inmediato, de ipso facto, el contrato de compraventa; si el arrendatario no pagare la renta convenida dentro del plazo fijado, el contrato de arrendamiento se extinguirá de ipso facto (por el sólo ministerio de la ley, sin necesidad de declaración judicial).

4. EFECTOS DEL PACTO COMISORIO

Para estudiar el punto, es necesario distinguir si el pacto comisorio es típico o atípico; y, en cada caso, si el mismo es simple o calificado.

4.1. Efectos del pacto comisorio típico.

Se denomina pacto comisorio *típico* a aquel que se encuentra regulado (o “tipificado”) en la ley, a saber, el normado en los artículos 1877 a 1880 del Código Civil, como una convención

accesoria al contrato de compraventa, referente al incumplimiento de la obligación de pagar el precio.

(i) Efectos del pacto comisorio típico y simple.

El pacto comisorio típico simple es aquel en que se conviene que el contrato de compraventa se resolverá en caso de incumplimiento del pago del precio por parte del comprador.

El artículo 1878 expresa que “por el pacto comisorio no se priva al vendedor de la elección de acciones que le concede el artículo 1873”, esto es, el derecho a exigir el precio (cumplimiento del contrato) o la resolución de la venta, con resarcimiento de perjuicios.

Como se puede observar, estos efectos son idénticos a los de la condición resolutoria tácita: es decir, el comprador, puede pedir el cumplimiento o la resolución del contrato con indemnización de perjuicios. Y por la misma razón, para que opere se requiere de una resolución judicial, igual que ocurre en la condición resolutoria tácita.

(ii) Efectos del pacto comisorio típico y calificado.

Los efectos del pacto comisorio en este caso, están tratados en el artículo 1879: *“Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido, se resuelva ipso facto el contrato de compraventa, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir, pagando el precio, lo más tarde, en las veinticuatro horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda”*.

Como puede observarse, pese a que las partes convinieron que la compraventa se resolviera de ipso facto, es decir por el sólo hecho del incumplimiento, no ocurre de esta forma, puesto que se otorga al comprador un plazo de 24 horas que se cuentan desde la notificación de la demanda, para enervar la acción de resolución, pagando el precio adeudado. De manera que está claro, que la resolución no opera de pleno de derecho, sino que se requiere de una sentencia judicial que la declare.

Se demanda la resolución en juicio ordinario, pues no hay un procedimiento especial (art. 3 del Código de Procedimiento Civil). Notificada la demanda, el comprador cuenta con un plazo de 24 horas, para enervar la acción de resolución pagando. Si el vendedor no quiere aceptar el pago, podrá pagar por consignación, lo que hará depositando la suma adeudada con los intereses vencidos, si los hay, y los demás cargos líquidos, en la cuenta corriente del tribunal que conoce del juicio de resolución (art. 1600 inciso final).

En conclusión, dice ABELIUK, no hay más diferencia, entre la condición resolutoria tácita y el pacto comisorio simple, por un lado, y el calificado en la compraventa por no pago del precio que el plazo que tiene el deudor para pagar, que es de 24 horas para este último y de todo el juicio en los dos primeros. Sin embargo, esto último no es compartido por toda la

doctrina, atendido que varios autores estiman que en la condición resolutoria tácita no es posible poder pagar durante todo el juicio.

Respecto al plazo para pagar, llamamos la atención que son 24 horas, que no es lo mismo que un día, por cuanto por tratarse de un plazo de horas, se empieza a contar a partir del momento mismo en que se notifica la demanda

Ej. si se notifica a las 5 P.M. del 13 de septiembre, el plazo vence a las 5 P.M. del 14 de septiembre. En tanto, que si fuere de un día, y se notifica a las 5 P.M. del día 13, el plazo vence el 14 a las 24 horas, por disponerlo así el artículo 48 del Código Civil.

Además es un plazo fatal, por lo que cumplido caduca el derecho del comprador para pagar, sin necesidad de acusar rebeldía (artículo 49 del Código Civil).

No hay duda, decimos, que en el presente caso la resolución requiere de sentencia judicial. Los siguientes argumentos así lo prueban:

- a) Argumento histórico. En los proyectos de Código Civil, aparece claro que don Andrés BELLO se quiso separar en esta materia del artículo 1656 del Código Civil francés, que le sirvió de fuente inspiradora;
- b) El artículo 1878 -aplicable al pacto comisorio simple y al calificado- no priva al vendedor de la elección de acciones, pudiendo éste pedir el cumplimiento o la resolución. Si el contrato se resolviera ipso facto, no se ve como podría solicitarse el cumplimiento, pues el contrato ya está terminado;
- c) El artículo 1879, señala que el comprador podrá, “sin embargo, hacerlo subsistir”. Esta frase demuestra que el contrato no se extinguió por el sólo incumplimiento, pues “subsistir” significa que sigue viviendo (de otro modo había señalado “revivir”);
- d) Si el comprador puede enervar la resolución pagando dentro de 24 horas, desde que le notifica la demanda, es porque la resolución no opera por el sólo hecho del incumplimiento; y
- e) Finalmente, el plazo que la ley otorga al deudor para hacer subsistir el contrato se cuenta desde la notificación judicial de la demanda, lo que prueba que es necesario un juicio.

Aclarado que en el caso que se viene tratando, la resolución opera por sentencia judicial, es necesario dilucidar en qué momento se produce la resolución. Hay dos opiniones: i) Según algunos (BARROS ERRÁZURIZ, FUEYO), la resolución se produce al momento en que se acoge la demanda por sentencia ejecutoriada; ii) Para otros (ALESSANDRI), la resolución se produce al momento en que se extingue el plazo de 24 horas para enervar la acción pagando.

4.2. Efectos del pacto comisorio atípico.

Conforme se analizó con anterioridad, la doctrina y jurisprudencia nacional admiten la plena validez de convenir un pacto comisorio diverso al regulado en la ley, esto es, para contratos diversos de la compraventa, o bien, en la compraventa, en relación a una obligación distinta de la de pagar el precio. A esta clase de convenciones se las denomina pacto comisorio atípico.

(i) Efectos del pacto comisorio atípico y simple.

El pacto comisorio atípico y simple puede referirse al convenido en un contrato de compraventa por el incumplimiento de una obligación distinta a la del pago del precio (ej. la obligación del vendedor de entregar la cosa vendida) o; al pactado en cualquier otro contrato por incumplimiento de cualquiera obligación.

Siendo el pacto comisorio simple sólo la condición resolutoria tácita expresada, sus efectos son los mismos de aquella, es decir, se otorga al contratante cumplidor la opción para pedir el cumplimiento o la resolución más indemnización de perjuicios. Luego, se requiere también de sentencia judicial que declare la resolución.

(ii) Efectos del pacto comisorio atípico y calificado.

El pacto comisorio atípico y calificado es aquel en el que se conviene la terminación ipso iure del contrato de compraventa por el incumplimiento de una obligación distinta a la de pagar el precio o, en otro contrato por incumplimiento de cualquiera obligación.

En relación con los efectos del pacto comisorio calificado en estos casos, hubo en un tiempo una discusión doctrinaria, que se estima hoy prácticamente agotada. El problema es resolver si la resolución opera de pleno derecho o si requiere también, igual que en la compraventa por no pago del precio, de una sentencia judicial que la declare.

ABELIUK y RAMOS estiman que opera de pleno derecho, sin necesidad de una sentencia judicial que lo declare. Les parece absolutamente claro que el pacto comisorio calificado, en este caso, opera de pleno derecho porque es eso lo que las partes pretendieron al estipularlo. No estamos frente al pacto comisorio del artículo 1879, por lo que no hay razón para aplicar sus reglas, sino ante un pacto creado por las partes en virtud del principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 1545. La norma del artículo 1879, es excepcional - porque rige para la compraventa y sólo para el no pago del precio- por ello su aplicación debe ser restrictiva. Además, como afirma STITCHKIN, "...para interpretar las cláusulas de un contrato en que no hayan reglas especiales, debe recurrirse a las disposiciones generales de los artículos 1560 y siguientes, que atienden principalmente a la intención de los

contratantes, que al estipular en esta forma el pacto comisorio en un contrato, pretenden, sin lugar a dudas, que se resuelva de pleno derecho en caso de incumplimiento”.

La Corte Suprema en sentencia de 2 de julio de 1948 acoge la tesis anterior, al establecer que en los contratos de arrendamiento las partes pueden estipular la terminación ipso facto del contrato por incumplimiento de las obligaciones de alguna parte y que esta estipulación surte los efectos que quisieron atribuirle, o sea que el contrato queda terminado por el sólo hecho de no cumplirse la obligación de que se trata, sin necesidad de acción en que se pida la terminación ni de sentencia que la declare. Este fallo tiene un extenso y esclarecedor comentario favorable de SANTA CRUZ S. quien, entre otros argumentos, recuerda que el pacto comisorio constituye una condición resolutoria, por lo que cabe aplicarle lo dispuesto en el artículo 1484, según el cual las condiciones deben cumplirse literalmente, en la forma convenida. Y exigir sentencia judicial, no es lo que las partes convinieron. En el mismo sentido Fernando ALESSANDRI. En contra Arturo ALESSANDRI, CLARO SOLAR quienes sostienen que cuando se estipula pacto comisorio calificado en otros contratos distintos de la compraventa debe aplicarse por analogía el art. 1879, y en consecuencia resolver que el deudor puede enervar la resolución pagando dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la demanda. Por tanto, requeriría también de un juicio para obtener la resolución.

Al operar el pacto comisorio calificado de pleno derecho en el contrato de arrendamiento por ejemplo, si en éste se estipuló que el contrato terminaba de ipso facto por el no pago de las rentas en la oportunidad fijada, y se produce el incumplimiento, el arrendador puede demandar directamente de restitución de la cosa arrendada, sin necesidad de pedir la terminación del contrato. Además, por la misma razón, el arrendatario carece de facultad para hacer subsistir el contrato consignando las rentas que en su oportunidad dejó de pagar, etc.

5. PREScripción DEL PACTO COMISORIO

El artículo 1880, establece que “el pacto comisorio calificado prescribe al plazo prefijado por las partes, si no pasare de cuatro años, contados desde la fecha del contrato”. “Transcurridos estos cuatro años, prescribe necesariamente, sea que se haya estipulado un plazo más largo o ninguno”.

Respecto de esta norma, es importante precisar lo siguiente:

- a) El plazo de prescripción que ella establece rige únicamente para el pacto comisorio - simple o calificado- que reglamenta el Código Civil, es decir para el contrato de compraventa por no pago del precio.

En el caso del pacto comisorio establecido en otros contratos, o en la compraventa por una obligación diferente a la de pagar el precio, no se aplica la norma del artículo 1880. La prescripción en esos casos, se regula por los artículos 2514 inc. 2º y 2515, vale decir, prescribe en 5 años contados desde que la obligación se hace exigible. Esta opinión no es naturalmente

compartida por quienes son partidarios de aplicar a estos pactos comisorios por analogía las reglas de la compraventa;

b) El artículo 1880, no dice que el pacto comisorio prescriba en 4 años, sino en el plazo que las partes acordaren si no pasare de 4 años. Luego puede prescribir en un plazo menor de 4 años; y,

c) Finalmente, el precepto contiene una grave anomalía, porque la prescripción, contrariamente a la regla general, se cuenta desde la fecha del contrato y no desde que la obligación se hizo exigible, y de ahí que la acción puede estar prescrita antes de nacer. Por ejemplo, en una compraventa se otorgan al deudor 5 años para el pago del precio y se estipula pacto comisorio. Si a los 5 años el comprador no paga el precio, la acción resolutoria estaría ya prescrita porque han pasado 4 años desde el contrato. Y no podría el acreedor pretender que no entabla la acción resolutoria del pacto comisorio, sino la emanada del art. 1489, que se cuenta conforme a las reglas generales, porque de ser así, el art. 1880 no tendría objeto. Esta última interpretación ha sido debatida, en consideración que el pacto comisorio es un beneficio para el acreedor, que no constituye una renuncia de la condición resolutoria tácita; adicionalmente, conforme al art. 1878 sigue vigente la opción del art. 1873, que es precisamente la condición resolutoria tácita, que se rige por sus propios plazos de prescripción.

V.C.

CLÁUSULA DE TÉRMINO UNILATERAL DEL CONTRATO

Es frecuente que en un contrato se establezca en beneficio de una de las partes o indistintamente de cualquiera de ellas la facultad de ponerle término sin expresión de causa, con lo cual se sujeta la extinción del contrato a la mera voluntad de la parte en cuyo beneficio se ha establecido el derecho de desligarse del vínculo contractual.

Al respecto, primeramente se debe observar que existe consenso doctrinal y jurisprudencial en lo que respecta a la plena validez de estas cláusulas, atendido que la estipulación mediante la cual se conviene la posibilidad de que una parte ponga término unilateral y anticipado a un contrato, constituye una manifestación de lo preceptuado en el artículo 1545, y concretamente, en cuanto establece que un contrato válidamente celebrado puede ser invalidado por el consentimiento mutuo de los contratantes.

Cabe observar que esta clase de estipulación –que habilita a poner término unilateral y anticipado- no es incompatible con una cláusula que regule un plazo general de vigencia del contrato: esta última se refiere a lo que podría denominarse el modo “normal” en que el

contrato expirará (a saber, el vencimiento del plazo estipulado para su duración). La estipulación de término unilateral y anticipado, en cambio, se refiere al que sería una forma “anómala” de ponerle término al mismo: de forma anticipada, conforme a la voluntad de una cualquiera de las partes. De entenderlo de otra forma, se estaría restando efecto a una u otra cláusula, cuestión que no resulta factible a la luz de la regla de interpretación del art. 1562.

Despejado lo anterior, lo cierto es que el hecho que un contrato consagre la facultad de ponerle término anticipado “sin expresión de causa” no implica que esta potestad contractual constituya un derecho absoluto, en el sentido que pueda ser ejercido de forma arbitraria o abusiva. El texto de una estipulación como la que se está analizando, en su recto sentido, únicamente da cuenta que el aviso de término de contrato no requiere “expresar” o “manifestar” la causa del término, lo que no exime al término anticipado de tener una causa real y lícita, susceptible de ser controlada por la jurisdicción para evitar su ejercicio malicioso o abusivo.

Para concluir lo anterior, debe tenerse en consideración lo que dispone el artículo 1467 del Código Civil, en cuanto a que toda manifestación de voluntad debe tener una causa, real y lícita, pero no es necesario expresarla. Lo mismo ocurre en esta clase de estipulaciones: el término anticipado de un contrato constituye una manifestación de voluntad, la cual no constituye un derecho absoluto o arbitrario. Así, si bien no es necesario expresar su causa, dicho término anticipado debe igualmente estar motivado por una causa real y lícita, susceptible de someterse al escrutinio judicial.

En el mismo sentido lo resolvió recientemente la Corte Suprema, en fallo de fecha 22 de mayo de 2019, cuyo razonamiento se sustenta fundamentalmente en la interpretación del contrato guiada por el principio de la buena fe. En concreto, el fallo observa que, más allá de los términos de la cláusula, resulta contrario a la buena fe el admitir un término intempestivo, abrupto o abusivo del contrato, y en consecuencia la decisión de poner término anticipado debe sustentarse en un motivo racional y justo.

El fallo recién citado viene a confirmar la jurisprudencia de la Corte Suprema en lo que se refiere a la interpretación de los contratos de conformidad al principio de la buena fe, particularmente en lo que respecta a convenciones que de algún modo alteran la responsabilidad civil regulada por la ley. La sentencia se sustenta en una serie de pronunciamientos de la misma Corte, así como en lo expuesto por una serie de autores; al efecto, hace suya una cita a CORRAL: “Una absolutización ideológica del principio de la intangibilidad contractual, que llevara a excluir a priori todo tipo de intervención en el contenido de un acuerdo contractual, correría un serio riesgo de transformar el contrato en un instrumento de explotación y dominio más que de expresión de la libertad personal”.

Por ello es que, como lo han resuelto reiteradamente los tribunales de alzada, la interpretación de buena fe impide que los contratantes puedan asilarse en la literalidad inflexible del contrato para dar menos ni para exigir más, arbitrariamente, al influjo de un interés propio y mezquino; antes bien, debe dejarse expresar al contrato ampliamente su contenido.

VI.

ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

Como se adelantó, el art. 1489, además de otorgar el derecho alternativo u opción de solicitar el cumplimiento forzado o la resolución, reconoce el derecho del contratante diligente de exigir además la indemnización de los perjuicios causados por el incumplimiento.

VI.1.

NOCIONES GENERALES

1. CONCEPTO

El cumplimiento por equivalencia o indemnización de perjuicios consiste en el derecho que la ley otorga al acreedor para obtener del deudor el pago de una cantidad de dinero equivalente al beneficio pecuniario que le habría reportado el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación. Según ABELIUK “las características fundamentales de la indemnización de perjuicios son: que tiende a reparar el perjuicio sufrido por el acreedor por el incumplimiento imputable del deudor, y que no implica un cumplimiento igual al que debió prestarse”.

En otras palabras, la infracción de una obligación contractual da lugar a una responsabilidad consistente en la reparación de los daños causados al acreedor. Frente a esta responsabilidad contractual, que tiene lugar en la medida que exista un vínculo jurídico previo, se encuentra la responsabilidad extracontractual, en la que el daño no proviene del incumplimiento de una obligación emanada de un contrato, sino que de cualquier otro hecho.

La indemnización de perjuicios cumple una doble función. Es una sanción para el deudor que incumple con dolo o culpa; y, a la vez, es un medio dado al acreedor para que pueda obtener el cumplimiento de la obligación por equivalencia.

2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR PERJUICIOS

Para la mayoría de los autores la de indemnizar los perjuicios es la misma obligación que dejó de cumplirse (*perpetuatio obligationis*), y que ante el incumplimiento cambia el objeto: en vez de perseguirse el cumplimiento de la obligación tal como ella se originó (*in natura*), se pretende una suma de dinero que represente al acreedor lo mismo que le habría significado a su patrimonio obtener el cumplimiento fiel de aquella (*aestimatio rei*). De este

modo, no habría novación, porque no se está extinguiendo la obligación anterior, no hay reemplazo de la obligación original por la de indemnizar.

Una doctrina minoritaria entiende en cambio que la obligación de indemnizar sería una nueva obligación que nace del hecho ilícito consistente en el incumplimiento de una obligación contractual.

La primera de las posturas sería la adoptada por el Código, pues los artículos 1672 y 1555 precisamente dan cuenta que se trata de una misma obligación, pero que varía de objeto.

La importancia de determinar cual es la naturaleza jurídica de la obligación de indemnizar consiste en que si se considera que es la misma obligación, todas las garantías de la obligación incumplida protegen la indemnización, y a la vez todo aquello que afectaba al vínculo de la obligación primitiva (por ejemplo una nulidad) afectará igualmente a la obligación de indemnizar.

3. CLASES DE INDEMNIZACIÓN

La indemnización de perjuicios puede ser: a) compensatoria; y b) moratoria.

En conformidad a la **doctrina clásica**, la indemnización de perjuicios compensatoria es la cantidad de dinero que tiene derecho el acreedor para repararle el perjuicio que le reportó el incumplimiento total o parcial de la obligación. De acuerdo a BAUDRY-LACANTINERIE esta indemnización “No es otra cosa que la avaluación en dinero del interés que el acreedor tenía en que la obligación fuera ejecutada; la compensación, en consecuencia, de los perjuicios que la inejecución le causa”. Su monto debe regularse considerando el valor de la cosa debida. Y si la obligación es de hacer, para determinar su monto se atenderá a lo que representaría económicamente la ejecución del hecho.

Por su parte, la indemnización de perjuicios moratoria, es aquella que tiene por objeto reparar al acreedor el perjuicio sufrido por el incumplimiento tardío de la obligación. Los mismos autores indican que “No es otra cosa que la avaluación en dinero del interés que el acreedor tenía en que la obligación fuera ejecutada en la época en que debía serlo”. En ambos casos la indemnización se paga en dinero, por ser el dinero una común medida de valores.

Sin perjuicio de lo anterior, cierta **doctrina moderna** (VIAL) critica lo anterior, pues de ello se desprendería que si el deudor no ejecuta la prestación o la cumple parcialmente, el acreedor debería demandar necesariamente la indemnización de perjuicios compensatoria; y si el deudor cumplió pero tardíamente, se tendría que dar lugar a la indemnización moratoria, todo lo cual no es efectivo en conformidad a la regulación del Código Civil.

Al efecto, y fundado en el ya estudiado art. 1489 –que regula la condición resolutoria tácita, VIAL señala que la indemnización de perjuicios compensatoria se puede reclamar cuando el acreedor hubiese optado por solicitar la resolución del contrato, pues en tal caso, y atendido que la resolución extingue el derecho para exigir la prestación debida y la obligación de efectuarla, la indemnización compensatoria reemplaza o sustituye la obligación extinguida. Por su parte, la indemnización de perjuicios moratoria se puede reclamar cuando el acreedor demanda la ejecución forzada de la obligación, y que sin sustituir dicha obligación, que se mantiene vigente, se limita a reparar los daños sufridos por el acreedor por no haberse efectuado en tiempo oportuno.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario considerar que la mayoría de la doctrina tradicional afirma que, sea que se exija la indemnización compensatoria o moratoria, en ambos casos la pretensión indemnizatoria es dependiente e indisociable de la pretensión principal (cumplimiento o resolución) no pudiendo en razón de este carácter ejercerse en forma independiente, sino que siempre asociada a esta. Ello es rebatido por la doctrina moderna, que le otorga a la acción de perjuicios el carácter de autónoma e independiente. Más adelante se analizará en detalle esta controversia.

4. NO SE PUEDE ACUMULAR EL CUMPLIMIENTO Y LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS COMPENSATORIA, PERO SÍ EL CUMPLIMIENTO Y LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA O BIEN AMBAS INDEMNIZACIONES.

Como la indemnización compensatoria equivale al cumplimiento de la obligación no se puede demandar conjuntamente el cumplimiento más indemnización compensatoria, porque importaría un doble pago. Pero sí se puede pedir cumplimiento e indemnización moratoria porque ésta última sólo resarce los perjuicios provenientes del atraso. Esto está permitido expresamente en el artículo 1553, y fluye también de los artículos 1502, 1555 y 1672.

Por excepción en la cláusula penal, en ciertos casos se puede acumular el cumplimiento de la obligación y la pena (artículo 1537).

Y también se pueden demandar ambas indemnizaciones, compensatoria y moratoria, porque se refieren a perjuicios diferentes.

5. ¿ES LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS UN REMEDIO AUTÓNOMO, O BIEN ES DEPENDIENTE DEL CUMPLIMIENTO FORZADO O DE LA RESOLUCIÓN?

Un tema que, no obstante lo fundamental, es altamente controversial, se refiere si es posible demandar la indemnización de perjuicios en forma autónoma, esto es sin necesidad de demandar a la vez el cumplimiento o la resolución.

5.1. Doctrina tradicional

La doctrina tradicional afirma que la **acción de indemnización de perjuicios es accesoria y dependiente** de la de resolución o cumplimiento, y por ende no se puede demandar en forma independiente o autónoma la indemnización de perjuicios, sino que sólo como consecuencia de demandar el cumplimiento o la resolución del contrato.

Lo anterior, en síntesis, fundado en lo siguiente:

- La interpretación gramatical de la expresión “con indemnización de perjuicios” del art. 1489, en cuanto la preposición “con” significa “conjuntamente” o “junto a” da
- La ubicación del art. 1489, esto es a propósito de las obligaciones condicionales y no en el título sobre efectos de las obligaciones, da cuenta que su principal efecto es la resolución, y sólo a partir de ella (o bien del cumplimiento) es posible pedir la indemnización
- El acreedor únicamente tiene los remedios que expresamente le otorga el legislador, y conforme a ello el cumplimiento y la resolución priman sobre la indemnización, que es accesoria
- El fundamento de la indemnización de perjuicios es la resolución o el cumplimiento forzado

5.2. Doctrina moderna

La doctrina civil más moderna postula que la **acción indemnizatoria es de carácter autónomo e independiente** de las acciones de resolución y cumplimiento. Al efecto, se distinguen dos vertientes:

- a. La primera, conforme a la cual quien demanda perjuicios de forma autónoma está manifestando tácitamente la voluntad de resolver el contrato.
- b. La segunda, conforme a la cual quien demanda perjuicios de forma autónoma está renunciando a las acciones de cumplimiento y de resolución, y de acogerse se “extingue el contrato”.

Esta doctrina moderna, en una y otra vertiente, se sustentan, en síntesis, en los siguientes argumentos:

- La interpretación gramatical de la expresión “con indemnización de perjuicios” es discutible, por cuanto otras disposiciones legales (Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías y arts. 1553 y 1555 del Código Civil) darían cuenta de la autonomía de la acción indemnizatoria. Así, y realizando una interpretación lógica y sistemática del art. 1489 CC, esto es, en armonía con los arts. 1553, 1555 y 1590 del Código, art. 157 del Código de Comercio y la referida Convención dan cuenta que el ordenamiento jurídico admite la indemnización como remedio autónomo frente al incumplimiento.
- El art. 1489 se encuentra erradamente ubicado, ya que regula una materia propia de los efectos de las obligaciones, y no limitada a la condición resolutoria (tácita en este caso).
- Existen casos en que la indemnización de perjuicios es el único remedio posible (vgr. cuando al acreedor sólo le interesaba el cumplimiento en un plazo determinado, o bien cuando el incumplimiento no es resolutorio)
- El derecho del acreedor para optar entre los distintos remedios por incumplimiento, que se desprende de los arts. 1553 y 1555, de la Convención De Viena y que es un principio general del derecho de las obligaciones.
- El fundamento de la indemnización es el incumplimiento, siendo irrelevantes al respecto el cumplimiento o la resolución
- La finalidad de la indemnización por incumplimiento es la reparación integral

5.3. La jurisprudencia.

En lo que respecta a la jurisprudencia, hasta el pasado muy reciente (año 2010), y salvo un caso aislado de un fallo del año 1984, la abrumadora y sistemática jurisprudencia era la de establecer la cabal dependencia y accesoriedad de la acción indemnizatoria, rechazándose las demandas por estar mal formuladas, sin entrar a conocer del fondo del asunto (vid. Corte Suprema, Rol 1782-2007, 22 de septiembre de 2008).

Entre los últimos fallos sobre la materia es de la Corte Suprema, de fecha 22 de septiembre de 2008 (Rol 1782-2007): *“la indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, como la demandada, es una consecuencia de la acción de resolución de contrato, de modo que su antecedente jurídico es, precisamente, esta acción optativa que lleva envuelta la de resarcimiento, por lo que no puede pedirse directamente el pago de los perjuicios ya que ellos no son accesorios al incumplimiento del contrato, sino, como se expresó, de las acciones optativas que consagran las dos normas citadas y sin las cuales la indemnización quedaría privada del antecedente jurídico que debe fundamentar toda acción, lo que conlleva, indefectiblemente, al rechazo de la demanda por improcedencia de la acción de la manera que se planteó.”/ En cuanto a la compensatoria, como por medio de ella se reemplaza la prestación a que el deudor está obligado (como su nombre lo indica), no puede ser pedida sino en lugar de ésta. Si la obligación es de hacer o no hacer y el deudor se halla constituido en mora, puede el acreedor,*

prescindiendo del cumplimiento de la obligación, solicitar la indemnización compensatoria, a la vez que la moratoria.

Lo mismo lo resolvió la primera sala en sentencia de fecha 5 de enero de 2010: *Que la acción de indemnización de perjuicios es accesoria a la de resolución hecha valer y debe, por su naturaleza, seguir la suerte de ésta, que constituye su antecedente jurídico necesario. Excluida la procedencia de la resolución, tampoco puede prosperar la acción de reparación supletoria, si con ello vulnerar también los preceptos que se ha declarado equivocadamente aplicados.*

Con todo, a partir del año 2009 en las Cortes de Apelaciones (v.gr. Punta Arenas), y luego el año 2014 en la Primera Sala (Civil) de la Corte Suprema (Primera Sala) se generó un radical cambio jurisprudencia, en cuanto se comenzó a sentar la doctrina de la autonomía de la acción indemnizatoria (vid. Corte Suprema, Rol 474-2014, 10 de noviembre de 2014; y Rol 14.008-2013, 26 de noviembre de 2014).

En el fallo de fecha 10 de noviembre de 2014 (Rol 474-2014) en el que se expuso, a propósito de un caso de incumplimiento de un contrato de promesa. Sin ahondar en los motivos que reforzarían la autonomía de la acción indemnizatoria, la Corte Suprema realiza al efecto una importante –pero en nuestro concepto errada- aplicación del principio iura novit curia: *la labor primordial de los tribunales de justicia es dar amparo a las pretensiones con mérito suficiente en los hechos y el derecho, atendiendo a los aspectos materiales o substanciales de las mismas, sin que consideraciones de carácter formal impidan un pronunciamiento de fondo. Esta exigencia permite otorgar mayor calidad a la administración de justicia, aspecto que se extiende a todos los estadios del procedimiento.*

El segundo fallo es de fecha 26 de noviembre de 2014 (Rol 14.008-2013), en el cual la Corte sí profundizó en los fundamentos que darían pie a la autonomía de la acción indemnizatoria: CUARTO: *Que en lo que toca a la procedencia y autonomía de la pretensión resarcitoria en relación con las acciones destinadas a obtener el cumplimiento o la resolución del contrato, parece oportuno aclarar que, conforme a los principios que integran el Código Civil, no se observan las particulares motivaciones que podrían inducir a privar a los afectados de dirigir las acciones en la forma y del modo como mejor se ajusten a sus intereses, desde el momento que el derecho civil le reconoce a las personas el principio de libre disposición de sus bienes y autonomía de la voluntad, todo lo cual lleva a reconocer las mayores prerrogativas al momento de someter las pretensiones al órgano jurisdiccional. Es por lo anterior que esta Corte Suprema ha reconocido la independencia y autonomía de las acciones indemnizatorias, sean estas moratorias o perentorias, las que cualquiera sea la naturaleza del objeto de la prestación, pueden impetrarse en forma exclusiva, desde el momento que el legislador ha establecido su procedencia y la forma más usual de interposición, pero no ha prohibido la que en mejor forma repare integralmente el daño derivado del incumplimiento;/ QUINTO: *Que establecido que la acción indemnizatoria no se encuentra ligada únicamente en sede contractual a la resolución o cumplimiento forzado de lo pactado, por lo que puede entonces cobrar identidad propia, como acción principal, aunque asociada a una de las variantes referidas- resolución o cumplimiento forzado- como a ninguna de ellas, conviene precisar que para ponderar esta pretensión resulta indispensable vincularla con el hecho en que se le hace descansar./ SEXTO: Que antes parece necesario explicitar las razones que llevan a reconocer la independencia de la acción indemnizatoria de la acción de resolución y/o cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Una razón fundamental surge para ello: tanto la teoría clásica, al considerar que la indemnización es la misma obligación cuyo cumplimiento se logra por medio de la justicia en naturaleza o por equivalencia, como por la teoría moderna que indica que la indemnización es una nueva obligación, permiten arribar a la conclusión que se trata de una acción principal, nunca accesoria.**

La interpretación exegética del artículo 1489 del Código Civil no se aviene con las tendencias modernas que inspiran el derecho de daños que postula la reparación integral del acreedor a través de una indemnización que satisfaga en plenitud los perjuicios irrogados por causa del incumplimiento. Si al acreedor no se le permitiera optar por demandar directamente la indemnización de los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato podría significar que no se alcance el propósito de la indemnización plena. En tal contingencia entonces, entendiendo que el ejercicio de la acción indemnizatoria implica la renuncia al cumplimiento forzado o a la resolución del contrato,

la indemnización se erige así como un remedio autónomo, cualquiera sea la forma en que se ejecute la obligación, lo que se manifiesta con mayor vigor tratándose de contratos de tracto sucesivo en donde el acreedor sigue vinculado jurídicamente al deudor, una vez que éste le indemnice los perjuicios. Más claro aún si el contrato es de ejecución instantánea en donde al seguir la exegética interpretación de la precitada disposición legal la opción del acreedor se ve reducida. Esta es, por tanto, la forma correcta de entender la autonomía de la acción indemnizatoria por incumplimiento de un contrato bilateral;

Creemos que aún es pronto para indicar decididamente un cambio en la jurisprudencia, en especial si se considera que los pronunciamientos del año 2014 son de la Primera Sala, en circunstancias que otras salas de la misma Corte Suprema también pueden conocer de casos de responsabilidad contractual, como acontece en casos de contratos con la Administración del Estado (de conocimiento de la Tercera Sala) o bien de contratos cuya infracción se somete a las normas del es conocida en juicio sumario (de conocimiento de la Cuarta Sala); siendo conocidas las pugnas interpretativas que han regido sobre la materia (v.gr. contabilización del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual, que derivó en un pronunciamiento del pleno vía casación).

5.4. Nuestra opinión.

Sin duda una y otra posición –tradicional y moderna- poseen relevantes y atendibles argumentos, lo que ha explicado el reciente giro jurisprudencial.

Con todo, **resulta que aplicando una u otra doctrina en términos absolutos, se puede arribar a resultados injustos o carentes de lógica jurídica:**

- En efecto, de aplicarse sin excepciones la doctrina clásica, puede suceder que frente a un incumplimiento irrelevante (por ejemplo, la cosa presenta un deterioro menor), y queriendo el acreedor hacer subsistir el contrato, igualmente se vea “forzado” a solicitar el “cumplimiento” del contrato; con todo, este ya fue cumplido (aunque imperfectamente), por lo que lo cierto es que sólo debiera poder exigir la indemnización de perjuicios.
- A su turno, de aplicarse sin excepciones la doctrina moderna, podría suceder que el acreedor solicite únicamente la indemnización compensatoria, pero sin requerir la resolución del contrato, dejándolo por tanto subsistente. En consecuencia, podría obtener dicha indemnización y, acto seguido, ejercer una acción de cumplimiento forzado, obteniendo así un doble pago, cuestión que obviamente el derecho repudia.

Ello nos lleva a pensar que **será necesario distinguir el caso de que se trate**, empleando al efecto los principios de Derecho Civil y Procesal.

- El principio básico que deben regir en la materia.

En una y otra doctrina es posible observar que siempre debe regir un principio básico, como es que, solicitada la indemnización compensatoria, **en caso alguno puede subsistir el contrato ni menos la acción de cumplimiento forzado**, pues de lo contrario, se habilitaría al acreedor a obtener un doble pago: primero vía indemnización, y luego vía cumplimiento en naturaleza. El tema se agrava si se considera que para la mayoría de la doctrina la acción de cumplimiento es irrenunciable anticipadamente.

Frente a tal problema, la doctrina clásica afirma, en nuestro concepto acertadamente, que la indemnización es una consecuencia de la resolución: terminado el contrato el acreedor obviamente no podrá pedir el cumplimiento en naturaleza, pero obviamente podrá pedir un cumplimiento en equivalencia, esto es, la posibilidad de que se le pague lo que habría significado el cumplimiento íntegro y oportuno de la prestación.

Por su parte, hemos visto que la doctrina moderna, a fin de salvar esta situación, posee dos “vertientes”: la primera, conforme a la cual el acreedor que está demandando directamente la indemnización está asimismo “tácitamente” demandando la resolución del contrato; la segunda, conforme a la cual en tales casos el contrato igualmente se “extingue”, aunque no por resolución (porque no se ha pedido), sino que por otro motivo que no se explicita.

A nuestro entender, en este punto ambas vertientes de la doctrina moderna presentan evidentes problemas, en cuanto:

- No es factible sostener que exista un “ejercicio tácito” de la resolución. Desde luego, con ello se está reconociendo lo que afirma la doctrina clásica, en orden a que la indemnización necesariamente es consecuencia de la resolución.

Pero a ello se agrega un evidente problema procesal: el juez únicamente puede pronunciarse sobre las pretensiones hechas valer en juicio, sin poder extender su pronunciamiento a otras materias (como lo sería la solicitud de una resolución tácita), so pena de incurrir en el vicio de ultrapetita. El problema es trascendente, ya que en definitiva la sanción de la ultrapetita encuentra su fundamento en el más elemental derecho a defensa: mal puede de oficio declararse terminado un contrato si el demandado no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la materia.

Desde luego, el principio iura novit curia al que alude la Corte Suprema no salva el problema, ya que el mismo encuentra sus claros límites en el debido proceso y en el derecho a defensa resguardados por la Constitución. Por ende, si bien los jueces pueden echar mano para fundar su decisión a disposiciones o principios legales no invocados por los litigantes, en caso alguno puede decidir sobre pretensiones no sometidas a su conocimiento, ni tampoco alterar el objeto o la causa de pedir de las acciones ejercidas.

- No es factible sostener que el contrato se “extingue” por el ejercicio de una acción indemnizatoria autónoma. El art. 1545 CC es claro: los contratos se extinguen o por consentimiento mutuo o por “causa legal”, y el ejercicio de una acción autónoma no constituye una causal para poner término a un contrato, el que por tanto quedará subsistente.
Y por los mismos motivos antes señalados, el juez no puede declararlo extinguido de oficio, ni aún a pretexto de invocar el principio iura novit curia.

De lo que se viene diciendo se concluye una primera **regla general: la indemnización compensatoria no puede solicitarse de forma autónoma e independiente de la resolución**, pues de lo contrario el contrato (y la acción de cumplimiento) subsiste, encontrándose imposibilitados los jueces de declarar de oficio la terminación del contrato.

Podrá rebatirse lo anterior señalándose que aún de subsistir el contrato y la acción de cumplimiento, cualquier nuevo juicio del acreedor destinado a obtener el cumplimiento en naturaleza debería estar destinado al fracaso, ya que el deudor podría enervar la acción oponiendo una excepción de enriquecimiento sin causa, o bien alegar una contravención a los propios actos, etc. ¿y si no lo hace? El juez no lo puede decretar de oficio, arribándose a una situación absurda e ilógica.

Por lo demás, entendemos que las doctrinas jurídicas deben estar destinadas a dar una solución tan justa como eficiente; por ende, una doctrina que no descarte la posibilidad de proliferación de juicios carentes de lógica no está cumpliendo su cometido. En este punto es que surge con fuerza la institución de la cosa juzgada.

- Excepciones: casos en que no resulta procedente pedir el cumplimiento ni la resolución, sino que exclusivamente la indemnización de perjuicios.

Más allá del principio general antes enunciado, al mismo tiempo es necesario reconocer que existen diversas situaciones en las que no aparece lógico ni procedente que se imponga al acreedor necesariamente tener que ejercer la acción indemnizatoria de modo dependiente al cumplimiento y resolución.

La clave está en identificar casos en los que, habiéndose verificado un incumplimiento que haya causado perjuicios, no sea por un lado procedente o pertinente pedir el cumplimiento en naturaleza de la obligación infringida, y, por el otro, no sea factible o pertinente solicitar la resolución (o, si se quiere, sea necesario o deseable dejar subsistente el contrato). Es decir, se deben dilucidar los **casos en los que la indemnización sea la real y única alternativa**; esto es, casos en los que el acreedor perjudicado no pueda o deba pedir el cumplimiento en naturaleza ni la resolución.

Entre tales casos podemos identificar, a primera vista, los siguientes:

- i. Indemnización de los perjuicios derivados de un cumplimiento tardío de la obligación. En esto existe bastante consenso doctrinal y jurisprudencial, en orden a que siempre la denominada “indemnización moratoria”, esto es, la proveniente del cumplimiento tardío de la obligación, puede demandarse de modo independiente.

Resulta lógico porque (i) no puede formalmente demandarse el cumplimiento forzado de la obligación, ya que la misma ya fue cumplida, aunque tardíamente; y (ii) puede que el acreedor no desee resolver el contrato, ya que el cumplimiento, aunque inoportuno, igual satisfacción en parte su interés contractual, con lo cual sólo le interesa que se le resarzan los perjuicios derivados de la atraso.

Creemos que esta primera excepción encuentra su fundamento en el art. 1559 que regula la evaluación legal de los perjuicios moratorios: basta el sólo hecho del retardo para cobrar intereses como indemnización.

- ii. Indemnización por casos de cumplimientos imperfectos no resolutorios. En segundo término, puede existir casos de cumplimientos imperfectos que, aunque hayan provocado un perjuicio, no sean de tal entidad que habiliten a pedir la resolución. En estos casos el acreedor no puede pedir el cumplimiento (porque ya se cumplió) ni la resolución (por inexistencia de un incumplimiento resolutorio), lo que impone concluir que sólo puede pedir directamente la indemnización.

Esta regla tiene expresa consagración en el art. 1590.2 del CC (ubicado en el párrafo relativo a “Cómo debe hacerse el pago”): ante la entrega de un cuerpo cierto deteriorado culpablemente o durante la mora del deudor, puede el acreedor pedir la resolución del contrato y la indemnización de perjuicios; *“pero si el acreedor prefiere llevarse la especie, o si el deterioro no pareciere de importancia, se concederá solamente la indemnización de perjuicios”*. Una norma similar se encuentra en el art. 1938 sobre arrendamiento.

De la norma emana un principio general: casos de poca importancia de cumplimiento imperfecto que no habilitan para pedir la resolución, sea (i) por ser de poca importancia y no constituir un “incumplimiento resolutorio”, (ii) por haberse pactado una nómina limitada de incumplimientos resolutorios convencionales, ninguno de los cuales se da en el caso; o (iii) por haberse renunciado derechamente a la acción resolutoria.

- iii. En contratos de tracto sucesivo (v.gr. de suministro) en los que frente a un incumplimiento en uno de los “tractos” no se desea poner fin al contrato, y por el otro ya no le resulta útil el cumplimiento tardío; en tal evento, parece ser de justicia y lógica que pueda demandarse exclusivamente la indemnización de perjuicios respecto del “tracto” incumplido.

VI.2.

REQUISITOS DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

Los requisitos de la indemnización de perjuicios en materia contractual, son:

1. Incumplimiento imputable del deudor (dolo o culpa);
2. Perjuicio del acreedor;
3. Relación de causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios;
4. Mora del deudor.

1. PRIMER REQUISITO: INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE

1.1. Clases de incumplimiento.

El primer requisito fundamental para exigir la indemnización de perjuicios es que exista un incumplimiento de la obligación, imputable a dolo culpa del acreedor. Atendido que tal requisito se predica respecto de todos los remedios que el art. 1489 consagra, es que sus principales aspectos ya fueron analizados con anterioridad, a lo que nos remitimos.

Sobre la materia, debe recordarse que de conformidad al art. 1556 hay incumplimiento en tres casos: (i) cuando la obligación no se cumple; (ii) cuando la obligación se cumple imperfectamente; o (iii) cuando se retarda el cumplimiento de la obligación. Dicho de otra manera, cuando se falta íntegramente al pago, o se infringe alguno de los requisitos de éste.

1.2. Prueba del incumplimiento y presunción de imputabilidad

Sobre esta materia, se debe reiterar que conforme al art. 1698, acreditada que sea por el acreedor la existencia de la obligación, corresponde al deudor probar que ha cumplido, porque alega el pago, o sea, la extinción de la obligación y sobre él coloca la ley la carga de la prueba en tal caso.

Asimismo se debe recordar que el art. 1567 presume que el incumplimiento ha sido imputable, ya que debe probar la diligencia quien debió emplearla, lo que se traduce en que se presume la culpa.

1.3 Imputabilidad del deudor (dolo o culpa del deudor)

Para que se genere la obligación de indemnizar perjuicios, el incumplimiento debe ser imputable al deudor, es decir, provenir de su dolo o culpa.

1.3.1. Dolo contractual

i. Concepto

En materia civil, el dolo opera en a lo menos dos casos de acción: (i) en la formación del consentimiento, como un vicio del mismo consistente en engañar a otro a fin de inducirlo a celebrar un acto jurídico, lo que da lugar a la nulidad del mismo; (ii) en la indemnización de perjuicios, como la intención de dañar a otro, sea en el incumplimiento de una obligación contractual, o mediante la ejecución de un hecho ilícito extracontractual.

El dolo está definido en el artículo 44 del Código Civil, como *“la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”*. Este concepto es precisamente el aplicable a la indemnización de perjuicios.

Tal concepto ha sido criticado por la doctrina. En este sentido, RODRÍGUEZ y FUEYO estiman que de entender que sólo hay dolo cuando existe una intención maliciosa, hace casi imposible su prueba, agregando que en la vida real, salvo que se trate de una personalidad perversa, el deudor no deja de cumplir sólo por perjudicar al acreedor, sino para conseguir **un provecho o ganancia, aún a costa del perjuicio del acreedor, a quien no desea exclusivamente perjudicar, pero acepta hacerlo en función de sus intereses**. En razón de lo anterior, la doctrina moderna, trasladando conceptos propios del derecho penal, distingue entre el “dolo directo”, consistente en la intención de dañar definida en el art. 44, del “dolo eventual”, consistente en la conducta de quien si bien no tuvo intención de causar daño, pudo representarse que su actuar sí podía producirlo.

ii. Prueba del dolo

El dolo, dice el artículo 1459, no se presume, sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los demás deberá probarse”. Esta norma si bien está establecida al tratar del dolo vicio del consentimiento, es de aplicación general. Ello, por otra parte, resulta absolutamente concordante con el principio de que “la buena fe se presume”, que si bien está establecido en materia posesoria, hay unanimidad para entenderlo como principio general.

El dolo se puede probar por cualquier medio probatorio, sin que rijan las limitaciones que para la prueba de testigos establecen los artículos 1708 y siguientes.

iii. Efectos del dolo en el incumplimiento de las obligaciones

1. Agrava la responsabilidad del deudor. Ello, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1558. De acuerdo a esta disposición, lo normal es que el deudor responda sólo de los perjuicios directos previstos (o que pudieron preverse) al tiempo del contrato. Mas, si hay dolo, se responderá además de los perjuicios directos imprevistos.

2. Se ha entendido también que si son varios los deudores que incumplen con dolo, su responsabilidad sería solidaria, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2317 inciso 2º. Si bien esta norma está ubicada en la responsabilidad extracontractual, se piensa por algunos, que el inciso 2º sólo se justifica, si su alcance es general. En caso contrario sería inútil pues no haría más que repetir lo dicho en el inciso 1º.

iv. El dolo no se puede renunciar anticipadamente

Así está establecido en el artículo 1465. Puede, no obstante, renunciarse el dolo pasado, siempre que se haga en forma expresa.

v. El dolo se aprecia en concreto, no en abstracto, como la culpa

Lo anterior significa que en cada caso, deberá el tribunal resolver si la conducta del hechor resulta o no dolosa. En cambio, la culpa se aprecia en abstracto, esto es, comparándola con un modelo ideal definido en la ley.

1.3.2. La culpa contractual**i. Concepto.**

El incumplimiento es también imputable al deudor cuando proviene de su culpa.

En términos generales, se entiende por culpa la omisión de la diligencia que se debe emplear en el cumplimiento de una obligación o en la ejecución de un hecho, y por culpa contractual la falta del cuidado debido en el cumplimiento de un contrato.

Al igual que en materia extracontractual, la culpa tiene mayor aplicación que el dolo, por la misma razón, aun cuando más drástica: allá porque es de más fácil prueba; acá la facilidad es todavía mayor: se presume.

Se ha discutido en doctrina si la culpa es una sola (teoría unitaria de la culpa) o si es diferente la culpa contractual de la extracontractual.

ii. Diferencias entre la culpa contractual y extracontractual

Sea que se estime que existe una sola culpa o que la culpa contractual y extracontractual son diferentes, es lo cierto, que se pueden apreciar en ellas algunas diferencias importantes:

- a) La culpa contractual supone un vínculo jurídico previo entre las partes. La extracontractual no.
- b) La culpa en la responsabilidad contractual admite grados: grave, leve y levísima. En materia de responsabilidad extracontractual, ciertos autores afirman que la culpa es una sola y que por tanto no admite graduación.
- c) La culpa contractual se presume. La extracontractual debe probarse.
- d) Para que la culpa contractual de origen a la indemnización de perjuicios -dice ALESSANDRI- "es menester que el deudor se haya constituido en mora, condición previa para que el acreedor pueda exigir indemnización al deudor que viola su obligación. Tratándose de la culpa delictual, no es necesario constituir en mora al deudor; basta la ejecución del simple hecho ilícito para que el acreedor tenga acción por los perjuicios contra el deudor".

iii. Graduación de la culpa

BELLO, siguiendo a POTHIER, estableció en el artículo 44, una clasificación tripartita de la culpa: en grave, leve y levísima, definiendo cada una de ellas.

Dice esta norma:

"La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo".

"Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano".

"El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa".

"Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios

importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado”.

Como puede observarse, la culpa contractual se aprecia en abstracto, pues la ley compara la conducta del sujeto con un modelo ideal (“padre de familia”, “personas negligentes y de poca prudencia”, “esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes”).

iv. La culpa grave equivale al dolo

Así lo dice el artículo 44 inciso 1º parte final. ¿Cuál es el alcance de esta afirmación?

Cuando el deudor incumple con culpa grave, su responsabilidad se agrava, igual que en el dolo, respondiendo de todos los perjuicios directos, previstos e imprevistos. Además, no podría renunciarse anticipadamente la culpa grave (1465); y si hay culpa grave de varios deudores, su responsabilidad sería solidaria (2317 inc. 2º).

v. ¿Se presume la culpa grave?

El problema estriba en determinar si la asimilación de los efectos de la culpa grave a los del dolo alcanza también al onus probandi, y en consecuencia si el acreedor que la invoca está eximido de acreditarla, como toda culpa contractual, o por aplicarse la misma regla del dolo está obligado a establecerla en el juicio.

Se ha fallado que “la circunstancia de que el artículo 44 del Código Civil, equipare el dolo a la culpa grave no significa que ésta deba probarse al igual que aquél”. SOMARRIVA critica esta doctrina por tres razones: a) porque el art. 44 no hace distinciones, sino que equipara en una forma absoluta ambos conceptos; b) porque la norma viene de POTHIER, que le daba al principio un alcance amplio; y c) porque no le parece lógico presumir la culpa grave contractual en circunstancia que ni el dolo ni la mala fe se presumen por expresa disposición del legislador”.

RODRÍGUEZ estima que “si la culpa grave en materia civil se asimila (la ley dice “equivale”) al dolo, ello implica que la culpa grave debe también probarse, al igual que el dolo”. Y da sus razones: “si la culpa grave se presumiera (como consecuencia de que deba probarse la diligencia debida por quien está obligado a prestarla) y los efectos de la misma fueran los que corresponden al dolo, ello implicaría que sería más grave y perjudicial incumplir una obligación con culpa grave que incumplirla con dolo”.

Sin embargo, según la mayor parte de la doctrina, la equivalencia no tiene alcances probatorios. De consiguiente, tratándose de culpa, cualquiera que ella sea, incluso, la grave, se presume siempre, por lo que corresponde al deudor probar el descargo, acreditando que

ha empleado la diligencia debida; en cambio en el dolo, la prueba corresponde al acreedor (CLARO SOLAR, ALESSANDRI, FUEYO). El primero de estos autores expresa que la equivalencia entre la culpa grave y el dolo no pueden llegar a significar que sean una misma cosa, pues si así fuere el artículo 44 no habría dado dos definiciones. Y agrega que “el artículo 1547 no hace referencia al dolo, sino únicamente a la culpa y no habría razón para suponer que no se haya referido a la culpa lata al exigir al deudor la prueba del cuidado que según la naturaleza del contrato se le exige”. El art. 1547 inc. 3º que presume la culpa en materia contractual no distingue entre las clases de culpa.

vi. De qué culpa responde el deudor

La primera regla que debe aplicarse es que el deudor responde de la culpa a que se haya obligado. Ello porque, esta es una materia, en que las partes, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, pueden alterar las reglas de responsabilidad establecidas en la ley, con algunas limitaciones. Así lo señala el inciso final del artículo 1547: “Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, *y de las estipulaciones expresas de las partes*”.

Si las partes nada han acordado entra a operar lo dispuesto en el artículo 1547, según el cual, para saber de qué culpa responde el deudor debe distinguirse según el contrato de que se trate, siendo la responsabilidad del deudor mayor en aquellos casos en que él es el único beneficiado y menor, cuando el principal beneficiado es el acreedor. Señala esta disposición: “El deudor no es responsable sino de la culpa lata en aquellos contratos que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima, en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio” (inciso 1º).

Así, por ejemplo, en el contrato de depósito, que sólo beneficia al depositante, el depositario, responde únicamente de culpa grave (art. 2222). En cambio, en el comodato, el comodatario, que es el único beneficiado, responde hasta de culpa levísima (art. 2178). En los contratos conmutativos, en que las partes se benefician recíprocamente, se responde sólo hasta de culpa leve.

Nótese que el que sólo responde hasta de culpa grave, es el que tiene menos responsabilidad, pues está obligado a emplear únicamente aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. El que no emplea este cuidado mínimo tiene una conducta tan descuidada que la ley la asimila al dolo (“Esta culpa en materia civiles equivale al dolo”, art. 44 inciso 1º, parte final).

A la inversa, el que responde de culpa levísima, es el que tiene la mayor obligación de cuidado, pues debe tener aquella “esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en

la administración de sus negocios importantes”. Y es lógico que así sea, pues él es el único que se está beneficiando con el contrato, como ocurre con el comodatario.

Lo normal es que se responda hasta de la culpa leve. Así ocurre con el que administra bienes ajenos, ej. el padre de familia (art. 250), el tutor o curador (art. 391); el mandatario (art. 2129); el agente oficioso (art. 2288); el albacea (art. 1299); el partidor (art. 1329). También responde de esta culpa el que tiene una cosa sujeta a plazo o a condición (arts. 758 inc. 2º, propietario fiduciario; 787, usufructuario; 818 usuario y habitador).

vi. Cláusulas para alterar la responsabilidad de las partes

El inciso final del artículo 1547 permite a las partes alterar el grado de responsabilidad, idea que repite el artículo 1558, inciso final. Luego las partes pueden celebrar distintos pactos para modificar su responsabilidad, haciendo al deudor más o menos responsable de lo que legalmente corresponde.

Sin embargo, esta facultad de las partes tiene como límite el que no se puede eximir de responsabilidad al deudor. Lo anterior, en atención a que como la culpa grave equivale al dolo, ésta no puede condonarse anticipadamente, cosa que precisamente ocurriría si se eximiese de toda responsabilidad al deudor.

vii. La culpa contractual se presume

En la responsabilidad contractual la culpa se presume. Este principio se desprende del artículo 1547 inciso 3º. En efecto, según esta norma “la prueba de diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega”. Si corresponde al deudor probar que ha empleado el cuidado debido, es porque la ley está presumiendo que si incumple es porque no empleó el cuidado a que estaba obligado, que actuó con culpa.

En el artículo 2158 (mandato) se encuentra una excepción a esta regla, en cuanto permite que el mandante se pueda liberar de sus obligaciones “alegando que **el negocio encomendado al mandatario no ha tenido buen éxito, o que pudo desempeñarse a menos costo, salvo que le pruebe culpa**”.

viii. Culpa del deudor por el hecho de personas que dependen de él

Los artículos 1679 y 1590, incisos 1º y 3º, hacen responsable al deudor por el hecho de terceros que dependen de él. La primera de estas normas expresa que “en el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable”; y la segunda, reitera la misma idea.

En el caso de hechos de terceros por quienes no responde el deudor, el acreedor sólo podrá exigir que se le ceda la acción que tenga su deudor contra el tercero autor del daño (art. 1590 inciso final; art. 1677).

2. SEGUNDO REQUISITO: PERJUICIO DEL ACREEDOR

2.1. Concepto

El daño es un requisito obvio de la responsabilidad que surge del propio enunciado “indemnización de perjuicios”. No puede repararse lo que no existe. La ley no ha necesitado decirlo en forma expresa, pero indirectamente fluye de varias disposiciones (1548, 1553 N° 3, 1556 y 1559 N° 2).

El perjuicio o daño -ambos términos son sinónimos- puede definirse como el detrimento, menoscabo o lesión que sufre una persona tanto en su persona como en sus bienes.

Si se produce el incumplimiento de un contrato pero éste no genera perjuicios al acreedor, no hay lugar a la indemnización de perjuicios. El ejemplo que citan los textos, es el del Conservador de Bienes Raíces, que habiéndosele requerido inscribir una hipoteca, sin razones valederas deja de practicarla, faltando así a las obligaciones propias de su cargo. Posteriormente la propiedad sale a remate público y el precio en que se adjudica es tan bajo que aun de haberse inscrito la hipoteca ese acreedor hipotecario no habría alcanzado a pagarse (FUEYO).

2.2. Requisitos

Para que el daño de lugar a reparación, debe reunir las siguientes características: debe ser cierto; no haber sido ya indemnizado, y debe lesionar un derecho o interés legítimos.

(i) **Certidumbre del daño.**

Que el daño sea cierto, quiere significar que debe ser real, efectivo, tener existencia.

Con esto se rechaza la indemnización del *daño eventual*, meramente hipotético, que no se sabe si existirá o no.

Sin embargo, en Francia se ha aceptado una cierta categoría de daño eventual: la *pérdida de una probabilidad u oportunidad* cierta como ocurre en el caso, por ejemplo, de que por negligencia un procurador judicial deje transcurrir un término sin deducir un recurso legal; como no hay forma de determinar si el tribunal superior habría acogido el recurso, el daño es en cierta forma hipotético.

Como indica ALESSANDRI, que el daño sea cierto no elimina la indemnización del *daño futuro*, que no ha sucedido aún, con tal que sea cierto, esto es, que no quepa duda de que va a

ocurrir. En el fondo el lucro cesante es siempre un daño futuro. Por ello no se discute la indemnización del daño futuro cierto.

(ii) El daño no debe estar indemnizado

En principio no puede exigirse la indemnización de un perjuicio ya reparado, pues de lo contrario se configuraría un enriquecimiento ilícito. Y así hay casos en que la víctima tiene acción en contra de varias personas para demandar los daños; por ejemplo, si los autores de un incumplimiento doloso son varios, por ser solidaria la acción (art. 2317), la víctima puede cobrar el total a cualquiera de ellos, pero indemnizada por el demandado no podrá volver a cobrar los daños a otro.

Se presenta en este punto el problema del llamado cúmulo de indemnizaciones, esto es, que la víctima haya obtenido de un tercero ajeno al incumplimiento una reparación total o parcial del daño sufrido. Este tercero podrá ser, por ejemplo, una compañía aseguradora. La solución más aceptada, aunque se ha discutido, pues el hechor se aprovecha para disminuir su responsabilidad liberándose del todo o parte de la indemnización de un acto jurídico que le es totalmente ajeno, es que si tales beneficios tienden a reparar el daño, éste se extingue, ya no existe, y no puede exigirse nuevamente su reparación.

El que ha pagado ésta, por regla general no podrá repetir contra el hechor, a menos que se le cedan las acciones correspondientes, o la ley se las otorgue.

(iii) El daño debe lesionar un derecho o interés legítimo

Lo normal es que resulte lesionado por el incumplimiento contractual un derecho subjetivo, ya sea patrimonial como el de dominio, excepcionalmente extrapatrimonial, como el honor de la persona.

Ahora bien, en el daño a las personas se pueden presentar casos dudosos si la víctima fallece.

En cualquier clase de daños si el afectado perece con posterioridad al acto ilícito, pero sin haber cobrado la indemnización esta es perfectamente transmisible. Pero si la muerte es instantánea, nada transmite a sus herederos, porque nada ha alcanzado a adquirir.

Sin embargo, los que son herederos de la víctima pueden tener un perjuicio personal a consecuencia del fallecimiento de ésta, y en tal caso, concurriendo los requisitos legales, habrá derecho a indemnización pero no la cobran como herederos, sino por el daño personal que experimentan, cuestión que deberá reclamarse conforme a las reglas de la responsabilidad extracontractual.

En esto se encuentran en igual situación que cualquiera otra persona que no sea heredera de la víctima, y a la que el fallecimiento de ésta lesiona un derecho, y por ello se ha concedido indemnización a un hermano del occiso, a quien éste proporcionaba alimentos. El hermano no es heredero forzoso, de modo que si no es llamado por testamento, sólo puede tener derecho de herencia si no es excluido por otros herederos abintestato de mejor derecho, como descendientes y ascendientes. En el caso fallado no tenía derecho a la herencia, no era heredero, pero el hecho ilícito había vulnerado un derecho suyo: el de alimentos.

Pero no sólo hay lugar a la indemnización cuando se vulnera un derecho, sino también un interés legítimo. Se exige sin embargo que el interés sea legítimo, lícito, y por ello en el pasado la doctrina rechazaba en general que los “concubinos” pudiesen cobrar indemnización por los daños personales que les produzca el fallecimiento de su conviviente a causa de un hecho ilícito.

2.3. Clasificación de los perjuicios.

Tradicionalmente la doctrina realiza las siguientes clasificaciones de los perjuicios:

(i) Perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales.

Atendiendo a la naturaleza del bien lesionado, los daños reparables han sido clasificados tradicionalmente en dos grandes categorías: daños materiales o patrimoniales y daños morales o extrapatrimoniales.

Los perjuicios **patrimoniales** son aquellos que inciden en el patrimonio del acreedor, sea porque producen la disminución efectiva de dicho patrimonio o la pérdida de una legítima ganancia.

Por su parte, son **extrapatrimoniales** aquellos que sin afectar el patrimonio del acreedor, afectan su honra o sus sentimientos. Daño moral es el que afecta los atributos o facultades morales o espirituales de la persona. En general, es el sufrimiento que experimenta una persona por una herida, la muerte de una persona querida, una ofensa a su dignidad u honor, la destrucción de una cosa de afección, etc. Como han dicho otras sentencias, es el dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

Durante muchos años se aceptó como dogma que el daño moral no se indemnizaba en materia contractual. Sin embargo, se aceptaba su indemnización en la responsabilidad extracontractual, en virtud de existir la regla del art. 2329, según la cual “Por regla general *todo daño* que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”. Faltaba, se decía, para la responsabilidad contractual una norma como la del art. 2329.

Esta solución resulta manifiestamente injusta pues no se ve por qué razón, por ejemplo, si una persona que va dentro un bus que choca y sufre lesiones (responsabilidad contractual), no tiene derecho a que se le indemnice por los padecimientos que le produce este accidente; en cambio, sí lo tiene si estando en la calle, esperando el bus, es arrollada por éste y sufre el mismo tipo de lesiones (responsabilidad extracontractual).

Desde hace varios años, la doctrina (FUEYO, TOMASELLO) viene señalando que hay en este trato discriminatorio, una grave inconsecuencia. Pero la jurisprudencia se había mantenido invariable y sólo recién ahora empieza a cambiar. Y ya encontramos algunos fallos que aceptan indemnizar el daño moral.

¿Qué razones se han dado para no indemnizar el daño moral? 1. En primer lugar, la ya explicada, que **faltaba una norma** como la del art. 2329 aplicable a la responsabilidad extracontractual. 2. En seguida, que el artículo 1556 establece que la indemnización de perjuicios comprende el **daño emergente y lucro cesante**, conceptos éstos de claro contenido patrimonial; y 3. Que es **difícil su prueba y evaluación**.

En realidad ninguno de los argumentos es categórico. En efecto, si falta la norma, nos encontramos frente a una laguna legal, que el juez en conformidad al artículo 24 del Código Civil, debe llenar recurriendo a los principios generales del derecho y a la equidad natural. En cuanto a que el art. 1556 no lo contempla, es cierto, pero tampoco lo prohíbe. Finalmente, no es serio sostener que no debe indemnizarse por ser difícil de probar y de evaluar, desde que en materia extracontractual el problema es el mismo y se pagan.

En todo caso cabe señalar que el artículo 1556, no es un buen argumento para acoger el daño moral, pues esa disposición se tomó del Código de Napoléon y en especial de POTHIER, que sólo autorizaban la indemnización por daños patrimoniales. La reparación del daño moral, no fue siquiera planteada por POTHIER, quien, por lo demás, entendía “por daños y perjuicios la pérdida que uno ha sufrido y las ganancias que ha dejado de hacer”. Sin embargo, en Francia con una disposición semejante a nuestro artículo 1556 (art. 1149), se viene aceptando desde hace mucho tiempo la indemnización del daño moral en materia contractual, entendiéndose agotado el debate.

En Chile, hoy día, frente al texto constitucional -art. 19 Nros. 1 inc. 1º y 4, que asegura a todas las personas tanto el derecho a la integridad física y psíquica (Nº 1), como el respeto a la intimidad y vida privada, y el honor-, no parece sostenible seguir negando la indemnización del daño moral. En estas disposiciones constitucionales y no en el artículo 1556, deben fundarse las demandas por daño moral.

Pero debe quedar claro también que cualquier incumplimiento contractual no puede ser fuente de daño moral. Así, por ejemplo, si la obligación incumplida es la no entrega de 100

sacos de porotos, no parece razonable pensar que ello pueda producir un daño moral al acreedor. En cambio, si una persona lleva a achicar el anillo de compromiso de sus padres, y el joyero lo pierde, sí que se ve como factible la indemnización. Lo mismo si se lleva a enmarcar la fotografía única de un antepasado lejano, y el establecimiento la pierde, etc. Uno de los primeros casos acogidos por la jurisprudencia, se trataba de un banco que en forma descuidada entregó a un tercero talonarios de la cuenta corriente de un cuentacorrentista. El tercero aprovechando estos talonarios giró cheques que fueron protestados, lo que ocasionó un daño moral al cuentacorrentista al lesionarse su crédito, su honor, su prestigio y buen nombre.

(ii) Daño emergente y lucro cesante.

El artículo 1556 dice que *“la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente”*. La ley no define estos conceptos.

Es **daño emergente** la disminución efectiva del patrimonio del acreedor como consecuencia de la infracción de la obligación.

Por su parte, el **lucro cesante** es la pérdida de la legítima ganancia que hubiera obtenido el acreedor si el deudor hubiera cumplido la obligación en forma íntegra y oportuna.

Ej: se contrata a Pavaroti, para que venga a dar un concierto; se gasta en propaganda, viajes, etc, pero en definitiva el artista no viene. El daño emergente, está representado por lo que se gastó en propaganda, viajes, etc. El lucro cesante, está determinado por la utilidad que el empresario pensaba obtener con este concierto.

En conformidad al artículo 1556 ambas clases de perjuicios deben ser indemnizados, salvo que la ley limite la indemnización sólo al daño emergente. Así ocurre, por ejemplo, en los artículos 1930 inc. final, 1932, 1933 del Código Civil y 209 y 210 del Código de Comercio (contrato de transporte).

No es fácil la prueba del lucro cesante. Por la misma razón, se debe apreciar la prueba con mayor liberalidad. Así lo entiende GATICA: *“el lucro cesante, a diferencia del daño emergente, es difícil de establecer, por su carácter esencialmente eventual, que lo transforma en un principio jurídico lleno de vaguedades e incertidumbres”*. Y agrega que *“por la misma razón el legislador ha prescindido de dictar normas al respecto, dejando entregada a la prudencia del tribunal la sana aplicación de los hechos de la causa”*.

(iii) Perjuicios directos e indirectos.

Esta clasificación se encuentra reconocida en el art. 1558. Los perjuicios **directos** son los que surgen como consecuencia directa y necesaria del incumplimiento de la obligación. En cambio, los **indirectos** si bien surgen como consecuencia de la infracción contractual, no encuentran en ésta una causa directa, sino indirecta o remota.

En el clásico ejemplo de POTHIER para ilustrar el concepto de daño indirecto, el suicidio del comprador de una vaca enferma, que luego de ser introducida en el rebaño, contagia y causa la muerte de todas las demás ocasionándole la ruina, no puede atribuirse razonablemente al hecho del vendedor que oculta el vicio.

En conformidad al artículo 1558 sólo los perjuicios directos pueden ser indemnizados, y no así los indirectos, pues respecto de éstos faltará un requisito propio de la responsabilidad, como lo es la relación de causalidad entre la infracción y el daño sufrido; lo anterior, salvo que las partes hubiesen acordado algo distinto.

(iv) Perjuicios directos previstos y directos imprevistos.

Los perjuicios directos pueden clasificarse en **previstos**, que son aquellos que las partes previeron o pudieron razonablemente prever al tiempo de contratar; y por otra parte son **imprevistos** los que no se previeron ni se encontraban en situación de prever a la fecha de celebración del contrato.

En la jurisprudencia italiana hay un caso célebre: un comerciante compró una partida de castañas para venderlas en El Cairo, donde obtendría un precio extraordinario; como no se le entregaron oportunamente, pretendió cobrar como lucro cesante la diferencia de precio que habría obtenido en la venta; los tribunales aceptaron únicamente la ganancia que habría obtenido en Italia misma, porque la otra no era previsible ni había sido prevista al tiempo del contrato. Otro ejemplo que también es clásico es de una persona que viaja con un maletín con objetos valiosos y es hurtado por un empleado de la empresa. El robo del maletín es perjuicio previsto, pero no el valor anormal de los objetos, porque está totalmente al margen de la previsión de la empresa que una persona traslade cosas preciosas sin avisarle para que se tomen las precauciones correspondientes.

En conformidad al art. 1558, si el deudor obró con dolo deberá indemnizar tanto los perjuicios previstos como imprevistos; en caso contrario sólo responde de los daños previstos.

2.4. Prueba de los perjuicios

La prueba de los perjuicios corresponde al actor, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil. Por excepción, en algunos casos no es necesario probarlos:

- a) Cuando existe una cláusula penal, en virtud de lo establecido en el artículo 1542 “habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio; y
- b) Tratándose de la indemnización moratoria en el incumplimiento de una obligación de dinero, en conformidad al artículo 1559 N° 2: “el acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando sólo cobra intereses, basta el hecho del retardo”.

En relación con esta materia conviene precisar que, en conformidad al artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, el acreedor que ha sufrido un perjuicio proveniente del incumplimiento de un contrato, puede adoptar dos caminos: a) demandar su pago, litigando inmediatamente sobre su especie y monto (es decir la descripción detallada de los mismos y su monto) o b) solicitar únicamente que se declare su derecho a cobrar perjuicios y se le reserve el derecho para discutir la especie y monto de ellos en juicio aparte o en la ejecución del fallo. Si se elige el primer camino, la sentencia no puede reservar a las partes el derecho de discutir la especie y monto de los perjuicios en la ejecución del fallo o en otro juicio diverso; y si lo hace, la sentencia debe anularse por no contener la decisión del asunto controvertido.

Se ha fallado que no se necesita señalar en la demanda una suma determinada como indemnización, basta con solicitar que se paguen los perjuicios experimentados, cuyo monto queda entregado a la apreciación del tribunal. También se ha fallado que cuando se litiga sobre la especie y monto de los perjuicios, el tribunal puede ordenar pagar una cantidad diferente, menor que la demandada.

Una jurisprudencia reiterada de los tribunales ha declarado que esta disposición (art. 173 del C.P.C.) no se aplica en materia extracontractual, donde, en consecuencia, tanto las bases, la especie y el monto de los perjuicios deben quedar fijados en el mismo juicio en que se discute la procedencia de la indemnización, y no puede reservarse parte alguna para la ejecución u otro juicio. Con todo, existen fallos en sentido contrario.

3. TERCER REQUISITO: RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL INCUMPLIMIENTO Y LOS PERJUICIOS

3.1. Concepto

El tercer requisito de la responsabilidad contractual consiste en la necesidad de que exista una relación de causa a efecto entre el incumplimiento y el daño.

En el Código Civil, esta exigencia se desprende, primeramente, del artículo 1556 “la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, *ya provengan de*

no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento...”; y con más claridad todavía, del artículo 1558, en cuanto establece que en caso de incumplimiento con dolo el deudor “es responsable de todos los perjuicios que fueron una *consecuencia inmediata o directa* de no haberse cumplido la obligación de haberse demorado su cumplimiento “.

Consecuencia importante de lo anterior es que no se indemnizan los perjuicios indirectos ni aun en el caso de haberse incumplido con dolo (art. 1558).

Hay un ejemplo clásico de POTHIER en materia contractual para distinguir una y otra clase de perjuicios: el del agricultor que compra unas vacas y resultan enfermas, contagiando al resto del ganado. La pérdida de éste va conduciendo en sucesivas calamidades al agricultor a no poder explotar el fundo hasta llegar a la quiebra y el suicidio. En este dramático ejemplo, el perjuicio directo es de las vacas enfermas y el contagio; todos los restantes no eran consecuencia necesaria del cumplimiento imperfecto del deudor, y pudieron ser evitados.

3.2. Teorías acerca de la causalidad

Este elemento de la responsabilidad ha sido objeto de numerosas discusiones y teorías, muchas de las cuales se han desarrollado a propósito de la responsabilidad extracontractual, y especialmente en el Derecho Penal.

Las múltiples doctrinas que se han forjado para determinar la causa en materia de responsabilidad pueden agruparse en dos grandes corrientes: las teorías de carácter empírico o naturalísticas y las teorías normativas. Las primeras intentan localizar el momento causal observando los fenómenos empíricos o naturales, y emplazando la conducta humana dentro del cortejo de acontecimientos que ocurren en la naturaleza según las leyes físicas. Las segundas, si bien parten de la observación del suceder causal empírico, estiman imprescindible, para asignar el rol de causa, efectuar valoraciones jurídicas o normativas que superen el marco de las previsiones y conexiones de la mera causalidad física.

(i) **Teoría de la equivalencia de las condiciones.**

Esta teoría, la más clásica y también denominada de la “*condictio sine qua non*”, postula que no es posible distinguir de entre las varias condiciones que concurren para producir un resultado (dañoso), cuál es más causa que otra. Todas ellas son equivalentes en cuanto a la causalidad. De esta forma, aunque hayan concurrido otros factores, si el hecho voluntario del eventual autor del daño **es una de las condiciones que intervinieron en la producción del resultado lesivo, vale como causa, y puede establecerse una relación de causalidad suficiente para establecer la responsabilidad.**

Para conocer si un factor es verdaderamente condición del resultado, y por tanto equivalentemente causa, la teoría utiliza el procedimiento de la **supresión mental hipotética**. Así, si se busca saber si un factor es condición (y por ende causa) del resultado, se debe reconstruir mentalmente la situación sin el factor analizado: si en este supuesto el resultado igualmente hubiere acaecido, quiere decir que dicho factor no fue una condición del mismo. En cambio, si al prescindir mentalmente del factor en análisis el resultado no se hubiera producido, entonces dicho factor tiene la categoría de condición (*condictio sine qua non*: condición sin la cual el resultado no hubiera tenido lugar). Y siendo condición, eso lo habilita para ser tratado como causa del resultado, en el sentido que sin su concurrencia el hecho dañoso no habría tenido lugar.

Esta teoría ha sido criticada, entre otros motivos, por cuanto: (a) la supresión mental hipotética sólo es eficaz si se ha hecho un juicio previo sobre si el factor suprimido es o no causa del resultado; (b) Asimismo se observa que en casos de causalidad acumulativa en que actúan dos causas independientes que por su confluencia producen el resultado, pero que si se eliminara mentalmente cualquiera de ellas debería llegarse a la conclusión que ninguna de ellas es causa, produciendo la impunidad del hecho; (c) aplicada con rigor, esta teoría conduce a una extensión exagerada de la responsabilidad, ya que cualquier hecho situado en la cadena de acontecimientos en la que luego se inserta el resultado podía ser considerado causa del mismo.

(ii) Teoría de la causa adecuada.

Esta teoría intenta corregir las deficiencias de la teoría de la equivalencia de las condiciones, haciendo una distinción entre las condiciones que concurren en la producción del daño.

Así, entre todas las causas que concurren a la producción del daño debe elegirse aquella que **normalmente ha de producirlo**, o sea, es necesario preferir el acontecimiento que ha desempeñado el **papel preponderante en la ocurrencia del perjuicio**.

Si bien esta doctrina tiene el mérito de limitar la extensión de la causalidad, también ha sido objeto de críticas. Las mayores dificultades que plantea la doctrina de la causa adecuada se refieren a que introduce también en sede la atribución objetiva del daño al hecho ilícito un elemento de *previsibilidad* que es propio de la culpabilidad, confundiendo ambos elementos.

(iii) Teoría de la relevancia jurídica.

Conforme a esta doctrina, para saber qué condiciones son causas en el plano empírico se reconoce la validez de la teoría de la equivalencia: todas las condiciones son causas desde el punto de vista meramente natural.

Pero este análisis no basta al jurista, ya que, jurídicamente, no todas las causas son equivalentes. Para el derecho sólo pueden ser tomados en cuenta los procesos relevantes. La relevancia de la causa se determina siguiendo criterios de previsibilidad utilizados por la teoría de la adecuación.

(iv) Teoría de la imputación objetiva.

Esta teoría fue desarrollada primeramente por LARENZ, para quien la relación de causalidad es una investigación acerca de la existencia de una imputación, es decir, el intento de delimitar dentro de los acontecimientos accidentales un hecho que puede ser considerado como propio (imputable) de un hombre. Para este autor, habrá causalidad (imputación) cuando el hecho, con sus consecuencias, fue previsible y dominable o dirigible.

En base a lo anterior, el penalista ROXIN elaboró la teoría de la imputación objetiva, conforme a la cual la causalidad debe ser jurídicamente entendida como imputación medida por parámetros objetivos. Sólo un resultado imputable al acto del autor puede generar responsabilidad.

A modo de síntesis, RODRÍGUEZ afirma que lo cierto es que **no existe causalidad jurídica si está ausente la causalidad material o física**. Pero si el acto material está absolutamente desvinculado del factor de imputación (culpa, dolo o riesgo), es causalmente neutro en el plano jurídico.

3.3. La causalidad en la responsabilidad contractual

Como señala RODRÍGUEZ, en general todas las teorías sobre la causa están concebidas pensando en la responsabilidad extracontractual, en circunstancias que en materia contractual hay un **hecho que es la fuente necesaria de la responsabilidad: el incumplimiento contractual**. Todo daño contractual ha de estar fundado en el hecho de no haberse desplegado la conducta asumida por el deudor en el contrato. En consecuencia hay una “**causa necesaria**”, sin la cual no surge responsabilidad alguna. Esta característica difiere absolutamente de la responsabilidad extracontractual, en cuyo campo cualquier hecho imputable al demandado, ejecutado dolosa o culpablemente o en contravención con un mandato legislativo expreso, puede generar responsabilidad para el deudor.

Por lo anterior, la causalidad en materia contractual consiste en determinar si el daño que se demanda fue provocado por el incumplimiento o por otra causa. Por ello, el problema causal de la responsabilidad se resuelve por el expediente de **suprimir mentalmente el incumplimiento de la relación obligacional**: si el daño perdura, el incumplimiento no es la causa del mismo; en caso contrario, la causa del efecto dañoso es el incumplimiento.

3.4. Interrupción del nexo causal

La interrupción del nexo causal implica que entre el hecho y el daño actúa una causa extraña que interfiere la relación causal. En otras palabras, el daño no puede ser atribuido al deudor, porque el daño no proviene causalmente de su acción, sino que de otro hecho, y por ende el deudor se encuentra exonerado de responsabilidad.

De conformidad a los arts. 1547 inc. 2º, 1558 inc. 2º, 1672 inc. 2º, 1677 y 1827 las causas extrañas que interrumpen el nexo causal son tres: el caso fortuito o fuerza mayor, el hecho de un tercero, y el hecho o culpa del acreedor, todas las cuales se analizarán al estudiar las causales de exención de responsabilidad.

4. CUARTO REQUISITO: MORA DEL DEUDOR

4.1. Generalidades

El último requisito de la indemnización de perjuicios es la denominada “mora del deudor”, exigida por el artículo 1557 en los siguientes términos: “se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora...”. Reitera esta misma idea el artículo 1538, en materia de cláusula penal: “Háyase o no estipulado un término dentro del cual deba cumplirse la obligación principal, el deudor no incurre en la pena sino cuando se ha constituido en mora...” (es necesario considerar que “la pena” es una forma de regular la indemnización de perjuicios).

Esa exigencia rige tanto para la indemnización compensatoria como para la moratoria (en este sentido CLARO SOLAR, ALESSANDRI, FUEYO, ABELIUK).

Se afirma, que en las obligaciones de no hacer, no se requiere el requisito de la mora del deudor, pues en conformidad con el artículo 1557, en este tipo de obligaciones, la indemnización se debe desde el momento de la contravención (STITCHKIN, ABELIUK). RAMOS cree que también en este caso se requiere mora, con la diferencia que ésta se produce por el solo hecho de la contravención.

4.2. Concepto

ABELIUK define la mora del deudor (*mora solvendi*) “como el retardo imputable en el cumplimiento de la obligación unido al requerimiento o interpelación por parte del acreedor”. En términos semejantes STITCHKIN: “retardo culpable en el cumplimiento de la obligación más allá de la interpelación del acreedor”.

4.3. Requisitos

1. Que el deudor retarde el cumplimiento de la obligación.
2. Que el retardo sea le imputable (con dolo o culpa).
3. Interpelación del acreedor; y
4. Que el acreedor haya cumplido su obligación o se allane a cumplirla.

4.3.1. Que el deudor retarde el cumplimiento de la obligación

El retardo es el antecedente necesario de la mora, pero sólo el antecedente, no la mora misma, pues el retardo puede deberse a caso fortuito o fuerza mayor, caso en que no habrá mora.

Se debe distinguir, entonces, entre exigibilidad, retardo y mora;

- a) La obligación es exigible cuando no se halla sujeta a modalidades suspensivas.
- b) Se retarda el cumplimiento de la obligación cuando no se cumple en la oportunidad debida, pero el solo retardo no implica mora (que exige otros requisitos: imputabilidad e interpelación). Nuestro Código en algunos casos habla de “la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito” (véase el artículo 1558, inciso 2º), señalando que no da lugar a la indemnización de perjuicios. Lo que la norma quiere significar es que no hay indemnización de perjuicios, porque si hay caso fortuito no puede haber mora ya que éste extingue la obligación.
- c) La mora supone el retardo imputable del deudor más allá de la interpelación hecha por el acreedor (arts. 1551 y 1558 inc. 1º).

El artículo 1537, en materia de cláusula penal, distingue con mucha claridad entre mora y simple retardo.

4.3.2. Que el retardo sea imputable del deudor

Es decir, para que se configure la mora es necesario que el atraso en cumplir sea debido al dolo o culpa del deudor.

El artículo 1558, claramente exige el requisito de la imputabilidad, al decir en el inciso 1º: “Si no se puede imputar dolo al deudor...” para agregar en el inciso siguiente: “La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios”. Lo que quiere expresar la norma es que si hay caso fortuito o fuerza mayor, no hay indemnización de perjuicios porque no hay mora.

4.3.3. Interpelación del acreedor

Se define como el acto por el cual el acreedor hace saber al deudor que su retardo le causa perjuicios.

Hay tres formas de interpelación, que están contenidas en el artículo 1551, que a la letra señala: “El deudor está en mora, 1º Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora; 2º Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla; 3º En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor”.

Atendido lo dispuesto en esta disposición, la interpelación, se produce en cualquiera de estos tres casos, constituyendo la regla general, el contemplado en el N° 3.

La doctrina llama a la interpelación del N° 1, contractual expresa; a la del N° 2, contractual tácita; y a la del N° 3, judicial.

i. Interpelación contractual expresa (art. 1551 N° 1)

Opera cuando las partes han establecido un plazo en el contrato, para que el deudor cumpla su obligación. Cumplido el plazo se van a producir coetáneamente tres situaciones jurídicas: exigibilidad, retardo y mora. Por el solo hecho de cumplirse el plazo, el deudor queda constituido en mora, salvo que la ley exija que se le requiera para constituirlo en mora. Así ocurre, por ejemplo, en el contrato de arriendo: artículo 1949 “para que el arrendatario sea constituido en mora de restituir la cosa arrendada, será necesario requerimiento del arrendador, aun cuando haya precedido desahucio...”; en el artículo 1977, cuando el arrendatario se encuentra en mora de pagar la renta, es necesario dos reconvenciones, entre las cuales debe mediar a lo menos 4 días.

Para que nos encontremos en el caso del N° 1 del artículo 1551, es preciso que se trate de un plazo convenido por las partes, pues la norma habla de no haberse cumplido la obligación “dentro del término estipulado”. Por ello, no rige, por ejemplo en el caso en que haya sido establecido por el testador (para pagar un legado), caso éste en que será necesario para constituir en mora al deudor requerirlo judicialmente.

Si se trata de obligaciones de cumplimiento fraccionado, la mora respecto de cada cuota, se irá produciendo al vencimiento del plazo establecido para su pago. Ello, sin perjuicio, de que pueda haberse convenido una cláusula de aceleración que pueda producir la caducidad del plazo y, por consiguiente, la mora respecto de todo el saldo insoluto.

ii. Interpelación contractual tácita (art. 1551 N° 2)

Se le llama interpelación tácita porque a pesar de que no se ha establecido en forma expresa un plazo dentro del cual debe cumplirse la obligación, ésta por su propia naturaleza y por la forma como fue convenida, tiene un plazo tácito, para cumplirse. Ej. El traje de novia tiene que estar terminado y entregado antes del día de la boda; los disfraces antes de la fiestas de carnaval; la máquina trilladora, antes de la trilla; la construcción del stand para una feria, antes de que esta se abra, etc.

iii. Interpelación judicial (o extracontractual) (art. 1551 N° 3)

La interpelación judicial constituye la regla general, como se desprende de la forma como comienza el N° 3 “En los demás casos...”

La regla es entonces que para que el deudor quede constituido en mora se le debe demandar. Problema aparte es determinar qué entiende el N° 3, por reconvenir judicialmente al deudor. Está claro que no es necesaria una gestión judicial en que específicamente se solicite que se constituya en mora al deudor. Se ha entendido que cualquier gestión judicial destinada a que el acreedor haga efectivos sus derechos para el caso de que el deudor incumpla es suficiente requerimiento judicial. Así satisfacen este objeto, una demanda en que se pida el cumplimiento del contrato o su resolución; o si se demandan perjuicios, etc. La Corte Suprema ha dicho que no es reconvención suficiente, la gestión de preparación de la vía ejecutiva. ABELIUK, discrepa de este fallo, pues una diligencia de este tipo supone el cese de la inactividad del acreedor y el conocimiento del deudor de que su incumplimiento está causando perjuicios.

¿En qué momento queda el deudor constituido en mora? RAMOS y ABELIUK entienden que lo es cuando se le notifica válidamente la demanda, y así lo ha entendido en general, la jurisprudencia. Hay fallos, sin embargo, que dicen que la constitución en mora se produce desde la contestación de la demanda.

Se ha fallado que para que el deudor quede constituido en mora, el requerimiento debe hacerse ante juez competente, decisión que para ABELIUK es discutible, pues aunque el tribunal sea incompetente, queda clara la intención del acreedor de hacer efectiva la obligación.

4.3.4. Si el contrato es bilateral, que el acreedor haya cumplido su propia obligación o se allane a cumplirla en la forma y tiempo debido

Es el último requisito de la mora, y lo contempla el artículo 1552: “En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro

no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”. Esta norma contiene el principio denominado “la mora purga a la mora”.

Como se indicó con anterioridad, buena parte de la doctrina tradicional estima que este artículo contiene la llamada “excepción de contrato no cumplido”, que es aquella que tiene la parte de un contrato bilateral que es demandada por la otra parte para que cumpla el contrato, a fin de que se rechace la demanda si esta última no ha cumplido o no se encuentra llana a cumplir las obligaciones que ella ha contraído. Como se observó en su oportunidad, es discutible que el art. 1552 consagre tal excepción, entre otros motivos por el hecho que su claro tenor no es otro que el de indicar que en un contrato bilateral no se configura el requisito de la mora (y por tanto es improcedente la acción de perjuicios) en el evento que quien demanda no haya cumplido ni esté llana a cumplir con sus obligaciones.

4.4. Efectos de la mora

Los efectos que produce la mora son los siguientes:

1. El acreedor puede demandar indemnización de perjuicios.
2. El deudor se hace responsable del caso fortuito.
3. El riesgo pasa a ser del deudor.

4.4.1. El acreedor puede demandar indemnización de perjuicios

Justamente por ello, se estudia la mora, como requisito de la indemnización de perjuicios. Este efecto lo establece el artículo 1557 del Código Civil: “se debe indemnización de perjuicios *desde* que el deudor se ha constituido en mora”.

Aclarado que sin constituir al deudor en mora, no hay indemnización de perjuicios, cabe resolver otro problema. Reconvenido el deudor ¿desde cuándo se deben pagar los perjuicios? ¿Desde la fecha de la constitución en mora o desde que se produjo el incumplimiento?

FUEYO afirma que constituido el deudor en mora, debe éste pagar los perjuicios producidos desde el retardo, pues no hay ninguna norma que descarte la zona intermedia entre el simple retardo y la interpelación judicial. Agrega que se trata de sancionar un acto ilícito e injusto. ABELIUK, en cambio, distingue entre los perjuicios compensatorios y los moratorios. Los primeros se habrán siempre producido antes de la constitución de la mora por el sólo incumplimiento, como lo prueba el art. 1672, según el cual si la cosa perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación subsiste pero varía de objeto, siendo obligado el deudor al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. El precio, agrega ABELIUK, corresponde evidentemente a la indemnización compensatoria. En cambio, los perjuicios moratorios sólo se van a generar con la constitución en mora, como parece demostrarlo el

artículo 1559 N° 1 en las obligaciones de dinero, en cuanto dicha norma expresa que si la deuda no devengaba intereses “empiezan a deberse los legales”.

4.4.2. El deudor se hace responsable del caso fortuito

Así lo dice el artículo 1547 inciso 2°. Esta regla tiene una excepción, en que a pesar de la mora el deudor, éste no responde del caso fortuito. Ello se produce si el caso fortuito hubiese sobrevenido a pesar de haberse cumplido oportunamente la obligación (arts. 1547 inc. 2°, 1672 inc. 2°, 1590). Este último hecho deberá probarlo el deudor (art. 1674 inciso 2°: “Si estando en mora pretende que el cuerpo cierto habría perecido igualmente en poder del acreedor, será también obligado a probarlo”).

4.4.3. El riesgo de la especie o cuerpo cierto debida que normalmente es del acreedor, pasa al deudor

Por regla general, de acuerdo el artículo 1550, en nuestra legislación el riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se debe es del acreedor, salvo algunas excepciones, entre las que figura que el deudor esté colocado en mora, en cuyo caso “será a cargo del deudor el riesgo de la cosa, hasta su entrega”.

4.5. Mora del acreedor

4.5.1. Concepto

Se puede decir que la mora del acreedor consiste en la resistencia ilegítima al cumplimiento de la obligación del deudor. Esta mora no debe confundirse con la excepción de contrato no cumplido, por cuanto en ella el acreedor no está rechazando infundadamente el cumplimiento de la obligación del deudor, sino que ha incumplido una obligación propia.

El Código no ha reglamentado en forma orgánica la mora del acreedor (*mora accipiendi*), pero en varias disposiciones se refiere a ella: arts. 1548, 1680, 1827, 1559 (que habla de la repugnancia del acreedor a recibir la cosa).

4.5.2. ¿Desde cuándo está en mora el acreedor?

Según algunos desde que el deudor haya debido recurrir a pagar por consignación pues es el procedimiento que el legislador ha establecido para que el deudor cumpla su obligación ante la negativa del acreedor. ABELIUK no está de acuerdo ya que esta posición confunde dos cosas: la consignación es un pago, extingue la obligación del deudor, mientras la mora del acreedor no libera al deudor sino que disminuye su responsabilidad. Según otros, debe aplicarse por analogía el art. 1551 N° 3 y concluir que estará en mora desde que sea judicialmente reconvenido. Finalmente CLARO SOLAR estima, como la mayor parte de la

doctrina, que basta cualquier ofrecimiento del deudor, incluso extrajudicial, para constituir en mora al acreedor. Así lo demostraría el artículo 1680, que no hace ninguna exigencia especial bastando que la especie o cuerpo cierto sea ofrecida al acreedor.

4.5.3. Efectos de la mora del acreedor

Los efectos que se producen con la mora del acreedor son los siguientes:

1. Disminuye la responsabilidad del deudor, pues sólo va a responder de la culpa grave o dolo en el cuidado de la cosa (1680 y 1827). Además queda relevado de los perjuicios moratorios.
2. El acreedor debe indemnizar los perjuicios que se sigan de no recibir la cosa, como lo prueba el artículo 1827 ubicado en la compraventa pero de alcance general: “Si el comprador se constituyere en mora de recibir abonará al vendedor el alquiler de los almacenes, graneros o vasijas en que se contenga lo vendido”.
3. Si el deudor tuvo que pagar por consignación, debe pagar las expensas de la oferta o consignación válidas (art. 1604).

VI.3.

AVALUACIÓN DE PERJUICIOS

Hay tres formas de evaluar los perjuicios: judicial, legal, y convencional (cláusula penal).

Lo normal viene a ser la evaluación judicial, pues la legal, sólo procede respecto de las obligaciones de dinero; y la convencional, supone un acuerdo de las partes que no siempre se da.

1. AVALUACIÓN JUDICIAL

1.1. Introducción

Es la que hace el juez. Para ello, éste debe pronunciarse sobre tres cuestiones:

- a) Determinar si procede el pago de la indemnización, para lo cual el tribunal tendrá que ver si se cumplen los requisitos generales estudiados.
- b) Determinar los perjuicios que deben indemnizarse y su naturaleza; y

- c) Fijar el monto de los perjuicios.

1.2. Perjuicios que deben indemnizarse

Según se ha estudiado al analizar los perjuicios como requisito de la responsabilidad contractual, es necesario distinguir:

- (i) En conformidad a la doctrina moderna, deben indemnizarse tanto los daños patrimoniales como extrapatrimoniales (morales), lo que deberá resolverse caso a caso.
- (ii) En conformidad al art. 1558, sólo se indemnizan los perjuicios directos, y no los indirectos.
- (iii) En conformidad al art. 1558, si el deudor obró con dolo debe indemnizar tanto los daños previstos e imprevistos; en caso contrario, sólo debe indemnizar los previstos.
- (iv) En conformidad al art. 1556, se deben indemnizar tanto el daño emergente como el lucro cesante, a menos que la ley limite la reparación al primero.

Sin perjuicio de las reglas legales indicadas, cabe indicar que **las partes pueden alterar las reglas sobre los perjuicios a indemnizar**. Así lo consigna el inciso final del art. 1558: “*Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas*”. Las partes podrían convenir no sólo que se indemnicen los perjuicios indirectos y los imprevistos, aunque no haya dolo o culpa grave, sino cualquier otra estipulación, como que no se indemnice el lucro cesante, que se reparen los daños meramente morales, y aún los inciertos, eliminar toda responsabilidad con ciertas limitaciones, etc. En todo caso, debe considerarse que estas cláusulas encuentran como límite el art. 1465, en cuanto prohíbe condonar el dolo futuro.

2. AVALUACIÓN LEGAL

2.1. Concepto y Naturaleza Jurídica

La avaluación legal de los perjuicios está establecida en el art. 1559, que la limita exclusivamente a la indemnización moratoria, que se genera por el incumplimiento de una obligación de dinero: “Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios *por la mora* está sujeta a las reglas siguientes...”.

¿Por qué sólo contempla la indemnización de perjuicios moratoria y no la compensatoria? La explicación es simple: en la indemnización compensatoria se paga una suma de dinero, que equivale al cumplimiento íntegro de la obligación. Pero si la deuda es de dinero, la suma que se paga “no equivale” al cumplimiento íntegro, sino que “es” el cumplimiento íntegro.

Cabe señalar que aun cuando el punto se ha discutido, no se ve una buena razón para estimar que respecto de esta indemnización, no se requiera constituir en mora al deudor. RAMOS piensa que sí es necesario constituirlo, por aplicación de las reglas generales. En el mismo sentido ABELIUK.

2.2. Características de la liquidación legal

1. El artículo 1559 es una disposición supletoria y excepcional. Supletoria porque rige sólo a falta de pacto entre las partes; excepcional -doblemente excepcional podríamos agregar- porque se refiere sólo al incumplimiento de las obligaciones de dinero y únicamente a la indemnización moratoria.
2. Cuando sólo se cobran intereses, los perjuicios se presumen, situación absolutamente excepcional, ya que la regla es que deben probarse.
3. Lo anterior, se explica porque los intereses representan el perjuicio que el acreedor experimenta si no se le paga con oportunidad el dinero que se le debe, pues cabe suponer que obtenida esa suma podría haber ganado intereses con el simple expediente de depositarlos en una cuenta de ahorro bancaria.
4. El acreedor, aparte de los intereses, puede cobrar otros perjuicios, pero para ello deberá probarlos, de acuerdo a las reglas generales.

2.3. Reglas del art. 1559

De acuerdo al art. 1559, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:

- **Regla primera del art. 1559.** *“Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos” (1559 N° 1).*

Para entender esta regla es indispensable recordar los distintos tipos de interés: legal, corriente, convencional. Hoy, en virtud del art. 19 de la Ley N° 18.010 debe entenderse por interés legal el corriente.

Luego, en conformidad a esta regla, habrá de distinguirse varias situaciones: a) que las partes hayan pactado intereses convencionales y que estos sean superiores al interés legal (corriente), se siguen debiendo los intereses convencionales, b) que las partes no hayan pactado intereses o que pactándolos han sido inferiores al legal, se empiezan a generar los

intereses legales (corrientes); y c) si se está frente a una disposición que autorice el cobro de intereses corrientes (después de la ley N° 18.010 hay que entender esta frase como el cobro de otros intereses) en ciertos casos, no rigen las reglas anteriores.

- **Regla segunda del artículo 1559.** *“El acreedor no tiene necesidad de justificar intereses cuando sólo cobra intereses; basta el hecho del retardo”.*

Ya se ha explicado. Solo resta agregar que se pueden cobrar otros perjuicios, siempre que se acrediten.

- **Regla tercera del artículo 1559.** *“Los intereses atrasados no producen interés”.*

Lo que la norma está señalando es que no acepta el anatocismo, que así se llama la capitalización de intereses (El art. 9 de la Ley N° 18.010 permite pactarlo en las operaciones de crédito de dinero).

- **Regla cuarta del artículo 1559.** *“La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas”.*

Por esta razón si las partes no han convenido otra cosa, las rentas de arrendamiento atrasadas no devengan interés. Lo que no significa que se deban pagar en valor nominal, pues la Ley N° 18.101 establece la reajustabilidad (art. 21).

3. AVALUACIÓN CONVENCIONAL: LA CLÁUSULA PENAL

3.1. Concepto

Está definida en el artículo 1535: *“La cláusula penal es aquella en que una persona para asegurar el cumplimiento de una obligación se sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o de retardar la obligación principal”.*

3.2. Funciones que cumple la cláusula penal

La cláusula penal cumple tres funciones: i) Es una forma de evaluar convencional y anticipadamente los perjuicios; ii) Constituye una caución; y iii) Importa una pena civil.

i. **La cláusula penal constituye una forma de evaluar perjuicios**

No hay disposiciones especiales que le confieran este carácter, pero ello fluye con claridad de diversos artículos. Así, por ejemplo, de los artículos 1537 y 1538, que exigen la constitución en mora del deudor; del artículo 1539, que establece la rebaja de la pena estipulada en el caso de cumplimiento parcial (evitando con ello acumular cumplimiento

con indemnización); del art. 1540, que permite dividir la pena entre los distintos herederos del deudor a prorrata de sus cuotas hereditarias.

Como forma de avaluar perjuicios, presenta dos características: a) es convencional y b) anticipada.

a) Convencional

Porque proviene del acuerdo de las partes. Ello significa que si la pena se establece unilateralmente (ej. la fija el testador para el heredero que no pague un legado), no estamos frente a una cláusula penal, a menos que fallecido el causante, este heredero acepte la situación. Por la misma razón tampoco puede establecerla la ley o el juez.

En Francia, la jurisprudencia ha creado una institución denominada **astreintes**, consistentes en la imposición por vía de apremio de una cierta suma de dinero como medio de compeler al deudor para que cumpla su obligación en el plazo señalado en la sentencia por el juez.

Los astreintes se caracterizan: (a) por su carácter arbitrario, ya que el juez puede fijar su monto prescindiendo de toda relación con la cuantía del perjuicio que el acreedor puede experimentar por el incumplimiento; (b) por la condición de apremio, ya que no es necesario que el deudor haya incurrido aún en su reticencia para que pueda ser colocado bajo la amenaza de los astreintes; (c) por su carácter provisorio, que autoriza al juez para aumentarlos en el futuro, si el deudor se obstina en no cumplir la obligación.

En nuestro Derecho no existe esta institución.

La cláusula penal no es la única forma de avaluar convencional y anticipadamente los perjuicios, pues el mismo carácter tiene las arras confirmatorias que también constituyen una liquidación anticipada de los perjuicios derivados de un incumplimiento contractual.

b) Anticipada

La cláusula penal constituye una evaluación anticipada porque el monto de los perjuicios queda irrevocablemente fijados antes del incumplimiento. Tanto es así que producido éste, el deudor no puede discutir ni la existencia ni el monto de estos perjuicios (art. 1542). Sirve para avaluar anticipadamente tanto perjuicios compensatorios como moratorios.

ii. La cláusula penal constituye una caución

Como la cláusula penal tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal (art. 1535), no puede discutirse su condición de caución, atendido que el Código define la voz caución como “cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de una obligación propia o ajena” (art. 46). Por lo demás, es mencionada como tal por el artículo 1472, al lado de la fianza, hipoteca y prenda.

Sin embargo, debe considerarse que la cláusula penal por sí sola no asegura el cumplimiento de la obligación principal. Sólo sirve de estímulo para que el deudor cumpla. Como dice GATICA, “la eficacia de la cláusula penal como caución reside fundamentalmente en la coacción psicológica que la pena ejerce sobre el ánimo del deudor, la cual naturalmente está en relación directa con la cuantía de la misma”.

Su condición de caución se robustece cuando se constituye para garantizar una obligación ajena, pues en ese supuesto, hay dos patrimonios que van a estar respondiendo del cumplimiento de la obligación.

Como caución es personal porque no afecta bienes determinados al cumplimiento de la obligación que puedan perseguirse en poder de terceros, como ocurre con la prenda o la hipoteca. No pasa a ser real, aun cuando consista en dar una especie o cuerpo cierto; en consecuencia, si el deudor o el que constituyó la pena enajenan el bien que se obligaron a dar, el acreedor carece de derecho de persecución de la cosa en manos del adquirente.

iii. La cláusula penal constituye una pena civil

Así está dicho en la propia definición legal. Puede agregarse que la cláusula penal nació en el Derecho Romano con una finalidad estrictamente sancionadora, carácter que aun conserva.

En virtud de este carácter de pena civil de la cláusula penal pueden explicarse diversas soluciones de la ley, y que, mirándola únicamente como indemnización de perjuicios, carecen de justificación. Desde luego, la ya señalada de que puedan cobrarse perjuicios, aunque no los haya (art. 1542).

Pero puede irse más lejos aún, y por estipulación expresa de las partes, al acreedor le es posible cobrar tanto la obligación principal como la pena (art. 1537), y, por otro convenio también expreso, la pena y la indemnización ordinaria de perjuicios (art. 1543); todo ello sería inexplicable si se trata de una mera evaluación convencional de los daños.

3.3. La cláusula penal puede ser compensatoria o moratoria

Como la cláusula penal es una forma de indemnizar perjuicios, puede ser tanto compensatoria como moratoria. Así se desprende de la propia definición legal: “en caso de no ejecutar” (compensatoria) o de “retardar la obligación principal” (moratoria). Así lo ha dicho la jurisprudencia. Y otro fallo ha señalado que “la regla general es que la cláusula penal sea compensatoria; así se deduce del texto del artículo 1537”.

VIAL, siguiendo su criterio ya estudiado, la clasificación de cláusula penal compensatoria y moratoria no atiende a si la pena se pacta por la no ejecución de la obligación principal o

por el retardo en el cumplimiento de la misma, sino que se hace en consideración a que el acreedor puede optar por perseverar en el contrato o desistirse de él.

3.4. Diferencias de la cláusula penal con la indemnización de perjuicios ordinaria

Como indemnización de perjuicios la cláusula penal, presenta algunas particularidades:

- a) Difiere de la indemnización de perjuicios ordinaria, en cuanto a la oportunidad en que se fija pues, como ya lo hemos dicho, estamos frente a una indemnización establecida antes del incumplimiento;
- b) Los perjuicios no se reparan necesariamente en dinero, como ocurre con la evaluación legal o judicial, pues en este caso, la pena puede consistir en un dar o en un hacer (como lo indica el artículo 1535) o en un no hacer (como lo señala la doctrina);
- c) No es necesario probar los perjuicios, como lo indica el artículo 1542. Este caso y el de la evaluación legal son las excepciones a la regla de que los perjuicios deben probarse.

3.5. Paralelo de la cláusula penal con otras instituciones

Se asemeja a la fianza, en cuanto es una caución personal, pero se diferencia de ésta en que el fiador sólo se obliga a pagar una suma de dinero (2343 inciso final), en tanto que la cláusula penal puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. Tampoco el fiador puede obligarse en términos más gravosos que el deudor principal (art. 2344), limitación que no existe en la cláusula penal.

Se asemeja también a las arras. En éstas se da una cosa con el fin de constituir una seguridad de la celebración o ejecución de un contrato, o como parte del precio o señal de quedar convenidos (arts. 1803 a 1805). Se pueden apreciar algunas diferencias importantes: las arras garantizan la celebración de un contrato y no el cumplimiento de una obligación. Además en las arras hay una entrega actual de dinero u otra cosa, lo que no ocurre en la cláusula penal en que la entrega -suponiendo que la cláusula penal establezca la entrega de algo- sólo se va a producir cuando se produzca el incumplimiento.

3.6. Características

- 1. Es consensual.
- 2. Es condicional.
- 3. Accesorio.
- 4. Puede garantizar una obligación civil o natural.

i. Consensual

Pues la ley no ha sometido su establecimiento a ninguna formalidad especial, aunque naturalmente le rigen las limitaciones para la prueba testimonial (arts. 1708 y 1709). Aun más, la voluntad de las partes puede manifestarse en forma expresa o en forma tácita.

ii. Condicional

Tiene ese carácter porque el derecho del acreedor a cobrar la cláusula penal está sujeto al hecho futuro e incierto que se produzca el incumplimiento del deudor. y que éste se encuentre en mora (artículo 1537). En este sentido, R.D.J., t. 32, sec. 1ª, p. 188.

iii. Accesorio

Esta característica proviene del hecho de ser una caución. De ello surgen varias consecuencias importantes:

- a) Extinguida la obligación principal, por cualquier medio, se extingue la cláusula penal.
- b) La acción para exigir el pago de la pena prescribe conjuntamente con la obligación principal (art. 2516).
- c) La nulidad de la obligación principal trae consigo la nulidad de la pena (art. 1536 inciso 1º). El artículo 1701 hace una clara aplicación de este principio al establecer que “La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad; y se mirarán como no ejecutados o celebrados, aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público dentro de un cierto plazo, bajo una cláusula penal: esta cláusula no tendrá valor alguno”.

En relación con esta característica es necesario estudiar dos situaciones vinculadas directamente con la nulidad de la obligación principal: casos en que se establezca una cláusula penal en la promesa de hecho ajeno y en la estipulación en favor de otro, situaciones tratadas en los incisos 2º y 3º del artículo 1536, respectivamente.

- Cláusula penal en la promesa de hecho ajeno

La promesa de hecho ajeno está contemplada en el artículo 1450: “Siempre que uno de los contratantes se compromete a que por una tercera persona, de quien no es legítimo representante, ha de darse, hacerse o no hacerse alguna cosa, esta tercera persona no contraerá obligación alguna, sino en virtud de su ratificación; y si ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la promesa”

Ahora bien, el artículo 1536, después de dejar consignado en su inciso 1º que la nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula penal, establece en su inciso siguiente, lo que parece una excepción: “Con todo, cuando uno promete por otra persona, imponiéndose una pena para el caso de no cumplirse por ésta lo prometido, valdrá la pena, aunque la obligación principal no tenga efecto por falta del consentimiento de dicha persona”.

La verdad es que no hay ninguna excepción a la regla del inciso 1º, pues lo que está garantizando la cláusula penal es la obligación que asumió el promitente de que el tercero acepte la obligación que se contrajo para él, o, dicho de otra manera, que ratifique lo obrado por el promitente. Y justamente, este es un caso en que la cláusula penal tiene clara utilidad.

- Cláusula penal en la estipulación en favor de otro

La estipulación en favor de otro está establecida en el artículo 1449: “Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla, pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él” (inc. 1º).

El inciso final del artículo 1536 señala que “lo mismo sucederá -valdrá la pena- cuando uno estipula con otro a favor de un tercero, y la persona con quien se estipula se sujeta a una pena para el caso de no cumplir lo prometido”.

Tampoco constituye una excepción a la regla del inciso 1º. Este es un caso en que la cláusula penal presenta evidente utilidad, porque como en conformidad al art. 1449, el estipulante no puede exigir al promitente el cumplimiento de lo acordado (cumplimiento que sólo puede demandar el beneficiario), estipula esta cláusula para poder compeler al promitente a que cumpla. Como dice SOMARRIVA “tampoco hay aquí nulidad de la obligación principal, sino que sencillamente el promitente contrae dos obligaciones: con respecto al beneficiario, cumplir con lo estipulado, y, con respecto al estipulante, pagar la pena en caso de incumplimiento”.

iv. La cláusula penal puede garantizar una obligación civil o natural

El artículo 1472, reconoce en forma expresa que pueda caucionar una obligación natural. Dice “Las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales constituidas por terceros para seguridad de estas obligaciones (naturales) valdrán”.

Cuando la cláusula penal está destinada a garantizar una obligación ajena, y esta obligación principal se transforma en natural, MEZA BARROS entiende que la obligación del tercero tiene este mismo carácter. Esta opinión no es compartida por GATICA, “porque la caución accede

no a la obligación civil, sino a la que ya es natural, y porque de otro modo ella no tendría sentido, ni el artículo 1470 del Código Civil le habría reconocido validez”.

3.7. Extinción de la cláusula penal

La cláusula penal puede extinguirse por vía principal y por vía accesoria. Por vía principal, cuando se extingue no obstante mantenerse vigente la obligación principal (por ejemplo la cláusula penal es nula y la obligación principal, es válida, artículo 1536 inc. 1º); y por vía accesoria, cuando desaparece como consecuencia de haberse extinguido la obligación principal, en razón de su carácter accesorio

3.8. Efectos de la cláusula penal

El efecto propio de la cláusula penal es dar al acreedor el derecho de cobrarla cuando no se cumple la obligación principal.

i. Requisitos para que el acreedor pueda cobrar la pena

Para que el acreedor pueda cobrar la pena deben cumplirse las condiciones ya estudiadas para la indemnización de perjuicios, con la salvedad que no es necesario probar la existencia de los perjuicios (art. 1542). Luego se requiere de:

- a) Incumplimiento de la obligación principal;
- b) Que este incumplimiento sea imputable al deudor; y
- c) Mora del deudor.

ii. Efectos de la cláusula penal cuando el incumplimiento es parcial

Si el acreedor acepta del deudor un pago parcial, el deudor tiene derecho a que “se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por la falta de cumplimiento de la obligación” (art. 1539).

3.9. Cobro de la pena, de la obligación principal y la indemnización ordinaria de perjuicios

Es preciso determinar los derechos del acreedor en caso de incumplimiento en relación al cobro de la pena, de la obligación principal y de la indemnización de perjuicios de acuerdo a las reglas generales, materias a que se refiere los arts. 1537 y 1543.

Se pueden resumir las reglas que señala este precepto en cuatro:

1. Antes de constituirse el deudor en mora, el acreedor sólo puede exigir la obligación principal;

2. Constituido el deudor en mora, puede el acreedor a su arbitrio cobrar la obligación principal, la pena compensatoria o la indemnización ordinaria de perjuicios;
3. Por excepción, el acreedor puede acumular la pena y la obligación principal, y
4. Por excepción puede también el acreedor pedir la pena y la indemnización ordinaria de perjuicios, si así se ha estipulado.

i. Antes de la mora sólo puede pedirse la obligación principal.

Así lo señala la primera parte del art. 1537: “antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino sólo la obligación principal”.

Ello es lógico, porque de acuerdo al precepto que sigue (art. 1538), el deudor no incurre en la pena mientras no sea constituido en mora. En consecuencia, antes de ella, el acreedor no puede exigir la pena que no se ha devengado aún, únicamente el cumplimiento del contrato.

ii. Derecho alternativo del acreedor en la mora del deudor

La regla es que una vez constituido el deudor en mora, el acreedor tiene una triple alternativa:

ii.1. Exigir el cumplimiento de la obligación principal, siempre que sea ello posible.

No podría el deudor oponerse al cumplimiento forzado ofreciendo la pena, porque de acuerdo al art. 1537 la elección es al arbitrio del acreedor y no de aquél.

ii.2. Exigir la pena, en vez de la obligación principal.

En la cláusula penal el legislador permite al acreedor elegir a su arbitrio entre la ejecución forzada y la pena.

ii.3. Exigir la indemnización de perjuicios ordinaria.

Bien puede el acreedor no pedir ni el cumplimiento ni la pena, sino la indemnización de perjuicios en conformidad a las reglas generales. Así lo establece la parte final del art. 1543: “pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o la pena”. Naturalmente que en tal caso la indemnización se somete en todo y por todo a las normas generales, y en consecuencia deberá probar los perjuicios que cobra el acreedor.

La explicación de esta solución es muy sencilla: la cláusula penal favorece al acreedor y de ahí que éste puede renunciarla. El elegirá entre las ventajas de la cláusula penal, que lo exime de probar perjuicios, y las de la indemnización ordinaria, que le permitirá percibir los que efectivamente ha sufrido y que pueden ser superiores a la cláusula penal.

iii. Casos en que el acreedor puede acumular la pena y la obligación principal.

Son tres los casos en que el acreedor puede cobrar la pena y la obligación principal:

iii.1. Si la pena es moratoria.

Que el acreedor no pueda cobrar al mismo tiempo la obligación principal y la pena se justifica ampliamente porque en tal caso estaría obteniendo un doble pago: el cumplimiento y la pena, pero ello naturalmente se refiere a la pena compensatoria y no a la moratoria, que siempre puede agregarse al cumplimiento porque indemniza el retardo.

Y por ello el art. 1537, después de decir que el acreedor no puede acumular la pena y la obligación principal, agrega: “a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo”.

Tiene gran interés, pues, distinguir si la indemnización es compensatoria o moratoria, lo cual es cuestión de interpretación, ya que el precepto habla de “aparecer”. Según una sentencia, la pena debe entenderse normalmente compensatoria.

iii.2. La estipulación de las partes.

Aun la pena compensatoria puede cobrarse conjuntamente con la obligación principal, si así se ha estipulado. Esta excepción la señala también el art. 1537, en su parte final: “o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entiende extinguida la obligación principal”. No hay, naturalmente, necesidad de usar esta frase sacramental; basta cualquiera que indique claramente la intención de las partes de acumular pena y obligación principal. La única exigencia es que semejante estipulación debe ser expresa, mientras que tratándose de la pena moratoria al legislador le basta que “aparezca” haberse convenido ésta por el simple retardo.

iii.3. En la transacción.

Dispone el art. 2463: “si se ha estipulado una pena contra el que deja de ejecutar la transacción, habría lugar a la pena, sin perjuicio de llevarse a efecto la transacción en todas sus partes”.

En consecuencia, cabe solicitar el cumplimiento del contrato y al mismo tiempo la pena, porque el legislador desea rodear a la transacción de la máxima eficacia posible.

iv. El acreedor sólo por estipulación expresa puede cobrar la pena e indemnización ordinaria

Normalmente el acreedor tiene una triple opción entre el cumplimiento, la pena y la indemnización ordinaria de perjuicios, y en los casos señalados puede acumular las dos primeras.

Pero no puede cobrar al mismo tiempo la pena y la indemnización de perjuicios, salvo el caso de excepción de que las partes lo hubieren expresamente convenido.

Lo dispone así el art. 1543 en su primera parte: “no podrá pedirse a la vez la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así expresamente”. También se exige en este caso que el convenio sea expreso.

3.10. Pluralidad de acreedores o de deudores

i. Cobro de la cláusula penal cuando la obligación principal es de cosa divisible.

Al efecto, el art. 1540 inc. 1º establece que “Cuando la obligación contraída con cláusula penal es de cosa divisible, la pena, del mismo modo que la obligación principal, se divide entre los herederos del deudor a prorrata de sus cuotas hereditarias. El heredero que contraviene a la obligación, incurre pues en aquella parte de la pena que corresponde a su cuota hereditaria; y el acreedor no tendrá acción alguna contra los coherederos que no han contravenido a la obligación.”

ii. Cobro de la cláusula penal cuando la obligación principal es de cosa indivisible o cuando se ha puesto la cláusula penal con la intención expresa de que el pago no pueda fraccionarse.

En estos casos puede el acreedor cobrar al culpable el total de la pena o, cada uno de los deudores incluidos los inocentes, su cuota en la pena, quedando a salvo el recurso de éstos contra el infractor (1540 incs. 2º y 3º).

iii. Situación en el caso que la pena sea indivisible

Si la pena es indivisible, se podrá reclamar a cualquiera de los deudores, sin importar quien sea el infractor. Ello porque estamos frente a una obligación indivisible, y es ése precisamente el efecto de la indivisibilidad. Así, por ejemplo, si la pena consiste en la entrega de un caballo y éste se encuentra en poder de uno de los deudores inocentes, no podría

excusarse de entregarlo alegando su no culpabilidad, pues estaríamos en presencia de una obligación indivisible, en conformidad al N° 2 del art. 1526.

iv. Situación en el caso que la obligación principal sea solidaria

La ley no da solución al problema. Cabe entender que la pena también se puede cobrar solidariamente, por el carácter accesorio que tiene. Así SOMARRIVA, CLARO SOLAR y GATICA.

ABELIUK estima que esta solución es discutible, porque la indemnización de perjuicios es conjunta aun entre los deudores solidarios. Por otro lado, agrega, pesa el argumento de que todos los codeudores han consentido en someterse a la pena. También para René RAMOS parece discutible la solución porque la solidaridad requiere de texto expreso, salvo incumplimiento doloso (art. 2317).

v. Cláusula penal garantizada con hipoteca

Trata de esta situación el artículo 1541: “Si a la pena estuviere afecto hipotecariamente un inmueble, podrá perseguirse toda la pena en él, salvo el recurso de indemnización contra quien hubiere lugar”. Esta solución es consecuencia del carácter indivisible de la hipoteca.

vi. Cobro de la cláusula penal cuando hay pluralidad de acreedores

No está resuelta esta situación en la ley. De acuerdo a las reglas generales, cada acreedor sólo podrá demandar su cuota en la pena, salvo que la pena fuere de cosa indivisible o hubiere solidaridad activa.

3.11. Cláusula penal enorme

En doctrina, la cláusula penal enorme es “aquella que contempla una pena desmesurada, lo que contribuye a que pierda su carácter indemnizatorio y constituya una fuente de lucro o ganancia para el acreedor. La persona que se sujeta a la pena en la cláusula penal enorme sufre una lesión, que consiste en el perjuicio que sufre a raíz de la prestación excesivamente gravosa” (VIAL).

Esta materia está regulada en el artículo 1544, que distingue varias situaciones:

a) Cláusula penal en los contratos conmutativos

Cuando la cláusula penal garantice el cumplimiento de la obligación de pagar cantidades determinadas como equivalente a lo que debe pagar la otra parte y la pena consista asimismo en el pago de cantidades determinadas se aplica la regla del artículo 1544: “Cuando por el pacto principal una de las partes se obligó a pagar una cantidad

determinada, como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse, y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, *podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que exceda al duplo de la primera incluyéndose ésta en él*".

La norma es confusa, pues no está claro lo que significa la frase "incluyéndose ésta en él". Hay dos interpretaciones:

Una mayoritaria que estima que el alcance es que la pena no puede exceder del doble de la obligación principal. Ej., si la obligación alcanza a 100; la pena no puede ser de más de 200.

Para otros, el sentido de la frase es que si la obligación principal es de 100, la pena puede llegar hasta 300, pues alcanza al doble de la obligación principal más la obligación principal.

La doctrina nacional está por la primera tesis: ALESSANDRI (ob. cit., p. 117); SOMARRIVA (*Tratado de las cauciones*, N° 33, p. 35); Gatica (ob. cit., N° 379, p. 486); CLARO SOLAR (ob. cit., t. X, N° 590, p. 530); FUEYO (*Derecho Civil*, t. IV, De las Obligaciones, vol. I, N° 374, pp. 359-360), ABELIUK (ob. cit., t. II, N° 923, p. 757).

b) Cláusula penal en el mutuo

Dice el art. 1544 inc. 3° que en el caso del mutuo "*se podrá rebajar la pena en lo que exceda del máximo del interés que es permitido estipular*".

Sin embargo, cuando se pactan intereses por la mora -lo que implica una cláusula penal- y éstos exceden al máximo que es permitido estipular, la sanción es que los intereses se rebajan al interés corriente (art. 8° de la Ley N° 18.010), no al máximo permitido estipular, como lo señala el art. 1544. Por ello se sostiene que este art. 8° dejaría sin aplicación el art. 1544 del Código Civil, en el caso que el mutuo sea de dinero. Luego el art. 1544 inc. 3° se mantendría vigente únicamente para los mutuos que no fueren de dinero (TOMASELLO).

c) Cláusula penal enorme en las obligaciones de valor inapreciable o indeterminado

Respecto de estas obligaciones, dice el art. 1544 inc. final, que el juez la moderará prudencialmente, cuando atendidas las circunstancias pareciere enorme.

Un antiguo fallo resolvió que "la obligación de entregar la cosa arrendada dentro del término convenido, a la cual accede la cláusula penal, es por la naturaleza de valor indeterminado: el tribunal puede moderar prudencialmente la pena si en su concepto fuera enorme". Se aplicó también la disposición en un caso en que un abogado había estipulado que si se le revocaba el poder en un juicio, el cliente pagaría como pena la mitad de la herencia por la cual se pleiteaba. La Corte de Talca la rebajó a \$ 1.000 de la época, por encontrarla enorme.

VII.

CAUSALES DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Tradicionalmente, la doctrina ha sostenido que la única causal de exención de responsabilidad sería el caso fortuito o la fuerza mayor. Adicionalmente, algunos autores agregan la ausencia de culpa. Una doctrina más minoritaria suma otras causales como la teoría de la imprevisión y la frustración del fin del contrato. Todas ellas se analizarán en este capítulo.

1. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Como consideración preliminar, es necesario considerar que de acuerdo a cierta doctrina, el Código Civil regula dos clases de caso fortuito según sean los efectos que produzca en el cumplimiento:

- a) El caso fortuito *permanente*, que opera como *modo de extinguir* la obligación por pérdida de la cosa que se debe o imposibilidad absoluta de ejecución del hecho debido (v. gr. destrucción de la cosa específica que se debía); y
- b) El caso fortuito *temporal*, que opera como *eximente de responsabilidad* y no como modo de extinguir, porque terminado el caso fortuito sí debe cumplirse (v. gr. se destruye el camino que necesariamente debía tomar el deudor para entregar la cosa debida: en tal caso, no responde por el retraso en el cumplimiento, pero debe entregar la cosa una vez que se haya reparado el camino).

1.1. Concepto

El artículo 45 lo define diciendo que “*se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc*”.

Es generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia que, conforme a dicha definición, el caso fortuito se configura como un hecho que debe ser **imprevisible** e **irresistible**, a lo que se agrega además que debe tratarse de un hecho **ajeno al deudor**, cuestión que se desprende del art. 1547 inciso segundo del mismo Código.

En tal sentido, la **jurisprudencia** reciente ha “conceptualizado el hecho imprevisto como aquel que la razón humana no puede determinar si se ha de realizar o no, al tiempo que entiende como hecho irresistible aquel cuyas consecuencias no han sido posible evitar ni

eludir por no haber medios para impedir las”. Profundizando esas nociones, se ha resuelto que “la naturaleza imprevista se verifica cuando no resulta posible vislumbrar la existencia del daño con anterioridad a su ocurrencia, es decir, haber adoptado todas las precauciones para que el daño no se produzca y aun así, ser imposible para el agente contrarrestarlo”; por su parte, el carácter irresistible “se refiere a la conducta del agente frente a un suceso en vías de ocurrir, inminente, o ya ocurrido, y consiste en defensas que se oponen al hecho imprevisto tendientes a evitar sus efectos dañosos”.

Por su parte, la **doctrina** afirma que “el hecho será ajeno cuando no constituya un riesgo que según el contrato corresponda al deudor”; es decir, corresponde a un hecho que afecta el cumplimiento de la obligación comprometida por el deudor y que escapa de los medios y recursos materiales o personales que debía utilizar para cumplir dicha obligación.

1.2. Elementos o requisitos del caso fortuito

Los elementos del caso fortuito son que se trate de un hecho ajeno al deudor, imprevisto e irresistible.

Es importante destacar que la forma de determinar la efectiva imprevisibilidad e irresistibilidad de un hecho se sustenta en base a un juicio en abstracto, por medio del cual se comparará la conducta efectiva del agente con un patrón de conducta estándar que servirá como punto de comparación (el *buen padre de familia*, el *hombre razonable*), de forma tal que se pueda dilucidar si una persona razonable, premunida de las mismas capacidades técnicas y enfrentado a las mismas circunstancias externas que el agente, habría podido prever y resistir el hecho que se invoca como caso fortuito.

Por su parte, la carga de acreditar que un hecho efectivamente constituye caso fortuito, recae en el deudor de la obligación; así, el art. 1547 inciso tercero del Código Civil dispone que incumbe “*la prueba del caso fortuito al que lo alega*”.

1.2.1. Hecho Ajeno

Este requisito –que para ciertos autores consiste en que el hecho sea “inimputable”, cuestión más restringida– consiste en que la circunstancia que el hecho que lo configura se encuentre fuera del ámbito de riesgos asumidos por el deudor en un contrato, de forma tal que si se produce un incumplimiento asociado a tales causas, “el deudor no podrá alegar su exención de responsabilidad. Ello, porque no se trata de un riesgo ajeno a él conforme al contrato, y por lo tanto, no puede configurar un caso fortuito a su respecto” (BRANTT).

Se debe tratar de un hecho ajeno al deudor; no debe provenir de su hecho o culpa o del hecho o culpa de las personas por quien él responde. Así resulta de varias disposiciones:

arts. 934, 1547 inc. 2º, 1590, 1672 inciso 1º, 1679, 1925 inc. 1º, 1926 inc. 1º, 2015 inc. 3º, 2016 inc. 2º, 2178 N° 2, 2242, etc.

Sobre esta materia, en Francia se ha fallado que un comerciante que vende mercaderías a plazo, que él no tiene, debe daños e intereses si una fuerza mayor le impide hacerlas venir lo suficientemente rápido como para entregarlas dentro de plazo. No hay caso fortuito por faltar la inimputabilidad: es culpable la conducta del deudor de ofrecer mercaderías que no tenía. ABELIUK señala este ejemplo como de falta de previsión, el vendedor debió prever la dificultad.

1.2.2. Hecho Imprevisto

Que sea imprevisto significa que dentro de los cálculos ordinarios de un hombre normal, no era dable esperar su ocurrencia. DE LA MAZA define los acontecimientos imprevistos como aquellos poco frecuentes, que por excepción suelen sobrevenir, y que no han sido tomados en cuenta por las partes al momento de contratar.

La Corte Suprema ha dicho que “el caso fortuito es imprevisto cuando no hay ninguna razón especial para creer en su realización”. Se ha fallado que “la sequía no constituye en sí misma un caso fortuito, ya que ella es insuficiente para eximirse de responsabilidad si se considera que en períodos de escasez de recursos hídricos, como sucede frecuentemente en nuestro país, es posible la generación a niveles normales de energía hidroeléctrica y aun sustituir el faltante mediante la generación termoeléctrica...”.

1.2.3. Hecho Irresistible

Se entiende que un evento resulta irresistible cuando, dispuestos todos los medios razonables para evitar su ocurrencia o sus efectos dañosos, éstos se verifican igualmente.

En tal sentido, se entiende que el carácter irresistible del hecho redunda en dos perspectivas distintas: que el hecho sea inevitable (esto es, que física o jurídicamente no sea posible evitar su ocurrencia) y que sus consecuencias sean irresistibles (a saber, que no puedan razonablemente eliminarse o aminorarse por parte del deudor).

Se ha resuelto que “El deudor, con la diligencia necesaria, debe superar toda clase de impedimentos u obstáculos –incluso imprevisibles al tiempo de contratar– que incidan en la ejecución de la obligación. Tratándose de estos impedimentos u obstáculos imprevisibles al tiempo del contrato, como ocurre en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, la diligencia requerida integra la prestación, imponiendo al deudor una actividad que no tuvo cómo prever inicialmente y, consiguientemente, unos costos adicionales. El límite de esta diligencia y de la actividad que se puede esperar del deudor está representado por la irresistibilidad de las consecuencias del impedimento u obstáculo. Este límite permite unir la responsabilidad civil por daños con la exoneración de la misma por caso fortuito o de fuerza mayor (artículo 1547 y 45 CC). El deudor incumplidor responde mientras no pruebe que su incumplimiento tuvo por causa un hecho constitutivo de caso fortuito, que se define concretamente, según sea su diligencia exigible.”

1.3. Efectos del caso fortuito

El efecto propio del caso fortuito es liberar de responsabilidad al deudor. Así lo dice el artículo 1547, inc. 2º: *“el deudor no es responsable del caso fortuito,...”*, y lo reitera el art. 1558 inc. 2º: *“La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios”*.

En opinión de VIAL, es necesario hacer presente que el caso fortuito presenta una doble naturaleza jurídica: (i) por una parte, como circunstancia que impide considerar que la infracción de obligación es imputable al deudor –lo que se traduce en la imposibilidad en que se encuentra el acreedor de exigir indemnización de perjuicios -. En este evento, si bien el caso fortuito hace imposible cumplir la obligación, no la extingue, porque se supone que el obstáculo es temporal o transitorio y que una vez que desaparece la obligación puede cumplirse, sin que el deudor contraiga responsabilidad por el cumplimiento tardío. (ii) Por otra parte, el caso fortuito puede considerarse como un elemento esencial de un modo de extinción de las obligaciones denominado pérdida de la cosa debida o imposibilidad absoluta de ejecución. En este caso, y a diferencia del punto anterior, se trata de un caso fortuito de efectos permanentes y no transitorios, por lo que no sólo exime de responsabilidad, sino que además extingue la obligación.

En definitiva, en la responsabilidad contractual, el caso fortuito constituye, en primer lugar, un **eximente de responsabilidad**, esto es, exime al deudor de una obligación contractual de su deber de indemnizar los perjuicios surgidos de su incumplimiento (total o parcial), si éste se ha producido por causa del caso fortuito o fuerza mayor. Así resulta del art. 1547 inciso segundo del Código Civil, según el cual *“el deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregada al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa”*.; y del art. 1558 del mismo Código, conforme al cual *“la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios”*.

En segundo término, el caso fortuito constituye una **forma de extinguir obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto**, que el Código Civil trata bajo la denominación de *“la pérdida de la cosa que se debe”*. Así, el art. 1670 de dicho Código dispone que *“cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye, o porque deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe, se extingue la obligación”*; pero dicha de la obligación extinción tiene lugar únicamente cuando la cosa debida perece **por caso fortuito** (art. 1672). La ley presume, en todo caso, que la cosa que perece en poder del deudor, lo hace por hecho o culpa suya (art. 1671), obligándolo a probar el caso fortuito (art. 1674).

1.4. Excepciones en el que el caso fortuito no libera de responsabilidad al deudor

1. Cuando el caso fortuito sobreviene por culpa del deudor. Así lo señala el artículo 1547 inc. 2º, y aplican este principio los artículos 1590 inciso 1º (para el caso fortuito como eximente de responsabilidad) y 1672 inciso 2º (para el caso fortuito como modo de extinguir). En verdad, si el hecho proviene por culpa del deudor, resulta impropio hablar de caso fortuito, pues el hecho le sería imputable.

2. Cuando sobreviene durante la mora del deudor. Así lo dice el artículo 1547 inc. 2º, y lo reiteran los artículos 1590 inciso 1º (para el caso fortuito como eximente de responsabilidad) y 1672 (para el caso fortuito como modo de extinguir).

Esa excepción no rige si el caso fortuito igualmente hubiere sobrevenido si el acreedor hubiere tenido en su poder la cosa debida: artículos 1547 inc. 2º, 1590 inc. 1º (para el caso fortuito como eximente de responsabilidad) y 1672 inciso 2º (para el caso fortuito como modo de extinguir).

3. Cuando se ha convenido que el deudor responda del caso fortuito. Ello puede establecerse en virtud del principio de la autonomía de la voluntad y de lo dicho en los artículos 1547 inc. final, 1558 inciso final y 1673.

4. Cuando la ley pone el caso fortuito de cargo del deudor (art. 1547 inciso final). Así ocurre, por ejemplo, respecto del que ha hurtado o robado una cosa (artículo 1676). Otro caso es el contemplado para el colono (arrendatario de predio rústico) en el artículo 1983 inciso 1º, en cuanto “no tendrá derecho para pedir rebaja del precio o renta, alegando casos fortuitos extraordinarios, que han deteriorado o destruido la cosecha”.

1.5. Prueba del caso fortuito

Los artículos 1547 inciso 3º y 1674, establecen que incumbe la prueba del caso fortuito al que lo alega. Estas disposiciones constituyen una aplicación de la regla general de onus probandi contemplada en el artículo 1698, según el cual corresponde la prueba de la extinción de una obligación al que alega esta circunstancia.

Constituye una excepción a la regla de que el caso fortuito debe probarse, el actual artículo 531 del Código de Comercio (ex art. 539), relativo al contrato de seguro, en cuanto dispone que “el siniestro se presume ocurrido por un evento que hace responsable al asegurador”.

2. AUSENCIA DE CULPA

La segunda causal de exoneración de responsabilidad del deudor sería -empleamos el condicional pues no es generalmente aceptada- la ausencia de culpa.

El problema es el siguiente ¿le basta al deudor probar que ha empleado la debida diligencia para liberarse de responsabilidad o debe probar además la existencia del caso fortuito? La doctrina no es uniforme. La Corte Suprema ha dicho que le basta al deudor acreditar que ha empleado el cuidado a que lo obligaba el contrato, sin que sea necesario probar el caso fortuito.

ABELIUK opina que es suficiente con que el deudor pruebe su ausencia de culpa. Ello, por las siguientes razones:

- a) La redacción del artículo 1547 inciso 3º que contrapone las dos situaciones: prueba de la diligencia o cuidado y prueba del caso fortuito. Explica que “si el deudor no se libera sino ante este último, carecería de objeto que probara su diligencia o cuidado”.
- b) El artículo 1670 establece, sin hacer distinción alguna, que si la cosa perece se extingue la obligación del deudor. Más adelante, en el artículo 1672, está la excepción al señalar que si ello ha ocurrido por culpa o durante la mora del deudor, la obligación subsiste, pero varía de objeto: la indemnización de perjuicios. Luego, si no ha habido culpa o mora, no hay excepción y se aplica la regla del artículo 1670, quedando la obligación extinguida;
- c) Si en conformidad al artículo 1678, cuando la cosa debida se destruye por un hecho voluntario del deudor, que inculpablemente ignoraba la obligación, sólo se lo obliga a pagar el precio sin indemnización de perjuicios, con mayor razón si hay un hecho involuntario y no culpable del deudor, éste debe quedar exento de responsabilidad.

En sentido contrario, CLARO SOLAR: “la imputabilidad cesa, cuando la inejecución de la obligación o la demora en su ejecución es el resultado de una causa extraña al deudor, o sea de fuerza mayor o caso fortuito”.

3. OTRAS SUPUESTAS CAUSALES DE EXENCIÓN

Además de las ya indicadas, cierta doctrina nacional agrega como causales de exención el estado de necesidad, el hecho ajeno, la teoría de la imprevisión y la frustración del fin del contrato. Con todo, tales causales han tenido escasa (y en algunos casos nula) acogida por la jurisprudencia nacional.

3.1. EL ESTADO DE NECESIDAD

El estado de necesidad se configura por el hecho que el deudor queda liberado de responsabilidad en el caso en que pudiendo cumplir, no lo hace para evitar un mal mayor. Se diferencia del caso fortuito, en que no hay un impedimento insuperable. FUEYO coloca

varios ejemplos. Veamos uno de ellos: el del capitán del barco que, en peligro de naufragar, lanza al mar las mercaderías que transporta ¿debe responder?

La doctrina no es unánime. ABELIUK cree que para quedar exento de responsabilidad, tiene que configurarse una fuerza mayor. Estima que si no se configura un caso fortuito, el deudor debe cumplir, ya que no hay disposición alguna en que pueda asilarse el estado de necesidad. Pero la tendencia moderna, es que el estado de necesidad legitima el hecho y lo convierte en lícito, liberando de responsabilidad al deudor.

El Código Civil, en un caso, toca el punto desechando el estado de necesidad. Es la situación del comodatario que en un accidente, puesto en la alternativa de salvar la cosa prestada o la propia, opta por esta última (art. 2178 N° 3). Hace responsable al comodatario, lo que se explica porque responde hasta de la culpa levísima.

3.2. HECHO O CULPA DEL ACREEDOR

Nuestro Código no ha reglamentado en forma orgánica la mora del acreedor (*mora accipiendi*). Pero se refiere a ella en varias disposiciones para exonerar de responsabilidad al deudor. Así, en el artículo 1548, en las obligaciones de dar, libera de responsabilidad al deudor, por el cuidado de la especie o cuerpo cierto debido, cuando el acreedor se ha constituido en mora de recibir; en el artículo 1680, repite la misma idea, haciendo responsable al deudor sólo por culpa grave o dolo; en el artículo 1827, en que exime al vendedor del cuidado ordinario de conservar la cosa, si el comprador se constituye en mora de recibir.

3.3. EL HECHO AJENO

Para determinar la responsabilidad del deudor que incurre en incumplimiento por hecho o culpa de un tercero, es preciso distinguir si es civilmente responsable por él o no.

Por regla general la intervención del tercero es para el deudor un caso fortuito si reúne los requisitos propios de éste de imprevisibilidad e irresistibilidad. Por ello el art. 1.677, que se cita como un caso de acción oblicua, establece que el acreedor puede exigir que el deudor le ceda los derechos y acciones que tenga contra el hechor. Lo mismo dispone el inc. final del art. 1.590 para el caso de deterioros.

Pero el hecho del tercero por el cual el deudor es civilmente responsable se considera hecho suyo. Así lo dispone el art. 1.679: "en el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable". Nos encontramos, pues, frente a un caso de **responsabilidad indirecta o por el hecho ajeno**, tal como ocurre en la responsabilidad extracontractual.

Sin embargo, el legislador no dijo en el art. 1679 -a diferencia del 2320- quiénes son estos terceros por los cuales el deudor es civilmente responsable. En los contratos en particular enumera sí varios casos: arts. 1.925, 1.926, 1.929, 1.941, 1.947, inc. final; 2.000, inc. 2º, 2.014, 2.015, inc. final; 2.003, regla 3ª, 2.242, 2.243.

3.4. TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN

En aquellos contratos de tracto sucesivo, en que las obligaciones de las partes se van cumpliendo durante períodos prolongados, puede ocurrir que durante la vida del contrato, sobrevengan hechos imprevistos y graves, que hagan para una de ellas excesivamente oneroso el cumplimiento de sus obligaciones. La pregunta que cabe formular es si en tal supuesto, puede el afectado recurrir a la justicia para que se revise el contrato y se restablezca el equilibrio patrimonial. Si aceptamos esta posibilidad, estamos aceptando la teoría de la imprevisión.

Frente a estos graves desequilibrios en las prestaciones de cada parte, hay en doctrina dos posiciones. Para una primera, todo contrato es ley para las partes, que ninguna de ellas puede desconocer aunque hayan variado las condiciones bajo las cuales lo celebraron. Lo acordado tiene que cumplirse en la forma convenida ("*pacta sunt servanda*"). La seguridad jurídica así lo exige. Ello implica no aceptar la revisión de los contratos y, por ende, el rechazo de la teoría de la imprevisión.

Para una segunda, que tuvo su origen en el Derecho Canónico, y que cobró mucha fuerza después de la Primera Guerra Mundial como consecuencia de los fenómenos económicos que de ella derivaron, debe admitirse, por razones de equidad, de moralidad, la revisión de los contratos, cuando varían gravemente, y por causas imprevistas, las condiciones bajo las cuales el contrato fue acordado. Contraponen al "*pacta sunt servanda*" el principio "*rebus sic stantibus*". Dicen los sostenedores de esa posición que "en cada contrato, se puede considerar como subentendida una cláusula tácita "*rebus sic stantibus*", según la cual las partes no quedarán obligadas a sus prestaciones recíprocas sino en el caso de que las circunstancias generales existentes al tiempo de obligarse subsistan en el mismo estado hasta la ejecución completa de la obligación". Lo anterior, porque "cada parte, al establecer las cláusulas del acto, sólo pensó y sólo pudo pensar en los riesgos normales que podrían ocurrir y de acuerdo con esto formuló sus condiciones. Los acontecimientos anormales, imprevistos, no han podido entrar en sus puntos de vista. Su voluntad se manifestó en relación con el medio existente y los riesgos normales".

DE LA MAZA define la teoría de la imprevisión, diciendo que es la doctrina jurídica (conjunto de principios de derecho debidamente fundados) que sostiene que el juez puede intervenir a petición de cualquiera de las partes, en la ejecución de la obligación con el objeto de atenuar sus efectos, cuando, a consecuencia de acontecimientos imprevistos para las partes al momento de formarse el vínculo jurídico, ajenos a su voluntad y que producen perturbación grave con relación a toda una categoría de contratantes, la ejecución de la obligación se hace más difícil o más onerosa, y siempre que aquel llegue a formarse la convicción de que siendo previsibles estas perturbaciones, las partes no se habrían obligado en las condiciones fijadas".

En doctrina se afirma que, para que opere la teoría de la imprevisión, se requiere de la concurrencia de los siguientes **elementos**:

1. Que se trate de un contrato de tracto sucesivo o por lo menos de un contrato de ejecución diferida. “La teoría de la imprevisión tiene necesariamente que suponer obligaciones que tengan duración en el tiempo, prestaciones sucesiva o diferidas o que no estén completamente ejecutadas. De otro modo no es posible concebir que sobrevengan acontecimientos imprevisibles y esto es de la esencia de la imprevisión”.
2. Que por circunstancias sobrevinientes, ajenas a las partes y no previstas, se produzca un desequilibrio patrimonial en las prestaciones.
3. Que los hechos que producen la alteración, sean tan extraordinarios y graves, que si las partes los hubieran tenido a la vista al momento de contratar no habrían contratado o lo habrían hecho en condiciones diferentes.

A diferencia de otros países (v.gr. Argentina), en Chile no existe una consagración expresa de la teoría de la imprevisión, sin perjuicio que es posible observar que hay casos puntuales, en que la propia ley la acepta, y otros, por el contrario en que en forma expresa la rechaza.

La acepta, por ejemplo, en el artículo 2003, regla 2ª, en el contrato para la construcción de edificios, por un precio único prefijado (contrato de empresa). Esta disposición señala que: “2º: si circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo, ocasionare costos que no pudieron preverse, deberá el empresario hacerse autorizar para ellos por el dueño; y si éste rehúsa, podrá ocurrir al juez para que decida si ha debido o no preverse el recargo de la obra, y fije el aumento de precio que por esta razón corresponda”. Otros ejemplos de disposiciones que acogerían la teoría de la imprevisión serían: el artículo 1496 que admite la caducidad del plazo por causas sobrevinientes; el artículo 2180, en el comodato en cuanto autoriza para pedir la restitución anticipada de la cosa prestada si surge para el comodante una necesidad imprevista y urgente; el artículo 2227, en el depósito, en que se acepta que el depositario pueda anticipar la devolución de la cosa si ésta peligró o le causa perjuicios; en el artículo 2348, que permite al acreedor exigir fianza al deudor cuya ausencia del territorio nacional se tema y que carezca de bienes suficientes para la seguridad de la obligación.

En otros casos, se rechaza expresamente. Así ocurre en el mismo artículo 2003, regla 1ª: “el empresario no podrá pedir aumento de precio, a pretexto de haber encarecido los jornales o los materiales...” Y lo mismo pasa en el artículo 1983, en el arrendamiento de predios rústicos: “El colono no tendrá derecho para pedir rebaja del precio o renta, alegando casos fortuitos extraordinarios, que han deteriorado o destruido la cosecha” (inciso 1º).

Cabe observar que han existido proyectos de ley que buscan consagrar la teoría de la imprevisión en el ordenamiento jurídico. Uno de ellos es el proyecto de ley “que permite la revisión judicial de contratos civiles y mercantiles” (Boletín N° 309-07-1), que data del año 1991, que consta de 5 artículos, y cuyo artículo 1º, en su inciso primero, señala: “*Los contratos civiles y mercantiles, bilaterales conmutativos y unilaterales onerosos, de tracto sucesivo o de ejecución diferida, podrán ser revisados judicialmente si la prestación se hubiere convertido, por acontecimientos extraordinarios, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes, en excesivamente gravosa de ser cumplida. En tal evento, el tribunal estará facultado para modificar las cláusulas respectivas, restableciendo la equivalencia de las prestaciones existente al momento de contratar*”.

Un segundo proyecto, más reciente y originado por la falta de tramitación del proyecto anterior, fue presentado el año 2017 (Boletín N° 11.204-07), y pretende incorporar al Código Civil una serie de nuevos artículos (arts. 1546 bis, ter, quater, quinquies y sexies) que reglamenten la “revisión judicial de los contratos”, en los siguientes términos: “*Con todo, los contratos civiles y mercantiles, bilaterales conmutativos y unilaterales onerosos, de tracto sucesivo, podrán ser revisados judicialmente en el caso de que la prestación se hubiere convertido, por acontecimientos extraordinarios, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes, en excesivamente gravosa de ser cumplida. En tal evento, el tribunal estará facultado para modificar las cláusulas*

respectivas, restableciendo la equivalencia de las prestaciones existente al momento de celebrarse el contrato. Para tal efecto, se establece una acción de revisión que corresponderá al contratante perjudicado.”

El problema se va a presentar en aquellas situaciones en que no hay un pronunciamiento legal. La generalidad de la doctrina la rechaza fundada en el efecto obligatorio de los contratos (artículo 1545) y además si las partes supieran que tienen el camino abierto para una posterior revisión del contrato los deudores inescrupulosos tendrían un pretexto más a fin de eludir o postergar su cumplimiento en largos pleitos. Adicionalmente, la jurisprudencia señala que los tribunales carecen de facultades para derogar o dejar sin cumplimiento la ley del contrato, ya sea por razón de equidad, o bien de costumbres o reglamentos administrativos.

Sin perjuicio de lo anterior, existe cierta doctrina que, fundada en normas y principios generales, entiende que la teoría de la imprevisión si tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, cuestión que ha sido muy aisladamente aceptada por ciertos fallos judiciales.

Entre los argumentos empleados para afirmar la aceptación de la teoría de la imprevisión en Chile se encuentran los siguientes:

- a) El art. 1560. De acuerdo a esa disposición “conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. De esta norma se sigue que para interpretar un contrato debe buscarse la intención con que éste se celebró. Y cabe presumir que lo querido por las partes al momento de contratar, fue la mantención del contrato en el entendido que no varíen substancialmente las condiciones existentes en ese momento. Por ello, si por causas que no se pudieron prever, se produce durante la vida del contrato un cambio significativo de esas condiciones, debe procederse a la revisión del contrato.
- b) El art. 1546, obliga a las partes a cumplir el contrato de buena fe. Sería contrario a esta buena fe que una de ellas pretenda que la otra deba cumplir en condiciones excesivamente onerosas, que rompen el equilibrio patrimonial y que fatalmente lo llevarán a la ruina.
- c) Toda persona -se agrega- al contratar contrae un determinado deber de cuidado. Si cambian las condiciones, pasaría a asumir un riesgo que va más allá del que el deudor aceptó al momento de contratar; y
- d) Por regla general, el deudor responde únicamente de los perjuicios previstos (art. 1558 inc. 1º). Si las condiciones en que se celebró el contrato cambian violentamente, por circunstancias que no se pudieron prever al momento de contratar, y se mantiene el contrato tal como fue convenido, viene a resultar que se estaría respondiendo de perjuicios imprevistos.

Si bien durante largo tiempo nuestros tribunales rechazaron enérgicamente la aplicación de la teoría de la imprevisión, fundados principalmente en el art. 1545, hace sólo un par de años cierta jurisprudencia arbitral comenzó a acoger, tímidamente, la aplicación de esta institución.

A ello cabe agregar que la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 14 de noviembre de 2006 recaída en los autos rol 6812-2001, estableció que nuestro ordenamiento jurídico si aceptaba la aplicación a esta teoría en los artículos 1545, 1546, 1547, 1558, 1560, 1568, más el artículo 1444, todos del Código Civil, lo que constituye el primer fallo emanado de los tribunales ordinarios en este sentido. Al efecto, dicha Corte resolvió que si bien de la simple lectura del art. 1545 pareciera emanar en forma definitiva, la inmutabilidad absoluta del contrato, estima que el análisis del tema discutido en el caso no puede abortarse de inmediato, pues la Teoría de la Imprevisión no es, en ningún caso, un peligro para tal principio. Tratándose en la especie de un acto jurídico bilateral que reporta beneficio para ambas partes, era el cuidado de un buen padre de familia el que debían emplear estas y ese

comportamiento es el único que se les puede exigir. No pudiendo calificarse jurídicamente el contrato celebrado entre las partes sino como oneroso y conmutativo, la equivalencia en las prestaciones resulta fundamental por cuanto dicha característica es un elemento de la naturaleza de ese tipo de contrato, de manera que, al alterarse la equivalencia en las prestaciones, se lesiona el contrato mismo, situación que permite consecuentemente su revisión.

3.5. LA FRUSTRACIÓN DEL FIN DEL CONTRATO

La frustración del fin del contrato se configura cuando en un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, que no sea de ejecución instantánea, la finalidad particular perseguida por uno de los contratantes se ve malograda absolutamente por un hecho imprevisible que no debía soportar, debiendo determinarse de qué manera habrá de cumplirse la obligación correlativa de la que es deudor, en circunstancias de que el contrato ya no le presta ningún beneficio no obstante poder ser llevada a cabo igual.

Como expresa el jurista español DIEZ-PICAZO, por *fin del contrato* “debe entenderse el propósito a que el contrato sirve dentro de la vida real, vale decir, el resultado empírico o práctico que en orden a los peculiares y propios intereses se pretende alcanzar”. De ahí que el mismo autor hable de “una pérdida de sentido y de razón de ser de la prestación”, toda vez que la utilidad que la misma le rendía, por un hecho imprevisible y extrínseco al riesgo que debe soportar, ha quedado amagada; el interés real en el contrato ha muerto no obstante objetivamente puede realizarse. Es esta finalidad individual, utilidad específica de un sujeto cocontratante que mediante la convención persigue, un elemento que cuando se encuentra expresado en la convención, no es indiferente y determina la producción de consecuencias jurídicas. Ahora bien, cuando este fin se imposibilita hay que examinar cuáles son los caracteres del contrato para determinar cuáles y de qué envergadura serán los efectos que se sigan a la frustración imprevisible y extraordinaria de dicho fin.

Si bien es clara la afinidad que existe entre la teoría de la imprevisión con la frustración del fin del contrato, más allá de las similitudes de ambas doctrinas existen diferencias entre una y otra, divergencia que se delinea principalmente a partir de que mientras la doctrina de la imprevisión se ocupa del destino del contrato frente a circunstancias que encarecen el cumplimiento de las prestaciones de una de las partes, la frustración del fin del contrato se aboca sobre una hipótesis más reducida consistente en la suerte del contrato como resultado de una nueva circunstancia que hace que una de las partes pierda total interés en su acreencia perviviendo el deber de cumplir con la obligación contraída en el contrato bilateral, oneroso y conmutativo.

En general, se indica por la doctrina que los presupuestos necesarios para que opere la frustración del fin del contrato son los siguientes:

- a) Que el contrato sea bilateral. Puesto que sólo en este supuesto la frustración absoluta e imprevisible del interés de un cocontratante puede afectar el curso de la ejecución ulterior del contrato. En efecto, si el contrato fuese unilateral, y el acreedor por su parte no debiera observar ninguna obligación a su tanto para el deudor de la obligación cuyo interés pierde, no habría ningún estímulo para demandar su cumplimiento y no quedarían dudas que despejar a resultas de ello.
- b) Que el contrato sea oneroso. Ambas partes deben tener interés en el contrato para que pueda hablarse con propiedad de frustración del fin contrato, dado que si solamente lo tiene el acreedor la pérdida sobrevenida de esta utilidad lo motivará a desestimar su cumplimiento, sin que la otra parte tampoco tenga ningún interés por cumplir.

- c) Que el contrato sea conmutativo. De suyo la frustración del fin del contrato será relevante en esta categoría, puesto que la valoración que cada parte hizo en función del interés que la convención les reportaba, hecho al momento de su perfeccionamiento, se ve quebrantado con posterioridad a raíz de una alteración imprevisible que malogra el interés particular de uno de los contratantes.
- d) Que el contrato sea de ejecución diferida o tracto sucesivo. Y ello puesto que en los contratos de ejecución inmediata no existe un intervalo de tiempo dentro del cual puedan mudar las circunstancias existentes al tiempo en que nació la convención.
- e) Que el beneficio de una de las partes se haya frustrado y las obligaciones del contrato sean objetivamente realizables. La peculiaridad de la frustración del fin del contrato es que las obligaciones nacidas de la convención pueden todavía ejecutarse empero que para uno de los sujetos la utilidad del derecho personal se ha difuminado por una causa sobreviniente. Es la persistencia del deber por parte de quien de manera inimputable ve alterada su expectativa sobre el negocio lo que lleva a plantear; como se ha dicho, si el Derecho es indiferente frente a este riesgo imprevisto que trastorna la vida del contrato.
- f) Frustración absoluta y perpetua del interés del cocontratante afectado. No es cualquier alteración sobre el interés de la parte afectada la que legitima reclamar los efectos de la frustración del fin del contrato. Todo contrato supone un marco de riesgo que se encuentra debidamente delineado primero por la voluntad de quienes se sujetan a él y en su silencio por la ley, encontrándose los sucesos futuros e imprevistos debidamente repartidos a favor o en contra de uno de ellos según sea. Por ello es que no parece plausible sostener que toda causa que amague la utilidad de una parte en el contrato sea idónea para estos efectos, debiendo distinguir diversos criterios para ver si este riesgo corresponde a la contratante que pierde el interés en su crédito o bien permite alegar que se ha frustrado la finalidad del contrato.
- g) Frustración del fin del contrato debe ser inimputable a las partes e imprevisible. Es imprescindible que la mutación de circunstancias que derivan en el posterior desinterés del acreedor por su derecho no sea consecuencia de una conducta dolosa o culposa de ninguno de los cocontratantes: severos principios del Derecho Privado, como la prohibición de reportar provecho del propio dolo o torpeza inexcusable – de parte del acreedor- o el principio de responsabilidad – de parte del deudor que perpetra el perjuicio, ambos asentados en nuestro Código Civil en varias disposiciones, impiden esta hipótesis.

En Chile no existe una consagración expresa de la teoría de la imprevisión, sin perjuicio que es posible observar que hay casos puntuales, en que la propia ley la acepta.

Un primer caso es el art. 1932 del Código Civil, que establece que *“el arrendatario tiene derecho a la terminación del arrendamiento y aun a la rescisión del contrato, según las cosas, si el mal estado o calidad de la cosa le impide hacer de ella el uso para que ha sido arrendada, sea que el arrendador conociese o no el mal estado o calidad de la cosa al tiempo del contrato; y aun en el caso de haber empezado a existir el vicio de la cosa después del contrato, pero sin culpa del arrendatario. Si el impedimento para el goce de la cosa es parcial o si la cosa se destruye en parte, el juez decidirá, según las circunstancias, si debe tener lugar la terminación del arrendamiento, o concederse una rebaja del precio o renta”*. Esta regla es congruente con la del art. 1924, N° 2 del mismo cuerpo normativo que establece la obligación del arrendador de mantener la cosa arrendada en estado de servir para el fin al que ha sido contratado.

Por su parte, el art. 52 de la Ley sobre Propiedad Intelectual N° 17.336 incorpora otro supuesto en el que típicamente se regula la frustración del fin del contrato para una convención en particular: *“el autor podrá dejar sin efecto el contrato si transcurridos cinco años de estar la edición en venta, el público no hubiere adquirido más del 20% de los ejemplares. En tal caso, el autor deberá adquirir todos los ejemplares no vendidos al editor, al precio de costo”*. Como se ve, la ley concede al autor de un libro en este caso la posibilidad de instar por el término del contrato si es que precisamente no se cumple la finalidad perseguida por él al momento de celebrar el contrato con el editor para que imprimiera, publicara y distribuyera la obra.

Un último caso que es interesante tratar consiste en aquél incorporado a nuestro ordenamiento por la Convención de Viena sobre compraventa de mercaderías internacionales, ratificada por nuestro país el 7 de Febrero de 1990 y que entró en vigencia el 1° de Marzo de 1991. El art. 79.1 de dicha convención establece como causal de exención de responsabilidad de incumplimiento de un contrato de compraventa internacional el que se frustre la expectativa económica para cualquiera de las partes, en tanto el evento que afecte la utilidad del crédito de las partes haya sido imprevisible e inevitable por las partes según el grado de diligencia al que se hubieren sujeto por el contrato.

Fuera de disposiciones legales expresas que reconocerían la existencia de la frustración del fin del contrato en nuestro ordenamiento jurídico, en general la doctrina estima que en Chile esta teoría no tiene cabida.

Como señala Ríos, el art. 1547 del Código Civil dispone que para fijar la extensión del nivel de cuidado que comporta cada obligación debe estarse a un criterio económico que ha sido establecido legalmente: según la utilidad que el contrato brinde a cada una de las partes se fijará el grado de cuidado, oscilando entre culpa grave y culpa levísima, a la exclusividad de beneficio del acreedor o del deudor, y centrándose en la culpa leve – como un buen padre de familia en los términos del art. 44 del Código Civil- si es que la utilidad económica es compartida por las partes de la convención. Esta forma de delimitar la exigibilidad de las obligaciones contractuales fue novedosa en el Derecho Comparado y obedece precisamente a un criterio que intenta ser equitativo sobre el interés de cada parte en el contrato. Prevalece en esta materia, en todo caso, un pacto expreso de los contratantes que alteren esta distribución legal, que es de carácter supletorio.

Siendo así, no puede demandarse a quien responde de culpa leve, como lo es el caso de uno de los cocontratantes en la frustración del fin del contrato, cualquier cosa que exceda el nivel de actividad que ha comprometido según el beneficio que le reporte la convención, de modo tal que un hecho imprevisible e inimputable no puede demandársele más allá de lo que constituye el límite de la conducta debida. Así, por lo demás, se ha fallado.

Pudiendo predicarse estas consecuencias de cualquier fenómeno en que las circunstancias contractuales se vean modificadas, forzoso es anotar de qué manera se engarza la frustración del fin del contrato con este criterio de exigibilidad previsto en el Código Civil.

Una primera duda que debe resolverse es aquella que dice relación con que, siendo la utilidad el factor determinante para asignar el grado de diligencia por el que se fija la extensión del comportamiento obligado, y siendo característico de la frustración del fin del contrato el que el beneficio de una de las partes se pierda irreversiblemente, es correcto afirmar que para el evento de que el esta figura se configure disminuye la exigibilidad de la obligación que el acreedor afectado debe observar precisamente porque ha perdido cualquier beneficio del contrato. Tal postura parece errónea dado que, entre otras razones, parece contundente el argumento de que es precisamente en razón de la alteración de las circunstancias contractuales uno de los motivos por los que es importante la determinación del nivel de exigibilidad de las obligaciones, por lo que asumir que puede disminuirse con posterioridad a la celebración del contrato implicaría trastocar el fundamento de las reglas y la precisa concepción del principio de intangibilidad de los contratos.

Una segunda cuestión es aquella tocante en determinar que, debiendo entonces el acreedor del interés perturbado de culpa leve, cómo deberá seguir cumpliendo con las obligaciones derivadas de la convención ante la frustración de su fin. Tal problema se predica de la frustración del fin del contrato como de la teoría de la imprevisión, y en el Derecho chileno se resuelven a partir del marco jurídico

establecido en el Código Civil, en el que no es posible compeler a una persona a cumplir más allá de lo que la conducta debida por la obligación le impone, frontera que queda determinada particularmente por las normas de los arts. 1545 a 1550 del Código Civil, en especial aquella que distribuye los niveles de actividad y eficiencia de las partes según la utilidad económica que uno de ellos o ambos obtenga de la convención.

Hay que remarcar que la frustración del fin del contrato no libera a la parte perjudicada en su interés económico de cumplir con sus obligaciones. Es por ello que igual debe seguir cumpliendo con aquellas obligaciones anteriores al evento frustrante. Con posterioridad a tal hecho debe seguir cumpliendo con sus deberes contractuales, quedando eximido de todo aquello que sobrepase su nivel de actividad el que queda determinado por la utilidad perseguida del contrato, de modo que demandarle algo sin que le preste, por hechos de la entidad y la envergadura descritos, beneficio alguno queda fuera del programa conductual de la obligación. Por lo tanto, deberá igualmente respetar sus obligaciones que no se ven afectadas por tales hechos imprevisibles e inimputables, debiendo cumplir como un buen padre de familia.

Por último, parece que no es admisible en nuestro Derecho la revisión del contrato por parte del juez, aun cuando ésta se realice sobre la base del principio de protección de la buena fe o la potestad de fallar conforme a la equidad por el tribunal.

VII.

MEDIOS DE CONSERVACIÓN

DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR:

LOS “DERECHOS AUXILIARES DEL ACREEDOR”

VII.A.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. EL DERECHO DE PRENDA GENERAL

El impropriadamente denominado “derecho de prenda general del acreedor” dice relación con el aforismo jurídico clásico que señala que “quien se obliga compromete todos sus bienes”; es decir, que la persona que contrae una obligación asegura su cumplimiento no con su persona –pues no existe la prisión por deudas-, sino que con todos los bienes que conforman el activo de su patrimonio.

Tal “derecho” se encuentra contenido en el artículo 2465, que dispone que “toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presente o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo 1618”. Al efecto, valga señalar lo siguiente:

- La nomenclatura “derecho de prenda general” ha sido correctamente criticada, por cuanto en los hechos no existe un contrato real de prenda (que supone la entrega de muebles del deudor al acreedor). Sin embargo, tal denominación se continúa empleando pues únicamente ilustra que todos los bienes del deudor se encuentran afectos al cumplimiento de la obligación.
- El derecho de prenda general no comprende los bienes inembargables señalados en los artículos 1618 del Código Civil y 445 del Código de procedimiento Civil, pues los mismos son considerados en general como los necesarios para la subsistencia del deudor).
- El art. 2456 sostiene que toda obligación “personal” se encuentra amparada por el derecho de prenda general. Al efecto, y si bien siempre la obligación del deudor principal es personal, se debe considerar que el artículo en análisis se refiere a la obligación “personal” en contraposición de las obligaciones “reales”, que son aquellas que emanan de contratos de garantía reales, como lo son la prenda y la hipoteca. El acreedor de una obligación que emana de una caución real no puede perseguir el cumplimiento de la obligación en todos

los bienes del constituyente de la garantía, sino que solamente en los que se encuentran afectos a la garantía que hubiesen sido dados en prenda o hipoteca. Todo lo contrario ocurre con las garantías personales, como la fianza, pues el fiador, al igual que el deudor principal, se obliga con todos sus bienes.

2. FUNDAMENTO DE LOS MEDIOS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, COMÚNMENTE DENOMINADOS “DERECHOS AUXILIARES DEL ACREEDOR”

Como en virtud del derecho de prenda general (art. 2465) es el patrimonio del deudor el que está respondiendo del cumplimiento de sus obligaciones, la ley otorga al acreedor ciertas acciones o medios destinados a mantener la integridad de ese patrimonio, a fin de que los bienes que lo componen no se deterioren, se enajenen o confundan con otros patrimonios. Estas acciones o medios son comúnmente denominados “derechos auxiliares del acreedor”.

No hay uniformidad sobre cuales serían esos derechos. Pero hay un cierto consenso, en atribuirle este carácter a los siguientes:

- a) Las medidas conservativas, destinadas a evitar que determinados bienes salgan del patrimonio del deudor;
- b) La acción oblicua, indirecta o subrogatoria, destinada a obtener que ingresen ciertos bienes al patrimonio del deudor que éste negligentemente pretende dejar fuera;
- c) La acción pauliana o revocatoria cuyo objeto es reintegrar al patrimonio del deudor bienes que han salido de él en perjuicio de sus acreedores (art. 2468); y
- d) El beneficio de separación destinado a impedir que los bienes del causante se confundan con los del heredero, en perjuicio de los acreedores hereditarios o testamentarios (arts. 1378 al 1385).

Algunos autores agregan el derecho legal de retención (arts. 1937, 2162, 2193, 2234, etc.; arts. 545 y 546 del C.P.C.)

VII.B. MEDIDAS CONSERVATIVAS

El Código en diversas disposiciones hace referencia a las medidas conservativas (arts. 156, 761, 1078, 1492 inc. final) pero no las define. La doctrina señala que “son aquellas que tienen por objeto mantener intacto el patrimonio del deudor, evitando que salgan de su poder los bienes que lo forman, a fin de hacer posible el cumplimiento de la obligación” (ALESSANDRI).

CLARO SOLAR, por su parte, expresa que “tienen el carácter de conservativas todas las medidas destinadas a asegurar el ejercicio futuro de un derecho, sin constituir su ejercicio actual”. Por su parte, VIAL las define como “aquellas que pueden ejercer los acreedores para evitar que los bienes embargables del deudor se destruyan o deterioren, o sean objeto de enajenaciones que los hagan salir del patrimonio de este”.

Entre las medidas conservativas se pueden mencionar:

- (i) Las medidas precautorias reglamentadas en los artículos 290 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, consistentes en: (a) El secuestro de la cosa que es objeto de la demanda; (b) El nombramiento de uno o más interventores; (c) La retención de bienes determinados; y (d) La prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados. Adicionalmente, el artículo 298 del CPC admite y regula las medidas precautorias innominadas.
- (ii) La guarda y aposición de sellos, de que tratan los artículos 1222 y siguientes del Código Civil;
- (iii) La confección de inventario solemne, que exigen muchas disposiciones del Código Civil (arts. 124, 374, 775, 1255, 1765, 1766, etc.).

VII.C. LA ACCIÓN OBLICUA O SUBROGATORIA

1. CONCEPTO

La ley en determinados casos otorga a los acreedores el derecho a actuar en nombre del deudor, respecto de ciertas acciones o derechos, que correspondiendo a éste, negligentemente o con el propósito de perjudicar a sus acreedores, no ejercita. Ello con el objeto de que estas acciones o derechos ingresen al patrimonio del deudor, mejorando de esa forma el derecho de prenda general. Estas acciones se denominan acciones indirectas, oblicuas o subrogatorias. ABELIUK las define como “el ejercicio de los derechos y acciones del deudor por parte de sus acreedores, cuando el primero es negligente en hacerlo”.

Es el caso, por ejemplo, del deudor que repudia una herencia, que renuncia a una donación, o que no cobra las rentas a que tiene derecho por un arrendamiento. El acreedor, en esos supuestos podría actuar en nombre del deudor y aceptar la herencia o la donación, cobrar las rentas, etc.

Estas acciones subrogatorias no son acciones directas que emanen del contrato, sino que las otorga la ley. Sus diferentes denominaciones se explican: *subrogatoria* porque los acreedores pasan a ocupar el lugar del deudor para ejercitar sus derechos y acciones, haciéndolo por cuenta y a nombre él. *Indirecta u oblicua*, porque la acción o derecho se incorpora al patrimonio del deudor, para que después el acreedor pueda hacer efectivo su crédito en ese patrimonio.

En Chile, no existe una disposición que en forma general la conceda, sino que únicamente hay casos específicos. En Francia es diferente, pues el artículo 1166 permite que “los acreedores pueden ejercitar todos los derechos y acciones de su deudor, con excepción de los que estén unidos exclusivamente a su persona”.

2. CASOS EN QUE SE LA LEY CONSAGRARÍA EXPRESAMENTE LA ACCIÓN OBLICUA.

i. Caso de los derechos de prenda, usufructo, retención.

El art. 2466 inc. 1º señala: “Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas por razón de dominio, y existan en poder del deudor insolvente, conservarán sus derechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los derechos reales que sobre ellos competan al deudor, como usufructuario o prendario, o del derecho de retención que le conceden las leyes; en todos los cuales podrán subrogarse los acreedores”. A primera vista, la frase final de este inciso, estaría otorgando a los acreedores la facultad de subrogarse. ABELIUK, piensa que ello no es así, y que “pareciere más bien que el legislador continuara reglamentando el derecho de ejecución que fluye de la garantía general establecida en los artículos 2465 y 2469”.

Por ejemplo, en la prenda querría decir que el acreedor ejecutante embargaría el crédito garantizado con ella, y lo sacaría a remate, como cualquier otro bien del deudor. En cambio, por la acción oblicua los acreedores podrían cobrar los créditos garantizados con prenda. Para ABELIUK entonces el inc. 1º se estaría refiriendo al embargo de los derechos del deudor sobre bienes de que no es dueño, y no estableciendo una acción oblicua.

ii. Caso de los derechos que corresponden al deudor derivados del contrato de arriendo.

El artículo 2466 inciso 2º establece que “podrán asimismo subrogarse en los derechos del deudor como arrendador o arrendatario, según lo dispuesto en los artículos 1965 y 1968”.

Para ABELIUK el art. 1965 se asemeja a la acción oblicua, pero verdaderamente lo que ocurre es que hay un traspaso legal del contrato, a consecuencia del embargo, y como modalidad

de la ejecución. Tanto es así que esta sustitución sólo beneficia a los acreedores que intentaron el embargo, y no a la masa, como ocurre en la acción oblicua.

El art. 1968 se refiere a la situación del arrendatario insolvente. Lo que ocurre es que los acreedores del arrendatario pueden tener interés en mantener el arriendo porque, por ejemplo, allí tiene su explotación el deudor, con cuyo producto podrá quizás pagarles sus créditos; para evitar la pérdida de esta expectativa, la ley les da el derecho de sustituirse en el contrato, dando fianza. Dice ABELIUK: "Aunque también participa de otros caracteres, y especialmente de la cesión legal de contrato, no hay duda de que tiene mucho de acción oblicua".

iii. Caso del deudor que no puede cumplir la obligación de entregar una especie o cuerpo cierto por culpa de un tercero.

Cuando el deudor no puede cumplir con la obligación de entregar la especie o cuerpo cierto debida, porque se perdió por culpa de un tercero, el acreedor puede exigir al deudor que le ceda las acciones contra el tercero (art. 1677).

Ciertos autores estiman que no es un caso de subrogación, sino que de cesión forzada de acciones.

iv. Caso del deudor que repudia una herencia o legado.

Si el deudor repudia una herencia o legado: "Los acreedores del que repudia en perjuicio de los derechos de ellos, podrán hacerse autorizar por el juez para aceptar por el deudor. En este caso la repudiación no se rescinde sino en favor de los acreedores y hasta concurrencia de sus créditos; y en el sobrante subsiste" (art. 1238).

El artículo 1394 repite la misma idea en el inciso 2º: "Los acreedores, con todo, podrán ser autorizados por el juez para substituirse a un deudor que así lo hace -repudia una herencia, legado o donación- hasta concurrencia de sus créditos; y en el sobrante, si lo hubiere, se aprovechará el tercero".

Para ABELIUK la figura "tiene mucho de acción oblicua, y tanto es así que el art. 1394 habla de "sustitución" del deudor; ello porque se ejerce un derecho de éste. Pero también tiene bastante de acción pauliana, y tanto que el art. 1238 utiliza la expresión "rescisión" tan erróneamente a nuestro juicio, como lo hace en el art. 2468 para la acción pauliana; en efecto, se deja sin efecto un acto ya ejecutado y en perjuicio de los acreedores. No se exige, en cambio, el fraude pauliano que identifica esta institución y que es de más difícil prueba que el mero perjuicio a los acreedores que exigen los arts. 1238 y 1394".

3. ACCIÓN SUBROGATORIA GENERAL.

3.1. Debate sobre la procedencia de la acción oblicua en Chile

Hay distintas opiniones sobre este punto. Para algunos (ALESSANDRI, FUEYO, ABELIUK) sólo cabe para los casos en que la ley expresamente lo autoriza. Para otros, en cambio (CLARO SOLAR), la acción oblicua opera en forma general.

Pese a no haber un texto tan claro como el de Francia, la situación sería semejante y emanaría de los artículos 2465 y 2466.

3.2. Requisitos para que opere una acción oblicua general

Estos requisitos pueden estudiarse en relación con: 1. la persona del acreedor; 2. con el crédito del acreedor; 3. con la persona del deudor; y 4. con los derechos y acciones respecto de los cuales opera.

i. Requisitos de la acción oblicua en relación con el acreedor

Respecto a los requisitos que debe cumplir el acreedor, se estima que sólo debe tener interés, lo que va a ocurrir cuando la negligencia del deudor en ejercitar el derecho o acción, comprometa su solvencia. Por ello, falta este requisito si el deudor tiene bienes suficientes para cumplir sus obligaciones. Ello explica que el artículo 2466 hable del “deudor insolvente”.

ii. Requisitos de la acción oblicua en relación con el crédito

En cuanto a los requisitos que tiene que tener el crédito del acreedor para poder accionar, tendrá que ser cierto y actualmente exigible, es decir, no podrá estar sujeto a plazos o a condiciones suspensivas.

iii. Requisitos de la acción oblicua en relación con el deudor

El deudor debe ser negligente en el ejercicio de sus derechos y acciones. Corresponde al acreedor probar esta circunstancia. ABELIUK, señala sobre este punto que “la negligencia deberá probarla el acreedor, pero no es necesario que constituya previamente en mora al deudor, y en buena doctrina habría que concluir que ni siquiera es necesario oír a éste”. Y agrega “Nos parece, sin embargo, de toda conveniencia emplazar al deudor para evitar discusiones posteriores sobre el efecto de la acción a su respecto”. Así lo exige, por ejemplo, el Código italiano expresamente (art. 2900 inc. 2°).

iv. Requisitos de la acción oblicua en relación con los derechos y acciones

Finalmente, respecto a los derechos y acciones que pueden ejercerse por el acreedor en nombre del deudor, tienen que ser patrimoniales; referirse a bienes embargables; y, en ningún caso, opera la subrogación respecto de los derechos o acciones personalísimos, como sería, por ejemplo, la acción de reclamación del estado de hijo., o el derecho de uso o habitación.

3.3. Efectos de la subrogación

Todos los efectos que se siguen son consecuencia del principio de que el acreedor va a actuar por cuenta y a nombre del deudor. Se parece a la representación, pero es diferente, porque en la representación el representante interviene en interés del representado. Acá, en cambio, lo mueve su propio interés.

Los efectos son consecuencia de que el acreedor va a actuar por cuenta del deudor:

- a) El tercero demandado puede oponer al acreedor las mismas excepciones que podía oponer a su acreedor (el deudor);
- b) La sentencia que se pronuncie en este juicio produce cosa juzgada respecto del deudor. ABELIUK encuentra esto discutible y por ello recomienda que se le emplace siempre.
- c) No se requiere de una resolución previa que autorice la subrogación. Esta calificación se hará en el mismo juicio en que se hace efectiva la acción.
- d) Los bienes ingresan al patrimonio del deudor, beneficiándose con ella, no sólo el subrogante sino todos los acreedores (de ahí que ABELIUK diga que la acción oblicua no es de mucha importancia y aplicación).

VII.D.

LA ACCIÓN PAULIANA O REVOCATORIA

1. CONCEPTO

Esta acción tiene su origen en Roma. Allí los actos realizados por un deudor en fraude de sus acreedores, constituían un delito privado, “*el fraus creditorum*”, sancionado mediante una acción especial llamada por los comentadores “acción pauliana”.

Se afirma que el origen de este apelativo es mal conocido. Algunos autores pretenden que se deriva del nombre del pretor que estableció la acción, el cual se llamaría Paulus. Parece ser más verosímil- agrega- que ese nombre derive del gran jurisconsulto Paulo, que trata de la acción en un fragmento del Digesto.

Se le llama también *acción revocatoria* porque tiene por objeto revocar, dejar sin efecto, los actos fraudulentos del deudor realizados en perjuicio de sus acreedores.

Está tratada en el artículo 2468. ABELIUK la define como “la que la ley otorga a los acreedores para dejar sin efecto los actos del deudor ejecutados fraudulentamente y en perjuicio de sus derechos y siempre que concurran los demás requisitos legales”.

2. REQUISITOS

Estos pueden estudiarse: 1. en relación con el acto; 2. en relación con el deudor; 3. en relación con el acreedor; y 4. en relación con el adquirente del deudor.

i. **Requisitos en relación con el acto**

La acción pauliana puede intentarse para dejar sin efecto cualquier acto o contrato voluntario del deudor (no los forzados, pues en tal caso no se divisa el fraude ni hay voluntad del deudor). Los términos del art. 2468 son bastante amplios. Pueden ser actos o contratos de distinto tipo (unilaterales, bilaterales, gratuitos, onerosos, donaciones, renuncia de derechos, etc.). Las cauciones otorgadas por el deudor también quedan incluidas si son fraudulentas, y por ello el N° 1 del art. 2468 menciona la prenda, hipoteca, anticresis. Sería el caso, por ejemplo, de una deuda pendiente que el deudor garantiza con una hipoteca totalmente innecesaria, puesto que el acreedor no puede aún presionarlo.

No obstante que procede tanto respecto de los actos gratuitos como de los onerosos, los efectos que se siguen en uno y otro caso son diferentes. En efecto, si el contrato que produce la insolvencia del deudor es oneroso, para revocarlo será necesario probar la mala fe del deudor y la mala fe del adquirente, esto es acreditar que ambos conocían el mal estado de los negocios del deudor. En cambio, si el contrato es gratuito, basta que el acreedor pruebe la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores.

ii. **Requisitos en relación con el deudor**

En Roma tanto la acción pauliana como la oblicua, se ejercitaba en el procedimiento colectivo de ejecución sobre los bienes. Era ejercida por el “*curator bonorum*” a nombre de todos los acreedores.

En Chile la situación es diferente, pues no es necesario para la procedencia de la acción pauliana que el deudor esté en un procedimiento concursal de liquidación o de

reorganización. En efecto, el artículo 2468 precisamente trata de los “los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o la apertura del concurso”. Es lógico que sea así, pues de exigirse ello, quedarían sin poder ser atacados por esta vía -por faltar el procedimiento concursal - muchos actos fraudulentos y claramente lesivos para los acreedores.

Si se produce la apertura de concurso rige el art. 2467, que establece que “Son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente a los bienes de que ha hecho cesión, o de que se ha abierto concurso a los acreedores”. Sin perjuicio de lo anterior, también se pueden revocar los actos previos a la apertura del concurso, según lo regulado por los artículos 287 y siguientes de la Ley de Reorganización y Liquidación, que establecen las denominadas acciones revocatorias concursales.

Respecto del deudor lo que exige el artículo 2468 es que esté de mala fe. Es una mala fe específica, denominada *fraude pauliano* o mala fe pauliana, que consiste en que realice el acto conociendo el mal estado de sus negocios.

iii. Requisitos en relación con el acreedor

El acreedor que entabla la acción debe tener interés, y sólo va a tenerlo cuando se reúnan los siguientes requisitos: a) que el deudor sea insolvente o que con el acto haga aumentar su insolvencia; y b) que su crédito sea anterior al acto que produce la insolvencia. SOMARRIVA explicado estos requisitos señala que “se entiende que existe este perjuicio cuando a consecuencia del acto el deudor queda en insolvencia, o se aumenta la ya producida”. Y agrega “Con lo expuesto se comprenderá que al acreedor que adquiere el carácter de tal después del acto, éste no puede causarle perjuicios, pues él conocía el estado en que se encontraban los negocios del deudor y aceptó contratar en esas condiciones”.

iv. Requisitos en relación con el tercero adquirente

Si el acto es gratuito, no se requiere ningún requisito especial en el tercero adquirente; basta la mala fe del deudor y el perjuicio (art. 2468 N° 2). Si el acto es oneroso, el tercero adquirente debe estar de mala fe es decir, haber celebrado el acto sabiendo el mal estado de los negocios del deudor (art. 2468 N° 1).

La razón de esta diferencia radica en que habiendo varios intereses en juego: del acreedor que quiere mantener la máxima integridad de su garantía; del deudor que debe conservar la libre administración de sus bienes, y a quien el legislador sólo sanciona en casos de negligencia o fraude, y del tercero que ha contratado con el deudor, la ley sacrifica con mayor facilidad el de éste, si no ha efectuado sacrificio alguno para su adquisición. El tercero en definitiva no pierde nada, queda igual que antes del acto. En cambio, el que ha adquirido a título oneroso, ha efectuado un desembolso, un sacrificio económico, que tendrá

posteriormente que entrar a recuperar. Por ello el legislador no puede prescindir de su actitud y sólo lo sanciona si es fraudulento también.

v. Situación del subadquirente

El Código no regula la situación de los subadquirentes, esto es de aquellos cuyos derechos emanan del tercero que celebró el contrato con el deudor.

Por ejemplo, el deudor donó su automóvil a A, y éste a su vez vendió el vehículo a B. Contra A, hay acción pauliana; ¿afectará ella a B, y en qué condiciones?

Para estos efectos, es necesario distinguir:

- (i) Si no procede la acción pauliana en contra del adquirente (por ejemplo porque este se encontraba de buena fe en la celebración de contrato oneroso), tampoco procederá en contra del subadquirente, ya sea a título gratuito u oneroso, siendo irrelevante que se encuentre de buena o mala fe.
- (ii) En cambio, en el caso que proceda la acción pauliana en contra del adquirente, para que ésta pueda entablarse en contra de los subadquirentes hay que distinguir si la enajenación a éste fue a título gratuito u oneroso:
 - (a) Si él subadquirente lo es a título gratuito, la acción pauliana procede en contra él aunque se encuentre de buena fe.
 - (b) Si él subadquirente lo es a título oneroso, sólo procederá la acción pauliana en contra de él en la medida que se encuentre de mala fe, esto es que haya sabido del mal estado de los negocios del deudor.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PAULIANA

- a. Es una acción *directa* del acreedor, que ejerce a su propio nombre y no por cuenta del deudor;
- b. Es una acción *personal*. El punto se ha prestado a cierta controversia, porque al igual que otras acciones personales (como la de resolución, pago de lo no debido o nulidad), puede afectar a terceros. Antes por el contrario, la acción carece de todo objeto si ella no va a implicar al tercero adquirente. Es más, dice ABELIUK, no hay duda alguna que el tercero debe ser parte en el pleito en que se discuta la revocación, tanto que si es adquirente a título oneroso esta en discusión su buena fe.

Pero ello no quita la calidad de acción personal a la pauliana, porque deriva de una relación de crédito entre el acreedor y deudor, y que involucra al tercero por disposición de la ley y por su participación en el hecho.

c. Es una acción *patrimonial*, de donde se sigue que a) es renunciable; b) transferible, c) transmisible, y d) prescriptible.

El plazo de prescripción de esta acción es de un año, contado desde la fecha del acto o contrato (artículo 2468 N° 3). Siendo una prescripción especial o de corto plazo, no se suspende (art. 2524).

A su turno, el art. 291 de la Ley de Reorganización y Liquidación dispone que las acciones revocatorias concursales deben entablarse en el plazo de un año contado desde la Resolución de Reorganización, de Liquidación o de Admisibilidad, según corresponda.

4. EFFECTOS DE LA ACCIÓN PAULIANA

El efecto propio de la acción pauliana es dejar sin efecto el acto o contrato impugnado, hasta el monto del crédito del acreedor que intenta la acción. Consecuencia de ello, es que el deudor puede enervar la acción pagando al acreedor.

Por aplicación del efecto relativo de la sentencia judicial -artículo 3° del Código Civil- la revocación sólo afecta a las partes que litigaron.

Los efectos de la revocación variarán según el caso de que se trate; así, si se trata de una enajenación quedará total o parcialmente sin efecto, y el adquirente perderá la cosa de que se trate; si se dirige contra una hipoteca, se cancelará ésta; si se ataca a una remisión, renace el crédito, etc.

5. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN PAULIANA

Hay diferentes opiniones sobre la naturaleza de la acción pauliana.

ALESSANDRI tomando pie de la expresión “rescindibles” que emplea el 2468, entiende que es una *acción de nulidad relativa*. Tiene importancia esa conclusión para los efectos de saber si a los terceros subadquirentes se les va o no exigir mala fe. ALESSANDRI, fundado en el art. 1689, piensa que no tiene importancia que los terceros subadquirentes estén de buena o mala fe. RAMOS dice que sin duda y aunque el artículo 2468 emplee la forma verbal “rescendan” (propia de la nulidad relativa), la acción pauliana no es una acción de nulidad, pues el acto que se pretende dejar sin efecto, es un acto válido, pues en su formación no hubo vicios. Recuerdese que para que haya nulidad tiene que existir un vicio originario.

SOMARRIVA, piensa que se está frente a una típica *acción de inoponibilidad por fraude*. Ello implica que al acreedor no le afecta el acto y por ello puede pedir su revocación. El hecho de que el acto se revoque hasta el monto del crédito del acreedor es un buen argumento en favor de esta posición. Esta tesis la sigue también ABELIUK.

Esta posición encontraba un argumento favorable en la antigua Ley de Quiebras, en cuanto justamente hablaba de “inoponibilidad”. La actual Ley de Reorganización y Liquidación únicamente habla de “acciones revocatorias concursales”. En todo caso, se debe considerar que el art. 289 de dicha Ley, inserto en el capítulo que regula las acciones revocatorias concursales, dispone que se puede solicitar la reforma de estatutos o pacto en ciertos casos, agregando que ello conlleva que los mismos sean “inoponibles”.

Para otros (PLANIOL), se trata de una *acción indemnizatoria* por un hecho ilícito. La reparación adopta una forma especial que es, precisamente, dejar sin efecto el acto ilícito.

VII.E.

EL BENEFICIO DE SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS

En virtud de los principios sobre sucesión por causa de muerte, fallecida una persona, su patrimonio (activo y pasivo) pasa a sus herederos, confundándose con el patrimonio de estos. Al producirse lo anterior va a ocurrir que si el heredero estaba cargado de deudas, sus acreedores personales van a mejorar su situación pues tienen ahora un patrimonio más rico sobre el cual hacer efectivas sus acreencias. Pero ello, en perjuicio de los acreedores que el difunto tenía en vida (acreedores hereditarios) y de aquellos cuyos créditos han sido adquiridos en virtud del testamento (acreedores testamentarios, legatarios) quienes verán peligrar sus acreencias al tener que concurrir con los acreedores personales del heredero.

Por este motivo, se establece el beneficio de separación de patrimonios que tiene por objeto evitar que se confundan los bienes del causante con los del heredero, para que, de esa forma, puedan pagarse en los primeros, los acreedores hereditarios y testamentarios, con preferencia a los acreedores propios del heredero.

Al estudiar sucesión por causa de muerte, se analiza en detalle esta importante institución, que el Código regula en los artículos 1378 al 1385 (Título XII del Libro III).

VIII.

CLÁUSULAS ESPECIALES SOBRE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

1. CONSIDERACIONES GENERALES.

Desde su entrada en vigencia, nuestro Código Civil ha permitido, en diversas disposiciones, que las partes de un contrato puedan establecer una regulación especial en lo que se refiere a la responsabilidad civil que se deriva de un incumplimiento contractual.

No obstante la evidente utilidad de esta clase de estipulaciones, en la práctica ellas han motivado el surgimiento de diversas controversias, particularmente en casos en los que las mismas se redactan en términos muy amplios –incluso absolutos o que no admiten excepción- y perentorios, que utilizan expresiones como “todo” o “ningún” –perjuicio, incumplimiento, situación, etc.- de manera categórica.

Estas discrepancias se han incrementado en las últimas décadas, atendido el cada vez más habitual empleo de modelos de cláusulas y de contratos provenientes del extranjero, particularmente de países regidos por el *Common Law*. Los principales problemas que se han observado a este respecto se originan por el hecho de que estas “importaciones” de modelos contractuales muchas veces son traducciones literales de las cláusulas, en las que no se ha cuidado de adecuar su redacción y configuración de una forma armónica con el ordenamiento jurídico nacional.

Lo cierto es que esta clase de estipulaciones –sean ellas de origen nacional o foráneo-, en abstracto y a lo menos a primera vista, no parecen adolecer de nulidad absoluta por objeto ilícito o por causa ilícita, según sea el caso, en cuanto su tenor no contraviene el orden público, las buenas costumbres o la ley (salvo casos especiales y de aplicación específica).

Así, más bien parece que las controversias relativas al sentido y alcance de estas cláusulas requieren ser resueltas en base a un ejercicio interpretativo de la convención, a efectos de conservar su eficacia. A continuación se analizarán las pautas generales para interpretar adecuadamente estas estipulaciones, y asimismo se procederá a analizar ciertas cláusulas en particular, que han sido fuente de disputas prácticas.

2. CONSIDERACIONES GENERALES RELATIVAS A LAS CLÁUSULAS QUE ALTERAN LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y SU INTERPRETACIÓN

2.1. Las cláusulas que alteran la responsabilidad contractual requieren de una estipulación expresa, especial y explícita.

Una primera cuestión, que resulta imprescindible a considerar, está dada por el hecho que las convenciones que alteran el régimen general de responsabilidad contractual que el Código Civil regula, siempre requieren de una estipulación *expresa, especial y explícita*, por lo que en ningún caso una cláusula modificatoria de responsabilidad puede tener la calidad de *tácita o implícita*.

El carácter necesariamente expreso y explícito de las cláusulas que alteran o modifican la responsabilidad contractual ha sido destacado, desde antiguo, por la más autorizada doctrina, fundada en una serie de disposiciones legales. En efecto, el art. 1547 del Código Civil, luego de regular el grado de diligencia del que debe responder el deudor, y de establecer a quien corresponde acreditar la diligencia empleada y la ocurrencia de un caso fortuito, dispone en su inciso final que ello es sin perjuicio de las “*estipulaciones expresas de las partes*”. A su turno, el art. 1558, después de regular los perjuicios de los que debe responder el deudor en caso de incumplimiento y señalar que la mora producida por caso fortuito no fa lugar a indemnización, agrega que “[l]as estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas”. Por su lado, y concordante con lo anterior, el art. 1673 permite a las partes el distribuir los riesgos que pudieran enfrentar en la ejecución del contrato, señalando al efecto que en tal caso “*se observará lo pactado*”.

Lo anterior es ratificado, además, por el art. 1444 pues, por definición, los pactos de limitación o exoneración de responsabilidad constituyen elementos meramente accidentales de un contrato, puesto que persiguen alterar el régimen de responsabilidad que les corresponde según su naturaleza. Y debe recordarse que, como señala esta norma, los elementos o cosas accidentales del contrato son aquellas “*que se agregan por medio de cláusulas especiales*”, es decir, se requiere de una cláusula especial y expresa para convenirlas y no pueden presumirse a propósito del acto interpretativo.

De este modo, es doble el fundamento para afirmar que las cláusulas que alteran la responsabilidad contractual deben ser pactadas de forma expresa, especial y explícita: por una parte, así resulta del claro tenor de las normas legales que contemplan la posibilidad de alterar el régimen de responsabilidad que la ley establece; y por otra, atendido que estas cláusulas constituyen elementos accidentales de un contrato, sólo pueden entenderse incorporadas por medio de cláusulas especiales.

2.2. Literalidad, intención y buena fe en la interpretación contractual.

Como es evidente, atendido que la eficacia y aplicación práctica de las cláusulas que alteran la responsabilidad contractual esté supeditada a la existencia de una estipulación expresa y específica, resultará habitual tener que recurrir a la interpretación de las mismas para desentrañar su cabal sentido y alcance.

A este respecto resulta aplicable, en primer término, el principio rector en materia de interpretación de contratos, el que se encuentra consagrado en el art. 1560 en los siguientes términos: “[c]onocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”.

Tal como la doctrina ha señalado desde antiguo, y como se ha recordado más recientemente, el principio consagrado en el art. 1560 no significa que el intérprete deba despreciar las declaraciones escritas, sino que, por el contrario, ello es la primera vía para desentrañar la intención común de los contratantes, y precisamente por ello es que existe una suerte de presunción de una “coincidencia entre la voluntad interna y la declarada”.

Ahora bien, que el intérprete deba tener en consideración la literalidad no significa que esté constreñido a la letra del contrato. Desde luego, si la clara intención de las partes es conocida –para lo cual se debe analizar no solo el contrato escrito en sí, sino que elementos exógenos, como lo es su aplicación práctica, la existencia de otros contratos, el establecimiento de qué parte fue la redactora de la convención, etc.-, deberá preferirse tal intención antes de lo literal, como indica el art. 1560.

A ello cabe agregar que es sumamente habitual que cláusulas gramaticalmente claras e inequívocas, dejan de serlo al darse ejecución al contrato, que es donde precisamente comienzan a surgir las divergencias. Precisamente eso es lo que ocurre con las estipulaciones elaborada en términos muy amplios y/o absolutos –esto es, al decir de la doctrina, de términos “claros pero excesivos”-, las que de suyo imponen un ejercicio interpretativo. Tan cierto es ello, que existe una regla especial de interpretación de las cláusulas amplias, como lo es el art. 1561, que dispone que “[p]or generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado”.

Adicionalmente, y por amplios y categóricos que sean los términos empleados por las partes, el intérprete –presumiendo la buena fe de los contratantes, y por ende asumiendo que su intención fue la de celebrar una convención plenamente válida y no expuesta a ser declarada ineficaz-, necesariamente deberá darle un sentido y alcance a la estipulación entendiendo que las partes, en el ejercicio de su autonomía privada, respetaron los límites que a su respecto establece el Código Civil en los arts. 1445 N°s 2 y 3, 1461 y 1467 en relación al art. 1682, a saber: la ley (prohibitiva), las buenas costumbres y el orden público.

Pues bien, una de las normas de orden público –esto es, irrenunciables e indisponibles por las partes– más relevantes en materia contractual es el art. 1546 del mismo Código, conforme al cual “[l]os contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”. De ahí que, como bien apunta FUEYO –empleando términos del Derecho Romano–, por expresa disposición de la ley ya no hay *contratos de derecho estricto* (que eran aquellos que obligaban taxativamente al tenor de lo prometido o pactado), sino que todos son *contratos de buena fe* (que además obligaban a todo lo que es exigible a personas justas y leales).

Conforme expresamente señala el art. 1546, la buena fe cumple, en primer término, una *función integradora* del contrato, en cuanto éste obliga a más de lo expresamente pactado, formando también parte de la convención los deberes que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley o la costumbre le pertenecen a ella. La norma en análisis es antecedida por el art. 1545, que consagra el principio *pacta sunt servanda*, siendo del todo evidente que los deberes que emanan de la buena fe son tan “ley para los contratantes” como las que contiene la convención escrita. En este sentido, recientemente la Corte Suprema ha resuelto que el principio de la buena fe impone el deber de cooperar con la ejecución del negocio, lo que supone adoptar un rol activo, siendo así la buena fe un “elemento integrador de los contratos y, concebida de ese modo, sirve de basamento al deber de garantía que asumen los contratantes”.

Adicionalmente, existe absoluto consenso doctrinal y jurisprudencial en torno a que el principio de la buena fe contractual consagrado en el art. 1546 también cumple una *función interpretativa*. Como señala BARAONA, en virtud del principio de la buena fe, el sentido y alcance se puede extender más allá de lo literal, a fin de establecer el sentido más funcional a la intención de los contratantes, ajustándose al objeto y causa de la convención.

Se debe destacar que el principio de la buena fe “tiene una función importante que jugar en regímenes subjetivos de interpretación contractual”, y precisamente por ello tanto la doctrina como la jurisprudencia indican el artículo 1560 es plenamente concordante con el art. 1546; el primero establece el querer jurídico de las partes, mientras el segundo su deber jurídico.

Así, la buena fe constituye un principio a la luz del cual todo contrato debe ser informado, integrado e interpretado. Como señala BETTI, la buena fe contractual consiste esencialmente en un “deber de cooperación debido en interés ajeno”, y por lo mismo se traduce en una conducta leal caracterizada por el consciente respeto hacia el interés de la contraparte, esto es, en una actitud activa de cooperación en interés ajeno, en una actitud de fidelidad al vínculo. Al decir de la Corte Suprema:

“tanto la doctrina como la jurisprudencia de esta Corte Suprema ha considerado a la buena fe, en su aspecto objetivo, como la conducta que puede esperarse de un hombre correcto,

puesto que es un estándar de conducta, que al darle contenido es empleado como sinónimo de probidad, lealtad, confianza, seguridad, honorabilidad, de no contradicción del comportamiento observado y fair play o juego limpio, considerando, en su caso, la función económica que tienen los negocios jurídicos, que impone la cooperación, colaboración, asesoramiento e información entre las partes, comportándose de manera activa, pues le asiste la obligación de salvaguardar el interés de la otra parte, en un contrato”.

Atendido lo anterior, en materia de hermenéutica contractual se entiende que interpretar según la buena fe se traducirá en que debe desestimarse toda aplicación de una norma contractual que conduzca a un resultado deshonesto o desleal. En este sentido, como decíamos, la interpretación de la buena fe es plenamente concordante con la regla general de interpretación de los contratos establecida en el artículo 1560 del Código Civil, pues en esta intención siempre el intérprete deberá buscar los elementos de cooperación, lealtad y rectitud que encierra la buena fe contractual.

En consecuencia, y no obstante los términos aparentemente claros, amplios y perentorios de una estipulación sobre responsabilidad civil, esta nunca puede ser interpretada de forma tal que permita un obrar desleal o incorrecto de parte de alguno de los contratantes. Más adelante nos referiremos a casos específicos sobre la materia.

2.3. Por su naturaleza, las cláusulas que exoneran, reducen o restringen la responsabilidad civil deben ser interpretadas restrictivamente.

Otra regla de interpretación que es de especial relevancia en esta materia es la contemplada en el art. 1563, cuyo inciso primero dispone: “*En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato*”.

Como se adelantó, la doctrina y jurisprudencia nacional admiten la validez de las normas contractuales que de algún u otro modo alteran –sea agravando, limitando o exonerando– el régimen legal de responsabilidad civil, reconociendo eso sí su eficacia ciertos límites, como se analizará más adelante.

La validez y eficacia de estas cláusulas se admite no sólo para los casos y materias expresamente señaladas por el legislador (vid. art. 1547 inciso final y art. 1673), sino que para otras materias, entre ellas, por ejemplo, las que buscan restringir la indemnización eventual a una suma determinada, siempre que al efecto se respeten los límites que el mismo ordenamiento jurídico establece.

Pues bien, la propia naturaleza de las cláusulas limitativas de la responsabilidad, imponen que ellas sean interpretadas de manera estricta o restrictiva. Ello es así, en atención a que la responsabilidad –esto es, el deber de toda persona de soportar, hacerse cargo y responder de las consecuencias dañosas de sus actos– constituye un principio general del Derecho

Civil. De ahí que la doctrina nacional afirme que el principio de responsabilidad constituye una limitación al principio de libertad, y que por ello las cláusulas que restringen la responsabilidad son de carácter excepcional.

A nivel doctrinal existe consenso en entender que, por ser el principio de responsabilidad uno de los fundamentales en materias civiles, toda convención destinada a limitarla debe ser necesariamente interpretada de forma restrictiva.

Que las cláusulas limitativas de responsabilidad deban ser interpretadas restrictivamente, se traduce en el hecho que no puede pretenderse su aplicación a materias que no se encuentren expresamente tratadas en ella.

2.4. La interpretación de una cláusula limitativa de responsabilidad no admite presumir la voluntad o intención de condonar el dolo (o culpa grave) pasado.

Las normas del Código Civil que reglamentan los requisitos de eficacia de los actos jurídicos constituyen un muy relevante insumo al intérprete, en cuanto establecen los presupuestos necesarios que debe contener una determinada declaración de voluntad para tener eficacia, o bien establecen los límites de la autonomía privada.

En lo que interesa, el art. 1465 cumple esa doble función, al disponer lo que sigue: *“El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada, no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente. La condonación del dolo futuro no vale”*.

Desde una perspectiva hermenéutica, esta disposición contiene dos hipótesis: (i) por un lado, la primera parte (*“El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada, no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente”*) consagra los requisitos o presupuestos necesarios para que una declaración de voluntad, de una determinada clase, produzca efectos; y (ii) por el otro, la segunda parte (*“La condonación del dolo futuro no vale”*) consagra un límite a la autonomía privada. La primera parte del art. 1465 será analizada en este apartado, mientras que la segunda lo será en el apartado que sigue.

Una primera cuestión que se debe observar en relación a la primera parte del art. 1465 es que éste, no obstante referirse al *“pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada”* – cuestión que en general se asimila a un finiquito-, es de aplicación general, conforme indica la doctrina de modo uniforme.

Siendo de aplicación general, debe entonces entenderse que la primera parte del art. 1465 no solo se aplica a los finiquitos totales (también denominados cláusulas exonerativas de responsabilidad), sino que también a los finiquitos parciales, como lo son las cláusulas que restringen o limitan la responsabilidad, que no son otra cosa que un pacto de no pedir más

que un determinado monto a título de indemnización, o bien solo referido a determinadas situaciones.

En específico, y como también señala de forma uniforme la doctrina nacional, la norma o principio general que consagra la primera parte del art. 1465 consiste en que se admite la condonación del dolo (o de la culpa grave) pasado o presente, en la medida que dicha condonación (i) se realice en términos expresos, esto es, de manera explícita y directa; y (ii) se extienda en el cabal conocimiento de los hechos que constituyen el dolo que se está perdonando.

De este modo, desde un punto de vista interpretativo, la primera parte del art. 1465 está imponiendo estos dos presupuestos (empleo de términos expresos, y conocimiento del dolo) a efectos de que valga –esto es, produzca efectos- la condonación del dolo pasado, de modo tal que si una cláusula no cumple con tales requisitos, debe necesariamente entenderse que no existe una condonación del dolo (o culpa grave) pasada. En Consecuencia, resulta inadmisibles concluir, desde un punto de vista interpretativo, que por muy amplios y omnicomprendivos que sean los términos de una cláusula exonerativa o limitativa de responsabilidad, en ésta se haya condonado el dolo (o culpa grave) pasado o presente, si no se indicó en términos expresos y en plena conciencia de quien perdona.

2.5. A su turno, la condonación del dolo (o culpa grave) constituye un límite a las cláusulas restrictivas de responsabilidad civil.

Como se ha indicado, la segunda parte del art. 1465 dispone que “[l]a condonación del dolo futuro no vale”. Desde luego, analizada la disposición desde la perspectiva de la eficacia de los actos jurídicos, existe total consenso en que una contravención a esta disposición constituye una hipótesis de objeto ilícito que, en cuanto tal, da lugar a la nulidad absoluta del acto o contrato de conformidad a lo dispuesto en el art. 1682 del Código Civil.

Ahora bien, analizada la norma desde la perspectiva de la interpretación contractual, aparece con igual evidencia que esta disposición constituye un claro límite a la autonomía privada, en cuanto constituye una prohibición que no se permite trasgredir.

En cuanto al fundamento de este límite a la libertad contractual, se suele indicar, en términos generales, que atiende a razones de moralidad; más jurídicamente, se observa que no daría cuenta de una voluntad seria de obligarse, que en cuanto tal sería constitutiva de una condición meramente potestativa del deudor (“cumpliré sólo si así lo quiero”), las que carecen de validez de conformidad al inciso primero del art. 1478; y, desde un punto de vista práctico, resulta un límite sumamente útil, pues de no existir sería una cláusula de uso habitual.

Este límite a la autonomía privada adquiere especial relevancia en lo que se refiere a las cláusulas modificatorias de la responsabilidad civil, pues por su intermedio jamás las partes podrían condonar el dolo (o culpa grave) futuro. Así lo señala de forma absolutamente uniforme la doctrina nacional, y en idéntico sentido se ha pronunciado la jurisprudencia.

Al efecto, cabe recordar que el art. 44, luego de definir la culpa grave o lata (que “consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”), agrega que “[e]sta culpa en materias civiles equivale al dolo”. La doctrina acertadamente observa que la culpa grave equivale al dolo en cuanto “es una proyección de este en el plano objetivo”, atendido que es un “hecho objetivamente indistinguible del doloso”, y por ello es la forma de probar el dolo. Sobre la materia, cabe recordar que en nuestro ordenamiento jurídico, tan identificados se encuentran los conceptos de culpa grave y dolo, que por regla muy general el Código Civil alude a ellos de manera conjunta. Ello es así en atención a que, en buena medida, la culpa grave es un estándar derivado del dolo, y de ahí que se les dé idéntico tratamiento jurídico.

Lo que se viene señalando tiene una evidente vinculación con el ya referido deber de interpretar de buena fe los contratos, atendido que tanto el dolo como la culpa grave son contrarios a la buena fe, y por tanto toda interpretación de un contrato, por amplios que sean sus términos, debe necesaria e ineludiblemente rechazar como resultado el que se admita o de alguna manera proteja o salvaguarde un obrar doloso o gravemente culpable.

En consecuencia, una interpretación guiada por la buena fe nos impone concluir que la limitación de responsabilidad estipulada en un contrato, no obstante los amplios, absolutos y perentorios términos que se empleen, en caso alguno podría amparar una infracción dolosa o gravemente culpable de la convención, atendido que ello implicaría aceptar y derechamente amparar un resultado evidentemente deshonesto, cuestión que como se ha visto se encuentra vedada por nuestro ordenamiento jurídico.

3. ANÁLISIS PARTICULAR DE DETERMINADAS CLÁUSULAS DE ESTILO

3.1. Del sentido y alcance que debe darse a la cláusula conforme a la cual “no se admitirá interpretación” de una cláusula en particular o del contrato en general.

Una primera estipulación que amerita comentar es aquella que, al referirse al entendimiento de las cláusulas que alteran la responsabilidad civil, dispone que ello “no admitirá interpretación”, o bien que la regulación contractual se realiza “para evitar cualquier duda en la interpretación”; y otras análogas.

Lo cierto es que, como observa la doctrina nacional, la existencia de tal clase de estipulaciones en caso alguno impiden que el juez despliegue una labor hermenéutica de la convención, primeramente porque la interpretación es precisamente la vía de determinar el

alcance y efectos jurídicos de la convención. Como observa CLARO SOLAR, siempre es necesario realizar una interpretación del contrato, aun cuando en apariencia sean claras e inequívocas.

En consecuencia, la supuesta o aparente claridad de una cláusula contractual –al punto que la misma indique que “no admite ser interpretada”- no es óbice para realizar una labor interpretativa; o, si se quiere, la oscuridad o ambigüedad de una estipulación no es una condición necesaria para desarrollar la labor hermenéutica, la que siempre es procedente desde que existe una controversia en torno al sentido y alcance de un contrato.

Por lo demás, esta clase de cláusulas –que pretenden “impedir” la interpretación- parten del supuesto de que el contrato escrito se basta a sí mismo, cuestión que como hemos visto es errada, pues el art. 1546 precisamente dispone que los contratos obligan a más de lo estipulado; y siendo dicha disposición una norma de orden público, la misma no es disponible para las partes.

3.2. Del sentido y alcance que debe darse a las exoneraciones y limitaciones de responsabilidad que se pactan respecto de “todo” o “cualquier” incumplimiento.

Por otro lado, también se observa en la práctica que se suelen pactar cláusulas limitativas de responsabilidad que, en términos bastante categóricos y absolutos, afirman que se aplican a “todo” o a “cualquier” incumplimiento.

Sin embargo, y por las razones ya reseñadas, no obstante la amplitud de dichas cláusulas, las limitaciones de responsabilidad que en ellas se pactan en caso alguno se podrían hacer extensivas a un incumplimiento doloso o gravemente negligente.

Además de los motivos ya expuestos para arribar a dicha conclusión, se agrega uno fundado en el denominado *principio de la normalidad*, que también forma parte de la naturaleza de la convención, y que presupone que, no existiendo una regla expresa en contrario, las partes regulan sus relaciones para eventos normales, y no extraordinarios. Y precisamente es en base al referido criterio de normalidad que la ley distribuye la carga de la prueba.

En lo que se refiere a incumplimientos contractuales, la ley, siguiendo el criterio de la normalidad, asume que lo habitual será que la convención se infrinja a causa de la negligencia del deudor, y precisamente por ello es que establece una presunción en tal sentido en el inciso tercero del art. 1547. Por el contrario, la misma ley asume que lo extraordinario sea que el contrato sea incumplido con dolo, y por ello es que el art. 1459 afirma que el dolo no se presume, sino que debe ser probado (a menos que la ley indique lo contrario).

Por tanto, el que un contrato aluda en general a “incumplimientos”, sin calificarlos de negligentes o dolosos, impone concluir que la convención únicamente está haciendo referencia a la infracción contractual imputable a culpa leve (que es lo habitual, al punto que la ley así lo presume), y no al incumplimiento doloso o gravemente culpable (que es lo extraordinario, y que por tanto la ley impone acreditar).

3.3. Del sentido y alcance que debe darse a las estipulaciones que establecen limitaciones a la responsabilidad aplicable a “todo” o “cualquier” daño.

Una estipulación contractual que habitualmente se vincula con la analizada en el apartado anterior, es aquella mediante la cual se pretende establecer una limitación de responsabilidad que sea aplicable a “todo” o a “cualquier” daño.

Al respecto, y como se ha venido señalando, nuestro ordenamiento jurídico señala de forma clara y consistente que el autor de un obrar doloso (o gravemente culpable) tiene el deber de responder de “todo” daño, sin que le sea aplicable ninguna clase de limitación de responsabilidad en lo que se refiere a la naturaleza y cuantía de la reparación.

Así aparece, en primer término, en el inciso segundo del art. 1458, conforme al cual *“el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado [...] por el total de los perjuicios [...]”*. Concordante con lo anterior, el inciso primero del art. 1558 dispone: *“Si no se puede imputar dolo al deudor, sólo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento”*.

Esta norma es de especial relevancia, ya que da cuenta que el dolo y la culpa grave constituyen un agravante de la responsabilidad contractual, de modo que en tales casos no solo se debe responder los perjuicios previstos, sino que también de los imprevistos o no contemplados por las partes; esto es, se responde de todo daño. Este agravamiento de la responsabilidad civil se encuentra en que el dolo y la culpa grave rompen la proporcionalidad entre indemnización y culpa, lo que impone que el acreedor tenga derecho a ser indemnizado a fin de quedar en una posición similar a la que se encontraba antes de contratar (o como si no hubiera contratado).

Si bien el inciso final del art. 1558 señala que *“[l]as estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas”*, de modo que se conteste la doctrina y la jurisprudencia entienden que en ningún caso se admite que, mediante una estipulación, se altere la regla conforme a la cual el responsable de dolo o culpa grave debe responder de todos los perjuicios, previstos e imprevistos. Al respecto, GATICA señala que *“en caso de dolo, la responsabilidad del deudor por los daños directos no puede sufrir ninguna atenuación, ni siquiera por voluntad de los contratantes”*. En igual sentido se ha pronunciado la jurisprudencia.

3.4. **Del sentido y alcance que debe darse a la cláusula que habilita a indemnizar todo daño, inclusive “los indirectos”.**

También en base al inciso final del art. 1558, se observan contratos en que –al contrario de la estipulación analizada en el apartado anterior- se busca agravar la responsabilidad contractual, por la vía de establecer que incluso se responderá de “daños indirectos”.

Se afirma que tal estipulación sería válida en base al hecho que el inciso primero del art. 1558 prescribe que, en caso de dolo, se debe responder de *“todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento”*, para luego disponer, en su inciso final, que *“[l]as estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas”*.

No compartimos tal análisis exegético, en cuanto el mismo se traduce en sostener que una parte tendría que responder de perjuicios que, en cuanto indirectos, son indeterminables; esto es, tal cláusula significaría que el deudor tendría que responder de manera indefinida, cuestión que no es posible, ya que se alteraría todo el sistema de responsabilidad civil, que necesariamente presupone que exista una relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño; si tal relación de causalidad no existe, no puede haber responsabilidad civil.

Ahora bien, ello no significa necesariamente que los contratantes no puedan estipular que se responderá más allá de los daños efectivamente causados, ya que el Código Civil expresamente permite tal convención, pues, al regular la cláusula penal, expresamente señala que habrá derecho a exigir la pena, *“sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio”* (art. 1542). Con todo, esta convención reconoce un límite, establecido en el art. 1544, al regular las diversas hipótesis de cláusula penal.

En definitiva, la cláusula que permite cobrar daños indirectos únicamente tendrá eficacia en la medida que forme parte de una cláusula penal, la que ineludiblemente deberá respetar los límites del art. 1544.